

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН



Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

Ниш, 2020. године

БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ПРИРЕЂИВАЧ: Апелациони суд Ниш

За приређивача: Драган Јоцић, председник суда

ИЗДАВАЧ: Paragraf Lex д.о.о., Сремска Каменица

За издавача:

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: Соња Симоновић Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКИ ОДБОР: Драган Јоцић, председник суда,
Зоран Поповић, Снежана Милошевић,
Гордана Павловић, Добрила Здравковић
Зорица Стошић, Ружица Јовановић,
Тања Ристић, судије Апелационог суда

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: Мирјана Милутиновић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКА ПРИПРЕМА СЕНТЕНЦИ: Мирјана Милутиновић, Јелена Јовановић
Момировић, судијски помоћници
Апелационог суда у Нишу

ПРЕЛОМ, КОРЕКТУРА И ДИЗАЈН: Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОМОТА: Наталија Стојановић

ШТАМПАРИЈА: Београф, Нова Пазова

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.11)

БИЛТЕН/Апелациони суду Нишу; главни одговорни уредник Драган Јоцић. - 2010, бр. 1- . - Нови Сад : Paragraf Lex, 2010- (Нова Пазова : Београф). - 21 cm

Два до четири пута годишње.

ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу
COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202. Кривичног законика). Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

Садржај

КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ	5
СЕЋАЊЕ ЈЕДНОГ СУДИЈЕ	9
ГОДИШЊИ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА СУДИЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ ЗА 2020. ГОДИНУ	13
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020.ГОДИНУ УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА АПЕЛАЦИОНЕ СУДОВЕ.....	25

КРИВИЧНО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА29

ОДГОВОРНОСТ ЗА ТЕЖЕ ОБЛИКЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА	31
---	----

ПРАВНИ СТАВОВИ, ЗАКЉУЧЦИ

И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА.....51

ПРЕГЛЕД УСАГЛАШЕНИХ СТАВОВА	53
-----------------------------------	----

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА59

ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ, НЕДОУМИЦЕ И ДИЛЕМЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА У ПАРНИЦАМА ИЗ РАДНИХ ОДНОСА	61
МЕХАНИЗМИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА СА ОСВРТОМ НА ПРОТОКОЛ БРОЈ 16	90

**ПРАВНИ СТАВОВИ,
ЗАКЉУЧЦИ И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА.....103**

ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНОГ
СУДА У НИШУ ОДРЖАНЕ ДАНА 19.02.2021. ГОДИНЕ. 105

**ГРАЂАНСКО ПРАВО
СУДСКА ПРАКСА107**

РАДНО ПРАВО149

КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ

МОДЕЛ ОКВИРА КОМПЕТЕНЦИЈА – СУДИЈА

I ВЕШТИНЕ И СПОСОБНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ

- Обезбеђује ефикасан тимски рад у пријатној радној атмосфери.
- Ефикасно управља предметима: делотворно утврђује приоритете, избегава непотребна одлагања у поступку
- Ангажује се на професионалном развоју и усавршавању других : активно учествује у развијању компетенција сарадника, помоћника и особља
- Конструктивно сарађује са другима, нарочито са припадницима других професија, подстичући сарадњу и заједнички рад

ЛИЧНЕ, СОЦИЈАЛНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

- Сагледава разноликост друштвеног окружења у којем суд функционише
- Поступа са другима са поштовањем и обзиром, правично и без предрасуда и дискриминације по било ком основу
- Поступа у складу са Етичким кодексом
- Поступа у складу са начелима независности и интегритета
- Показује смиреност и ауторитет у захтевним и непријатним ситуацијама
- Саопштава материјално-правне и процесне информације на одговарајући начин, једноставно и лако разумљивим језиком

ПРАВНОТЕХНИЧКЕ

- Суди ефикасно и делотворно
- Управља поступком на непристрасан и објективан начин
- Предузима неопходне припремне радње у поступку и сагледава различита процесна решења
- У стању је да ради брзо и под притиском
- У стању је да брзо и делотворно усвоји и анализира велики број информација, чињеница и правних аргумената
- Доноси јасно образложене одлуке

П ЗНАЊЕ

ПОЗНАВАЊЕ ПРАВА

- Поседује висок ниво познавања материјалног и процесног права и начелима на којима оно почива
- Стално тежи да ажурира, унапреди и прошири своје знање, у контексту друштвених и економских промена
- Редовно прати развој у судској пракси релевантних судова, као што су Врховни касациони суд, Уставни суд, Европски суд за људска права, Европски суд правде и слично

ПОЗНАВАЊЕ ВАНПРАВНИХ ОБЛАСТИ

- Поседује способност да делотворно користи различите изворе информација, укључујући и електронске базе података
- Користи информационе и комуникационе технологије у свакодневном раду
- Активно тежи стицању, развијању и унапређењу знања из ванправних области као што су медицина, економија, форензика, информационо-комуникационе технологије и слично

Драган Јоцић

судија Врховног касационог суда

председник Апелационог суда у Нишу

СЕЋАЊЕ ЈЕДНОГ СУДИЈЕ

„Господе!”

„Ја сам једино биће на земљи којем си Ти дао своје свемогућности: власт да осудим или ослободим ближњег... На мој знак врата затвора се затварају за леђима осуђеног, или се отварају, једнога дана, за слободу. Моја пресуда може претворити сиромаштво у иметак или богатство у беду. Од моје одлуке зависи судбина многих живота... сви су подложни од рођења до смрти Закону који ја представљам, Правди коју значим... И када једнога дана, коначно паднем, и тада се као кривац појавим пред Твојом узвишеношћу, Присутношћу, за последњи суд, погледај ме са милошћу и изреци Господе пресуду Своју.

Суди ми као Бог.

Ја сам судио као Човек.” (из судијске молитве).

Зато судије, будите достојне моћи која вам је дата. Занемаримо овом приликом да је као корелатив овлашћењима и улози која је дата судијама, прописана и њихова овоземаљска одговорност.

Као да је јуче било. Када сам почетком те, сада давне 2005. године крочио у Врховни суд Србије, као новоизабрани судија тог суда. Није било судије у Србији који поступа у управној материји који није поштовао несумњиви ауторитет у овој области, заснован на свезнању, судију Љубу Пљакића. У грађанској материји то су биле судије Предраг Трифуновић, Снежана Андрејевић, Љубица Милутиновић а у привредној судија Драгиша Слијепчевић. У кривичној материји судије Евалд Грубер, Томислав Ђурђевић, Никола Латиновић. И одједном ја међу њима: судија кривичар Врховног суда Србије. Један од двадесет троје. Под притиском њиховог ауторитета стасала

је још једна генерација судијских ауторитета: судије Јанко Лазаревић, Новица Пековић, Драгиша Ђорђевић, Драгомир Милојевић а следећи њих, судије Невенка Важић, Бата Цветковић. Трудио сам се да бар мало пажње и ја заслужим. Ризик побрајања (и нужног изостављања неких имена) је присутан. Пријало је када нас колеге препознају, али и обавезивало, за сваку написану или изговорену реч. Племство обавезује.

Ова генерација судија одлази из судова. Већина је тихо, један за другим, отишла. Последњи представници генерације су при одласку. На одласку, желели то или не, нужно се осврнемо за собом, да погледамо шта остављамо али и да призовемо сећања. Управо ова генерација је подарила судству првог изабраног председника Врховног касационог суда, председнике апелационих судова у Нишу и Новом Саду. Нешто раније и председника Уставног суда.

Осврнувши се, сетио сам се заиста великог ауторитета некадашњих судија окружних судова, у то време крајњег домета судијског напредовања сем за заиста ретке, и једног колегијума судија. Старији судија Д. Васиљевић, мени тек изабраном судији окружног суда је пре почетка колегијума рекао: „Отиди да почистиш гробницу, пало је лишће по њој. Јуче сам био да запалим свећу твом оцу.” Од смрти мог оца протекло је тридесет година. Судија је свом судији поред кога је стасавао, данас би рекли свом ментору, запалио свећу толико година после његове смрти. Има ли данас судија са таквим поштовањем према старијим, па и преминулим, судијама. Или немамо времена чак ни на сахрану да им одемо. Уместо тога верујемо да је довољна СМС порука. Или нам је тако комфорније. Одговорност је вероватно подељена. Постоји реална сумња да поједине судије поред којих треба да стаса нова, будућа генерација судија, имају све мање времена и стрпљења да својом улогом ментора завреде дужну пажњу, поштовање.

Одлази једна, у време пуне снаге нужно, али и данас, дубоко у својим душама аналогна генерација. Данашња, дигитална на својим мобилним телефонима поручује ПОЗЗЗ. Један колега, адвокат, рекао је за судије Врховног суда: мозгови који ходају. Зато што су нама коментари закона, обимна судска пракса, једном речју знање, морали бити у нашим главама, знању. Данас су у фолдерима. Али, и после ПОЗЗЗ, младе колеге ће на интернету отварати десетине стручних радова одлазећих судија.

Одлази ова генерација зато што треба да оде. Хируршки нож заменио је гама нож. Веште руке старијег хирурга замењују веште руке за цојстиком.

Ако треба да оде, постављам питање зашто писати о томе? Ваља запамтити, поменути. Ја својим менторима поштовање одајем на овај начин. Била ми је част што сам са Вама.

Без обзира на промене којима одлазећи повремено приговарају, охрабрује сазнање да међу младим судијама препознајемо не мали број колега чије каријере обећавају. Не по напредовању, већ по стручности. Младе колеге, вратите се на почетни пасус!

Напомена:

Чланак је објављен у дневном листу „Политика“, дана 09.03.2021.године, број 38539

ГОДИШЊИ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА СУДИЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. ст. 1. Закона о уређењу судова и члана 46 – 48. Судског пословника, донео је Годишњи распоред послова судија за 2020. годину.

I

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи **Драган Јоцић**, председник суда.

За заменике председника суда одређују се судије **Снежана Милошевић** и **Соња Симоновић Стојановић**.

Судији Снежани Милошевић поверавају се и посебне обавезе за информисање и контакте са јавношћу и медијима (портпарол).

За руководиоца службе председника суда одређује се **Јелена Јанчетовић**, секретар суда.

У њеном одсуству замењиваће је Јасмина Кузмановић, судијски помоћник.

II

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

У суду постоје следећа одељења:

- Кривично одељење;
- Грађанско одељење;
- Одељење за радне спорове;
- Одељење за поступање по захтевима за заштиту узбуњивача;
- Одељење судске праксе.

ПРЕДСЕДНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА СУ:

1. **Кривично одељење:** председник одељења је судија Зоран Поповић, а у случају његове одсутности или спречености замењиваће га судија Слободан Стојилковић.
2. **Грађанско одељење:** председник одељења је судија Марина Ђукић, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Соња Симоновић Стојановић.
3. **Одељење радних спорова:** председник одељења је судија Ивана Рађеновић, а случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Тања Ристић.

За уређивање Веб сајта суда задужује се судија Соња Симоновић Стојановић.

За праћење и евиденцију одлука Европског суда за људска права, Уставног суда, стручних реферата и судске праксе других судова у штампаним публикацијама које суд прима у недовољном броју примерака за све судије задужују се судије Весна Стевановић, Јасмина Јововић, Добрила Здравковић и Тања Ристић.

III

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Зоран Крстић, председник већа;
2. Љиљана Миљковић, члан;

II – ВЕЋЕ

1. Снежана Милошевић, председник већа;
2. Слободан Стојилковић, члан;
3. Дијана Јанковић, члан.

III – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа;
2. Јасмина Јововић, члан;
3. Весна Стевановић, члан.

IV – ВЕЋЕ

1. Гордана Павловић, председник већа;
2. Иван Булатовић, члан.

V – ВЕЋЕ

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа;
2. Саша Бошковић, члан;
3. Горана Митић, члан.

III-a

Одређују се већа која ће поступати по жалбама изјављеним против одлука Апелационог суда (Кж-3 предметима).

I- ВЕЋЕ

1. Снежана Милошевић, председник већа;
2. Горана Митић, члан;
3. Мирјана Ђорђевић, члан.

II- ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа;
2. Зоран Крстић, члан;
3. Гордана Павловић, члан.

III-6

За поступање у предметима малолетних учинилаца кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица одређују се III и V веће.

Судијски помоћници распоређени у веће чији су чланови судије одређене за поступање у предметима малолетних учинилаца кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, као и судијски помоћници распоређени у већа чији су чланови судије одређене за поступање по жалбама изјављеним против одлука апелационог суда у КжЗ-предметима, према распореду послова за 2020. годину, обрађиваће и предмете у овим материјама.

III-в

За предмете у којима већа поступају у петорном саставу, веће које је задужено предметима ће се допунити члановима првог наредног већа, до потребног броја.

Председника већа замењује први члан већа.

Дежурна већа за време годишњих одмора у кривичном одељењу су:

- у јулу V веће;

- у августу I веће.

Одређује се и посебно веће за поступање искључиво у старим предметима према Програму решавања старих предмета овог суда.

1. Драган Јоцић, председник већа;
2. Снежана Милошевић, члан;
3. Слободан Стојилковић, члан;
4. Марина Ђукић, члан;
5. Ивана Рађеновић, члан.

С тим што ће члана овог већа чинити и судија који реферише старе предмете. Ово веће се не задужује новим предметима.

IV

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Марина Ђукић, председник већа;
2. Невена Благојевић, члан;
3. Драган Крстић, члан.

II – ВЕЋЕ

1. Снежана Лазић, председник већа;
2. Милица Златковић, члан.

III – ВЕЋЕ

1. Стојанка Вујошевић, председник већа;
2. Никола Пржић, члан;
3. Оливера Јовановић, члан.

IV-ВЕЋЕ

1. Соња Симоновић Стојановић, председник већа;
2. Јадранка Митровски, члан,
3. Горан Контић, члан.

V-ВЕЋЕ

1. Добрила Здравковић, председник већа;
2. Снежана Тодоровић, члан,
3. Зоран Стаменковић, члан.

VI-ВЕЋЕ

1. Зорица Стошић, председник већа;
2. Миљана Стојковић, члан.

Председника већа замењује први члан већа.

IV-a

Одређују се судије које ће одлучивати по жалбама изјављеним против решења Вишег суда у Нишу, која су донета у поступцима у којима се утврђују чињенице о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породициштва или здравствених установа у Републици Србији и поступке у којима се досуђује правична новчана накнада нематријалне штете.

I ВЕЋЕ

1. Соња Симоновић Стојановић, председник већа;
2. Јадранка Митровски, члан већа;
3. Горан Контић, члан већа.

II ВЕЋЕ

1. Марина Ђукић, председник већа;
2. Зорица Стошић, члан већа;
3. Невена Благојевић, члан већа.

Судију који је одсутан или спречен да поступа замениће судија Миљана Стојковић.

Судијама које буду задужене предметима ове материје, рачунаће се као редован прилив предмета.

V

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

I – ВЕЋЕ

1. Ружица Јовановић, председник већа;
2. Данијела Божовић, члан.

II – ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа;
2. Биљана Стаменковић, члан;
3. Даниела Радовић, члан.

III – ВЕЋЕ

1. Тања Ристић, председник већа;
2. Слађана Стојановић, члан;
3. Лидија Стошић, члан.

IV- ВЕЋЕ

1. Ђорђе Гојгић, председник већа;
2. Зорица Цветковић, члан;
2. Ксенија Џомбић, члан.

Председника већа замењује први члан већа.

V-a

У предметима рехабилитације поступаће судије:

1. Иван Булатовић;
2. Саша Бошковић;
3. Соња Симоновић Стојановић;
4. Никола Пржић;
5. Зорица Стошић.

У саставу овог већа, без обзира ко је судија известилац, члан већа биће судија који поступа у Кривичном одељењу.

VI

ПОСТУПАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу чл. 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, за поступање у предметима заштитите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

У предметима из области Грађанског права

- Стојанка Вујошевић
- Никола Пржић
- Оливера Јовановић

У предметима из области Радних спорова

- Ивана Рађеновић
- Тања Ристић
- Ђорђе Гојгић

У предметима из области Кривичне материје

- Снежана Милошевић
- Слободан Стојилковић
- Дијана Јанковић

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списка предмета у којем је ово право повређено.

Поступци у предметима по приговорима и по жалбама се међусобно изједначавају приликом завођења и расподеле предмета.

Судијама које буду задужене предметима ове материје, рачунаће се као редован прилив предмета у материјама у којима поступају.

VII

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

I- ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа;
2. Слађана Стојановић, члан;
3. Ксенија Џомбић, члан.

II-ВЕЋЕ

1. Тања Ристић, председник већа;
2. Јадранка Митровски, члан;
3. Добрила Здравковић, члан.

Председника већа замењује први члан већа.

За поступање у предметима унутрашњег узбуњивања поступаће судија Добрила Здравковић.

Предмети примљени у овој материји рачунаће се судијама који су њима задужени у редован прилив предмета.

VIII

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине судије:

Драган Јоцић, председник суда, руководица судске праксе суда.

Зоран Поповић, председник Кривичног одељења, заменик руководиоца судске праксе.

Гордана Павловић, руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија **Снежана Милошевић**.

Добрила Здравковић, руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија **Зорица Стошић**.

Ружица Јовановић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија **Тања Ристић**.

Судијски помоћник **Милан Ђорђевић** у Кривичном одељењу, а случају његове одсутности или спречености, замењиваће га судијски помоћник **Зоран Ђурђевић**.

Судијски помоћник **Миљана Поповић Ђурић**, у Грађанском одељењу, а случају њене одсутности или спречености, замењиваће је судијски помоћник **Јелена Голубовић**.

Судијски помоћник **Ивана Ђурђић Митровић** у Одељењу радних спорова, а случају њене одсутности или спречености, замењиваће је судијски помоћник **Наташа Митковић**.

Редакцију Билтена судске праксе суда чине судије овог одељења с тим да је главни и одговорни уредник Билтена председника суда **Драган Јоцић**, а његови заменици судије **Зоран Поповић** и **Соња Симоновић Стојановић**.

IX

Непотпуна већа биће допуњена, до пуног састава, судијама других већа из исте материје према месечном распореду који сачињава Судска управа, а на предлог председника одељења, и благовремено уручује судијама на које се допуна већа односи.

Судска одељења ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе из своје области и оцењивати резултате рада одељења у целини и појединачно судија и судијских помоћника.

Годишњи извештај за 2020.годину Упоредни приказ података за апелационе судове

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	13	118	951	6.65	1.069	986	6.90	83	0
НОВИ САД	11	85	1.028	8.50	1.113	1.011	8.36	102	0
КРАГУЈЕВАЦ	11	56	886	7.32	942	900	7.44	42	0
БЕОГРАД	22	147	1.145	4.73	1.292	1.042	4.31	250	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ2”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР.СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	13	1	727	5.08	728	721	5.04	7	0
НОВИ САД	11	13	2.121	17.53	2.134	2.127	17.58	7	0
КРАГУЈЕВАЦ	11	4	830	6.86	834	834	6.89	0	0
БЕОГРАД	22	25	2.758	11.40	2.783	2.752	11.37	31	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	16	944	3.459	19.65	4.403	3.292	18.70	1111	1
НОВИ САД	23	686	2.982	11.79	3.668	3.263	12.90	405	0
КРАГУЈЕВАЦ	22	1.265	3.116	12.88	4.381	3.615	14.94	766	0
БЕОГРАД	38	4.034	7.704	18.43	11.738	7.848	18.78	3890	53

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	11	1.616	3.689	30.49	5.305	3.886	32.12	1419	0
НОВИ САД	14	749	3.695	23.99	4.444	3.954	25.68	490	0
КРАГУЈЕВАЦ	11	1.507	3.927	32.45	5.434	3.540	29.26	1894	0
БЕОГРАД	17	1.623	4.067	21.75	5.690	4.060	21.71	1630	8

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ2”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	16	54	470	2.67	524	491	2.79	33	0
НОВИ САД	13	32	520	3.64	552	525	3.67	27	0
КРАГУЈЕВАЦ	22	19	521	2.15	540	510	2.11	30	0
БЕОГРАД	38	75	576	1.38	651	560	1.34	91	0

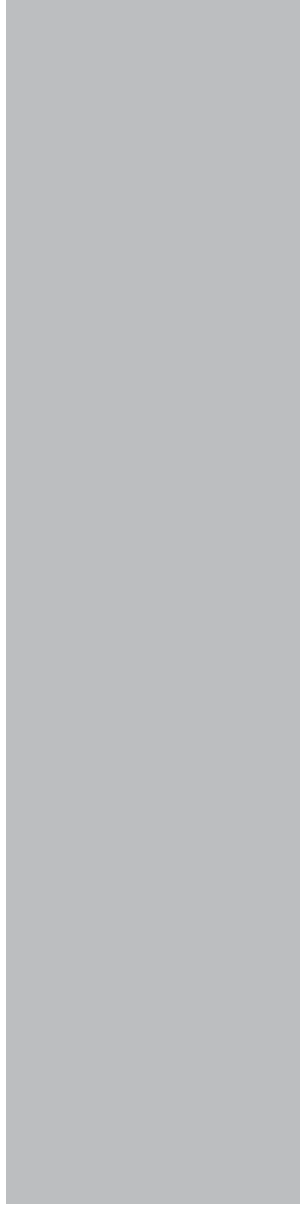
ПРИКАЗ ПОДАТАКА УКУПНО НА НИВОУ СУДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР.СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	40	2.814	10.841	24.64	13.655	11.211	25.48	2444	1
НОВИ САД	48	1.589	11.631	22.03	13.220	12.160	23.03	1060	0
КРАГУЈЕВАЦ	44	2.883	10.700	22.11	13.583	10.825	22.37	2758	0
БЕОГРАД	78	6.202	19.072	22.23	25.274	18.941	22.08	6333	62

АПЕЛАЦИОНИ СУД	ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У СУДУ	САВЛАДАВАЊЕ ПРИЛИВА	АЖУРНОСТ	УКУПАН КВАЛИТЕТ
НИШ	82.10	103.41	2.71	99.23
НОВИ САД	91.98	104.55	1.09	98.66
КРАГУЈЕВАЦ	79.70	101.17	3.09	97.09
БЕОГРАД	74.94	99.31	3.98	98.18

КРИВИЧНО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА



Драган Јоцић

судија Врховног касационог суда

председник Апелационог суда у Нишу

ОДГОВОРНОСТ ЗА ТЕЖЕ ОБЛИКЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Животно се често дешава да наступи тежа последица по жртву или заштитни објекат кривичног дела од оне која редовно наступа, због чега је законодавац био принуђен да их издвоји и предвиди као посебне, теже, облике основних дела предвиђајући за њих и строже казне. Институт одговорности за тежу последицу је традиционалан у нашем кривичном законодавству. У Кривичном законiku (Сл. лист ФНРЈ бр. 13/51) био је одређен чланом 8 став 1 и гласио: „Ако је из кривичног дела произашла тежа последица за коју закон прописује тежу казну, тежа казна ће се изрећи ако се та последица може приписати нехату учиниоца”. Међутим ставови правне теорије и судске праксе су били јединствени – да је за примену овог института на учиниоца потребан **најмање његов нехат** али да се примењује и када је учинилац у односу на тежу последицу поступао са умишљајем. Овакво законодавно решење остаје све до доношења КЗ у 2006. години.

Усаглашавајући законску одредбу са правном теоријом и судском праксом законодавац је законску одредбу допунио тако да сада гласи: **кад је из кривичног дела произашла тежа последица због које закон за то дело прописује тежу казну, та се казна може изрећи ако је учинилац у односу на ту последицу поступао из нехата, а и са умишљајем ако тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела** (члан 27 КЗ).

Карактеристично је да се одредба о одговорности за тежу последицу не примењује непосредно. Не примењује се ни у вези кривичног дела и када се дело правно оцењује као тежи облик основног дела, за разлику од већине института општег дела КЗ. Стога представља одредбу – услов, основ или услов за примену на појединачне случајеве. Примена овог института исцрпљује се у примени норме која садржи тежи облик дела. Одредба је задржала стари назив: одговорност за тежу последицу. Нови Кривични

законик је напустио појам кривичне одговорности и на њено место увео кривицу, па је било логично да институт носи назив, наслов, **кривица за тежу последицу**. Независно од тога у раду ће бити коришћен законски назив института.

Ранији КЗ/51 је предвиђао три основа, института, тежих облика кривичних дела: кривична дела квалификована тежом последицом, кривична дела квалификована нарочитим околностима и особито тешке случајеве кривичних дела. Нови законик брише институте кривичних дела квалификованих нарочитим (тежим) околностима и особито тешке случајеве кривичних дела. Ову измену није пратила измена обележја појединих кривичних дела, тако да се у њиховим обележјима појављују ови институти.

ОДНОС ОВОГ ИНСТИТУТА СА ПРОДУЖЕНИМ КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ

Институт одговорности за тежу последицу је правна конструкција, слична конструкцији продуженог кривичног дела, која се, као општи институт, примењује на поједина кривична дела те се њен домашај може потпуно сагледати само ако се сагледају могуће комбинације елемената који је чине.

Код продуженог кривичног дела се **више кривичних дела која су у реалном стицају**, из криминално политичких разлога а у сваком случају због околности које су ван обележја самих дела, сваког од учињених дела, **преводе у идеални стицај**. Њиховим спајањем добија се привид једног, продуженог дела, односно већем броју кривичних дела, учињених са више радњи извршења, даје се правно јединство, сматра се да је учињено једно дело. Код кривичног дела са тежом последицом **постоји идеални стицај последица једне радње**, једне делатности, учиниоца. Тежа последица треба да резултира из радње основног дела. Обрнуто посматрано, ако бисмо елиминисали криминално политичке разлоге или оно што је ван обележја сваког од почињених дела код продуженог дела, било би их онолико колико их је извршилац починио. Код кривичног дела са тежом последицом нема околности које су ван обележја дела. Да овог института нема постојало би једно дело са основном последицом, док би тежа последица била некањива, или реални стицај тог дела и дела чије обележје је тежа последица.

Сличност ових института посебно је видљива у случају примене става 4 одредбе о продуженом кривичном делу, којим је одређено да ако продужено кривично дело обухвата лакше и теже облике истог дела, сматраће се да је продуженим кривичним делом учињен најтежи облик од учињених дела. Идентично је и код дела са тежом последицом, јер се радње учиниоца квалификују према најтежој последици. Учиниоца који оштећеном ударцем песницом нанесе тешку телесну повреду па другим ударцем другу која изазове смртну последицу чини два дела али ће одговарати за квалификовани облик тешке телесне повреде чија последица је смрт, односно према најтежој последици. **Идеалног стицаја нема само зато што је посебном одредбом општег дела КЗ одређено да је основно дело конзумирано квалификованим обликом.** Квалификовано кривично дело искључује постојање стицаја са лакшим кривичним делом због појачане одговорности, кажњивости, за тежу последицу. Да тога нема, постојао би стицај.

Идентична је ситуација и када законска обележја једног дела истовремено представљају квалификаторну околност другог дела (овде се не крећемо у оквирима истог дела као у претходном ставу). Дакле, постоји идеални стицај, али га конструкција квалификованог облика дела брише. Нема стицаја кривичног дела насилничког понашања (члан 344 КЗ) када је учинилац, поред грубог вређања, нанео оштећеном лаке телесне повреде. Грубо вређање и лаке телесне повреде су елементи кривичног дела насилничког понашања, без обзира што су посебна кривична дела.

Код обе правне конструкције основ је да је у већем садржано мање односно у тежем је садржано лакше.

Оба института су у корист окривљеног, јер се више дела сматрају једним и учинилац се кажњава за то једно дело али се приликом одмеравања казне може узети у обзир као отежавајућа околност број насталих последица основног и квалификованог облика дела, иако конзумираних у квалификованом облику дела. Конструкција кривичног дела са тежом последицом најчешће **отклања могуће дилеме о стицају кривичних дела**, прописујући једно дело и једну казну, иако не потпуно. Тиме се и кривични поступак значајно поједностављује и убрзава, посебно ако се има у виду да је за највећи број кривичних дела прописана тежа последица. Изостављањем квалификованих, тежих, облика у правној норми занемарила би се стварна, животна, реална последица дела. За кривична дела са тежом последицом законодавац за теже

последике прописује строжу казну, често тежу од оне која би могла бити изречена за кривична дела у стицају, тако да у овом сегменту институт није на корист учиниоца. Не само то, већ се оваквом решењу, присутном код појединих кривичних дела, може приговорити да није логички оправдано да се учинилац строже казни када је у односу на тежу последицу поступао из нехата, него када је у односу на њу поступао са умишљајем, односно када би постојала два умишљајна кривична дела.

Конструкцијом дела са тежом последицом се избегава, иако не потпуно, али се у сваком случају сужава примена стицаја, због неодвојивости једне делатности учиниоца у више. Без ове конструкције део последица основног дела, тежих последица, остао би некажњив у оним случајевима када закон не прописује самостално, посебно, кривично дело које би покривало ту, тежу, последицу. У том случају би се тежа последица могла ценити само као отежавајућа околност код одмеравања казне за основно дело. Стога је овакво решење добро са аспекта кривичноправне заштите јер последице кривичног дела „покрива” у целини али може бити теже по окривљеног.

ТЕЖА ПОСЛЕДИЦА ИЛИ ТЕЖИ ОБЛИК ДЕЛА ИЛИ ТЕЖЕ ДЕЛО

На помен одговорности за тежи облик дела, сасвим оправдано, прва асоцијација је да је реч о кривичним делима квалификованим тежом последицом. Ранију одредбу о одговорности за тежу последицу КЗ/2006 је допунио делом који гласи: „а и са умишљајем ако тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела.” Законодавац јасно одређује да тежа последица може бити и умишљајна али садржи и дистинкцију – да тиме нису остварена обележја другог дела, несумњиво тежег од квалификованог облика основног дела. Држећи се оваког законског решења може се поставити градијација дела према тежини последице на: 1) основне облике, 2) облике са тежом последицом (квалификоване облике) и 3) облике који су због тежине последице прописани као посебна дела, односно тежа дела. Тиме је сужено поље примене појачане одговорности само на непосредну последицу дела и само на случајеве када је прописана одговорност за тежу последицу.

Решење садржано у општем делу КЗ/2006 брише раније институте одговорности за дела квалификована нарочитим околностима и особито тешке случајеве. Измену, односно брисање ових института у општем делу КЗ није пратила измена појединих одредаба посебног дела КЗ, оних у којима су

садржани квалификовани облици кривичних дела. Анализом кривичних дела која имају своје квалификоване облике, дакле засноване на посебном делу КЗ, показује се да градација кривичних дела према тежини последице заснована на одредби општег дела о одговорности за тежу последицу није потпуна, односно да недостаје став одредбе који би обухватио **теже облике дела**. Држећи се претходног градација кривичних дела према тежини последице би била: 1) основни облик, 2) облик квалификован тежом последицом, 3) тежи облик дела и 4) теже дело.

Разлика између дела квалификованог тежом последицом и тежег облика основног дела је теоријска, не захтева посебан напор у примени. Посебно и због тога што су тежа последица и тежи облик основног дела по правилу садржани у истој одредби у којој је и основно дело. Квалификован облик основног дела је између дела квалификованог тежом последицом и тежег кривичног дела, одређено према тежини последице, својству пасивног субјекта или околностима дела. Дакле оно превазилази меру дела квалификованог тежом последицом али још увек није посебно, односно теже дело. Тежи облик дела постојаће увек када су разлози за његово прописивање ван непосредне последице основног дела.

Добар пример међусобног односа ових института је кривично дело разбојништва. Уколико је неком лицу при извршењу разбојништва нанета нехатна тешка телесна повреда, што представља класичан услов дела квалификованог тежом последицом, неће постојати тај облик, јер га законодавац не предвиђа, већ стицај разбојништва и нехатне тешке телесне повреде. Међутим, ако је тешка телесна повреда умишљајна, разбојништво неће бити квалификовано тежом последицом, већ ће постојати квалификовани облик кривичног дела разбојништва из става 2 члана 206 КЗ. Уколико је у истој ситуацији и са истим обликом виности неко лице лишено живота, неће бити ни основног дела разбојништва, ни његовог квалификованог облика, јер прераста у тешко убиство из члана 114 тачка 4 КЗ. У овом случају неће бити стицаја разбојништва и тешког убиства.

Код овог дела из става два учинилац у односу на вредност одузетих ствари може поступати са умишљајем када зна да вредност одузетих ствари прелази цензус или са нехатом, када је олако држао да вредност одузетих ствари не прелази цензус. Без обзира на ову разлику неће бити промењена квалификација кривичног дела, примениће се иста одредба, односно став

2 члана 206 КЗ. Дакле, код појединих кривичних дела учинилац може поступати у односу на тежу последицу са умишљајем или из нехата а да то не мења квалификацију кривичног дела.

Иако се ради о варијацијама једног, основног, дела законодавац се није определио да један тежи облик искључује други. Дело квалификовано тежом последицом такође може имати свој тежи облик. Карактеристично је дело злостављања и мучења (члан 137). Ставом два је предвиђен облик квалификован тежом последицом, када примењена сила пређе меру из става један одредбе, док је ставом три предвиђен тежи облик и за став два, иако последице дела остају исте, уколико је дело извршило службено лице у вршењу службе.

Ни правна теорија, нити судска пракса, не инсистирају доследно на разлици између теже последице дела и тежег облика дела тако да се ни у даљем току рада на њој неће инсистирати. Наиме, у оба случаја се користи синтагма „тежи облик дела” као генусна. Међутим, ако би се инсистирало на постављању критеријума за разликовање облика о којима је реч а држећи се законодавне формулације, могући критеријум разликовања, иако га се законодавац не држи доследно, би био:

Квалификован облик основног дела законодавац најчешће формулише одредницом „Ако је услед дела из става 1 (или и 2)...”. Тиме се исказује чврста веза основног дела и теже последице. Примери су чланови 120 ст. 4; 121 ст. 3; 121а ст. 4; 125 ст. 4; 126 ст. 3; 208 ст 3 и 4...

Код тежег облика основног дела та веза је нешто блажа и најчешће гласи „Ако је дело из става 1 (или и 2) учињено... Примери су чланови 119 ст. 4; 125 ст. 4; 128 ст. 2; 135 ст. 5...

Теже дело постојаће онда када се најпре због тежине последица основног дела, или околности под којима је учињено... мења правна оцена дела, када основно дело прераста у друго, теже, дело. Теже дело има своја обележја у којима понавља радњу основног дела као у члану 114 или се позива на основно дело као у члану 204 КЗ. У неколико случајева законодавац се позива на бројчане ознаке основних дела, прописујући само последице основног дела, које их чине тешким делима, као код кривичног дела тешко дело против здравља људи из чл. 259, тешког дела против опште сигурности из чл. 288 или тешког дела против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. Иако

ове одредбе представљају класичан пример дела квалификованих тежом последицом законодавац их означава као тешка дела.

УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНУ

1. Предвиђеност у закону

Први услов примене одговорности учиниоца дела за тежу последицу или тежи облик дела је предвиђеност такве одговорности у законским обележјима кривичног дела. Стога суд није овлашћен, чак и ако је дело имало тежу последицу, да радње окривљеног квалификује као дело са тежом последицом, уколико законска обележја тог дела то не предвиђају. Могуће је да наступи иста околност која код другог дела јесте прописана као тежа последица али то суд не овлашћује да, аналогијом, кривично дело код кога та околност није предвиђена, које нема квалификован облик, правно оцени као кривично дело са тежом последицом. Код једног телесна повреда јесте, код другог иако је примењена сила није тежа последица. Стицај кривичног дела разбојништва и лаке телесне повреде није могућ, нити је лака телесна повреда квалификаторна околност овог дела. Лака телесна повреда је обухваћена „применом силе” код овог кривичног дела. Међутим, код кривичних дела спречавања службеног лица у вршењу службене радње или напада на исто, лака телесна повреда јесте квалификаторна околност. Кривична дела квалификована тежом последицом могу бити прописана само законом, тако да не могу бити производ конструкције практичара.

Законодавац обележјима основног дела додаје допунска обележја, која делу дају тежи облик. „Квалификаторна околност мора бити потпуно чињенично одређена у опису дела у изреци пресуде да би из таквог описа проистекла тежа квалификација дела” (ВКС Кзз 85/2016).

Узрочно последична веза

Законском одредбом није изричито прописана узрочно последична веза радње извршења основног кривичног дела и наступеле теже последице. Неопходност постојања ове везе произлази из општег појма кривичног дела, односно неопходности да постоји узрочна веза између радње и последице јер је тежа последица такође последица кривичног дела и она мора такође бити у узрочном односу са радњом извршења. Та веза неће постојати ако је тежа последица наступила случајем или услед неке околности која не улази у

радњу извршења или радњом трећег лица која прекида повезаност основног дела и теже последице или се не може приписати ни нехату учиниоца. Узрочна веза се мора утврдити пре него што се пређе на утврђивање виности учиниоца за тежу последицу.

3. Акцесорна природа теже последице

Да би се уопште разматрала тежа последица неопходно је да су испуњена сва обележја основног дела из којег је тежа последица произашла. Дакле, тежа последица је акцесорна, уз основно дело, те уколико нису испуњени услови за опстајање основног дела, неће бити ни облика тог дела са тежом последицом. Основно кривично дело је темељно, па ако нема основног дела, нема ни његовог квалификованог облика. Дакле, тежи облик дела претпоставља постојање основног дела и појављује се као посебна квалификација тог дела.

Основно дело неће постојати ако постоји неки од института, основа, који искључују постојање кривичног дела, односно уколико је основно дело малог значаја (што је тешко замисливо у пракси), ако је учињено у нужној одбрани, крајњој нужди, под дејством неодољиве силе, у неотклоњивој стварној или правној заблуди или је у одредби кривичног дела предвиђено да се учинилац неће казнити (видети члан 112 став 29 КЗ). Наиме, законодавац за побројане институте изричито прописује да нема кривичног дела иако постоје обележја кривичног дела прописана законом. Основно дело неће постојати ни уколико недостају субјективна обележја општег појма кривичног дела.

Основно дело може остати у покушају а да учинилац буде оглашен кривим за тежу последицу истог дела. Наравно да је претпоставка да је покушај основног дела кажњив (члан 30 КЗ). Примера ради код покушаја кривичног дела силовања и испољене спремности жртве да искочи из возила како би избегла извршење кривичног дела, па то и учини и наступи смрт жртве, учинилац ће бити крив за квалификован облик силовања у покушају пошто му се може приписати виност и за тежу последицу, и онда када није био свестан али је према околностима и својим личним својствима могао то бити (ВСС Кжм 323/80). Идентична је ситуација уколико жртва кривичног дела отмице, бежећи од учиниоца падне и због пада по њу наступе тешке последице, због којих отмица не буде довршена.

Покушај тежег облика дела није могућ прво, уколико се ради о кривичним делима код којих покушај није кажњив и друго, онда када тежа последица

произлази из последице основног облика, јер је дело у покушају па ни основна последица није наступила.

Могућ је и дијаметрално супротан случај: да је основни облик кривичног дела свршен а да покушај тежег облика није могућ.

Наравно да и тежи облик кривичног дела, сам за себе, и независно од основног кривичног дела, захтева испуњеност одређених услова.

Код појединих кривичних дела законодавац не успоставља „пуну” акцесорност тежих облика основног кривичног дела. Квалификовани облици тих кривичних дела не обухватају све последице основног облика дела, већ само неке од њих. Тако код кривичног дела злоупотребе службеног положаја (члан 359) основно дело ће постојати ако је прибављена каква корист или другом нанета каква штета, код испуњених осталих услова дела, док квалификовани облици овог дела обухватају само прибављање користи, не и штете, и то не ни какве као у основном облику, већ само имовинске користи.

Виност учиниоца

Уколико постоје основи који искључују противправност или виност учиниоца неће бити основног кривичног дела, што искључује и његов тежи облик. За отклоњиву стварну и правну заблуду учинилац може одговорати за кривично дело из нехата али уколико је за основно дело прописан искључиво умишљај неће бити дела у ма ком облику. Дакле, кривица учиниоца за тежу последицу дела мора бити заснована на његовој виности. Виност се утврђује прво у односу на основно дело, па потом и у односу на тежу последицу. Код основног кривичног дела виност се утврђује у оном облику који је законом прописан. Уколико је за основно дело прописан нехат он се утврђује, као и нехат у односу на тежу последицу (нехат на нехат). Овакво законодавно решење је присутно код кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја, против здравља људи, опште сигурности.

Случајно произведена тежа последица или ако није обухваћена ни нехатом, учиниоцу се не може ставити на терет. Супротан став би водио увођењу објективне одговорности.

Изузетно, уколико је из основног кривичног дела произашла тежа последица али основно дело није извршено са умишљајем, који је услов постојања основног дела, неће постојати то кривично дело квалификовано тежом последицом али зато може постојати друго кривично дело. „Када је

кривично дело тешке телесне повреде нехатно учињено, па је услед истог наступила тежа последица – смрт повређеног која се такође може приписати нехату учиниоца, у радњи оптуженог постоји само кривично дело убиства из нехата” (ВСС Кж 1335/65). У овом случају је примењен принцип консумпције.

Уколико је учинилац у односу на тежу последицу поступао са умишљајем, може постојати идеални стицај двају умишљајних кривичних дела. Учинилац ће бити крив за кривична дела силовања и убиства уколико је у односу на смртну последицу поступао са умишљајем. Ако је смрт жртве нехатна биће остварена обележја квалификованог дела силовања, иако садржи силовање и нехатно убиство јер је посебном одредбом прописан тежи облик кривичног дела. Супротно овоме ако је умишљај учиниоца да жртву лиши живота наношењем бројних тешких телесних повреда постојаће само кривично дело убиства, док ће тешке телесне повреде бити конзумиране. Дакле силовање неће бити конзумирано убиством када су обе последице умишљајне а тешке телесне повреде ће бити конзумиране кривичним делом убиства, иако су теже последице оба дела умишљајне.

Код кривичног дела изнуђивања исказа квалификован облик ће постојати уколико је изнуђивање исказа праћено тешким насиљем. Готово је извесно да учинилац овог облика дела у односу на примену тешког насиља поступа са умишљајем као обликом виности. Идентично је и код квалификованог облика кривичног дела принуде када учинилац прети убиством или тешком телесном повредом или отмицом, код несумњивог закључка да ове претње морају бити умишљајне. У оба случаја постојаће квалификовани облици ових дела иако је тежа последица умишљајна. Стога када је учинилац поступао са умишљајем и у односу на основно дело и у односу на проистеклу тежу последицу (умишљај на умишљај) постојаће квалификован облик основног дела под условом да тежа последица није предвиђена као посебно дело. Уколико јесте постојаће стицај двају умишљајних кривичних дела.

ШТА ДЕЛО ЧИНИ КВАЛИФИКОВАНИМ

Бројност радњи основног кривичног дела. Кривично дело које у основном облику није колективно, може добити тежи облик ако се врши у виду занимања. Пример је кривично дело недозвољеног прекида трудноће (члан 120 КЗ) које у ставу два прописује квалификован облик за учиниоца

који се бави вршењем дела из става 1 овог члана. Идентично решење је и код кривичног дела трговине малолетним лицима у ставу 2 одредбе члана 389 КЗ, за учиниоца који се бави вршењем делатности из става 1 одредбе, као и код кривичног дела кријумчарења из члана 236 КЗ у којем је, ставом 2, предвиђено „ко се бави продајом, растурањем или прикривањем неоцаријене робе...” Такође код кривичног дела изнуде и уцене те кривичног дела прикривања и недозвољене трговине.

Нарочите околности под којима је дело учињено. Већ је речено да су нарочите околности извршења дела представљале посебан институт у старом кривичном законодавству. Институт је брисан у важећем КЗ али је остао обележје појединих квалификованих облика кривичних дела. Овај основ теже последице дела одступа, па чак и негира основни принцип конструкције дела са тежом последицом, јер основно дело нема тежу последицу. Тежу последицу замењује околностима под којима је дело учињено. Делом је остварена последица основног дела али је дело учињено под околностима које га чине тежим обликом.

Код кривичног дела одавања државне тајне квалификован је облик кривичног дела ако је дело извршено за време ратног стања, или ванредног стања. Уколико је кривично дело силовања извршено у присуству више лица, само присуство више лица извршењу дела, чини га квалификованим, извршеним на нарочито понижавајући начин. „Када окривљени после извршеног силовања над оштећеном одузме њену бунду, када сила и претња нису примењени, чини кривично дело тешке крађе извршене на нарочито дрзак начин (ВСС Кж1 1128/86).

У овим случајевима основ теже квалификације су нарочите околности извршења основног дела, али са последицом основног дела. На ову групу кривичних дела примењују се опште одредбе о виности учиниоца. Уколико је за основна дела прописан умишљај као облик виности онда и нарочите околности извршења морају бити обухваћене умишљајем учиниоца а уколико је облик виности за основно дело нехат онда и околности извршења дела могу бити нехатне.

Ако су делом изазване нарочито тешке последице такође је реликт старог кривичног законодавства. Код кривичног дела оштећења поверилаца постојаће ако је повериоцу проузрокована штета великих размера или ако је због тога дошло до покретања поступка принудног поравнања или стечаја

према повериоцу. Чланом 136 став 2 КЗ прописан је квалификова облик уколико су за окривљеног услед изнуђеног исказа наступиле нарочито тешке последице у кривичном поступку.

Ако су делом изазване тешке последице које се, за разлику од претходног, не подводе под нарочито тешке. Кривично дело кршење породичних обавеза има тежи облик ако је наступило тешко нарушење здравља услед кршења законом утврђених обавеза издржавања. Код кривичног дела зеленаштва ако су наступиле тешке последице за оштећеног, док кривично дело проузроковања лажног стечаја ставом 2 прописује квалификован облик ако су за повериоца наступиле тешке последице. Код кривичног дела напуштања немоћног лица постојаће квалификован облик дела ако је наступило тешко нарушење здравља остављеног лица (чл.126 став 2 КЗ), идентично као и код наредног кривичног дела непружања помоћи или претходног, излагања опасности. Тежи облик кривичног дела шпијунаже постојаће ако су наступиле тешке последице за безбедност, економску или војну моћ земље.

Имовиски цензуси као квалификаторне околности су одређени новчаним износима и карактеристични су за кривична дела у главама кривичних дела против интелектуалне својине, против имовине, против привреде и против службене дужности. „Постигнута имовинска корист (исто важи и за штету) не представља последицу већ квалификаторну околност дела и ако није постигнута нема тог дела, па није могућ ни покушај, већ се ради о свршеном делу из претходног става” (ВСС Кж1 267/82). Код појединих кривичних дела је имовински цензус повезан са коришћу или штетом, примера ради код кривичног дела преваре из чл. 208 став 3 или злоупотребе поверења из чл. 216 ст. 2 и 3 јер из природе ових дела произлази да су корист и штета корелативи, односно да прибављање користи једном повлачи за собом штету другом. Код кривичних дела кршење закона од стране судије, јавног тужиоца или његовог заменика или злоупотребе положаја одговорног лица су и корист и штета али не и нужно повезани.

Код групе кривичних дела имовински цензуси су повезани искључиво са штетом другоме, што их чини сличним са претходно разматраним квалификаторним околностима исказаним као тешке или нарочито тешке последице само сада исказане новчаним износима. Имовински цензуси повезани само са штетом присутни су код кривичних дела злоупотребе у вези са јавним набавкама (чл.228 ст. 2 и 3), злоупотребе у поступку

приватизације (чл. 228а ст. 2 и 3), несавестан рад у служби (чл. 361 ст. 2)... Нанета штета несумњиво може имати одраз и у прибављању користи али законодавац евентуалну корист занемарује, пре свега због заштитног објекта ових кривичних дела.

Трећа група кривичних дела је повезана искључиво са прибављањем користи и представља лик у огледалу у односу на претходно разматрану штету. Код кривичног дела уговарања исхода такмичења из чл. 208б ст. 2 и 3 штете у реалном, животном, и нема. Код других кривичних дела је по правилу има као код кривичних дела изнуде из чл 214 ст. 2 и 3 или уцене из чл. 215 ст. 2 и 3 или проневере у обављању привредне делатности из чл.224 ст. 2 и 3 или недозвољене трговине из чл. 235 ст 4... Међутим могућу штету законодавац занемарује такође повезано са заштитним објектом ових кривичних дела.

Занимљиво је кривично дело злоупотребе службеног положаја које у основном облику санкционише и корист и штету али у квалификованим облицима само корист.

Посебно својство учиниоца. Кривични законик прописује велики број кривичних дела код којих је тежи облик кривичних дела повезан са посебним својством учиниоца. Основни облици дела попримају теже облике када њихов извршилац има посебна својства и са њима повезан висок степен овлашћења и друштвене одговорности или обавља одређене функције или јавна овлашћења. Такав учинилац при вршењу основног дела злоупотребљава и овлашћења која су му дата за разлику од извршиоца који таква својства нема. Дело мора бити извршено у вршењу таквих овлашћења или у вези истих. Кривично дело злостављања и мучења постојаће у квалификованом облику ако је дело извршило службено лице у вршењу службе. Идентично је и код тежег облика кривичног дела нарушавања неповредивости стана или повреде равноправности из члана 128 став 2 КЗ. Тежи облик дела чини члан бирачког одбора који повреди тајност гласања или уништи документа о гласању. Својство васпитача, усвојιοца, родитеља, очуха или маћехе у извршењу кривичног дела обљубе злоупотребом положај основно дело чини квалификованим. Својство родитеља, усвојιοца или старатеља је околност тежег облика кривичног дела ванбрачне заједнице са малолетником. Својство адвоката у извршењу кривичног дела злоупотребе поверења. Међутим, посебно својство извршиоца не мора бити повезано са његовим посебним

овлашћењима. Код кривичног дела учествовања у групи која спречи службено лице у вршењу службене радње посебно својство извршиоца је одређено као „коловођа”, баш као и код кривичног дела учествовања у групи која изврши кривично дело из чл 349 КЗ.

Посебно својство заштитног објекта. Код кривичног дела угрожавања сигурности квалификован облик дела постоји уколико је дело извршено према председнику Републике, народном посланику, председнику владе... судијама... Узрост жртве односно својство малолетника или детета стим што ова чињеница мора бити обухваћена виношћу учиниоца представља квалификаторну околност код кривичних дела подвођења из члана 183 КЗ, посредовања у вршењу проституције из члана 184 КЗ као и у члану 185 став 3 КЗ или својство новорођенчета код кривичног дела одузимања малолетног лица. Иако је предвиђено као посебно дело илустративан је пример да обична крађа прераста у тешку, без обзира на вредност украдене ствари, ако украдена ствар представља културно добро или уређај за воду, .. или уређаје система јавног саобраћаја. Навођење на самоубиство и помагање у самоубиству је квалификовано дело ако је извршено према детету или према неурачунљивом лицу, у мери да овај облик дела прераста у најтеже дело по запрећеној казни (учинилац ће се казнити по члану 114 КЗ). Ако је предмет противправног заузимања земљишта део националног парка или код кривично дела прикривања из чл. 221 уколико је ствар прибављена кривичним делом.

Средство извршења је квалификаторна околност зато што код појединих кривичних дела за собом повлачи већи степен угрожавања заштитног објекта. Ова околност постојаће ако је увреда или кривично дело изношења личних и породичних прилика извршена коришћењем средстава јавног информисања. Коришћење оружја или другог опасног оруђа је квалификаторна околност кривичног дела насиља у породици, као и лаке телесне повреде.

Уколико је дело извршило више лица. У овом случају дело је квалификовано због стицаја извршилаца, законом одређених као више лица, група или организована криминална група. Законодавац не одређује значење израза „више лица” али је пракса на становишту да ће овај услов бити испуњен уколико је најмање два извршиоца. Може их бити и више, под условом да због међусобне повезаности не прерастају у групу. Група је најмање три лица која морају да буду повезана ради трајног или повремениг

вршења кривичних дела. Више извршилаца је и код организоване криминалне групе уколико су испуњени додатни услови одређени чланом 112 КЗ.

Више лица као квалификаторна околност је најмање заступљена код појединачних кривичних дела. Изричито се наводи код кривичних дела против полне слободе (чл.178 ст. 2, чл. 179 ст. 2, чл.180 ст. 2 и чл.182 ст.3).

Група је обележје квалификованих облика кривичних дела принуде из чл. 135 ст. 4, разбојничке крађе из чл. 205 став 3, прикривања из чл. 221 ст. 4, неовлашћеног стављања у промет опојних дрога или код кривичног дела бекства и омогућавање бекства лица лишеног слободе из чл. 339 ст. 3.

Организована криминална група је квалификаторна околност кривичних дела отмице из чл 134 ст. 5, принуде из чл. 135 став 5, промене породичног стања из чл. 192 ст. 3, запустања и злостављања малолетног лица из чл. 193 ст. 2 разбојничке крађе, разбојништва, изнуде као и уцене...

Овакво законодавно решење је несумњиво лоше. Уколико не постоје елементи унутрашње организације, неће постојати организована криминална група али може постојати група а уколико недостаје циљна повезаност извршилаца неће постојати група али ће постојати више лица. Када је код појединих кривичних дела као квалификаторна околност одређена само организована криминална група (чл. 134 ст. 5) а нема елемената њене унутрашње организације нема тежег облика дела, већ само основног дела и саизвршилаштва иако постоји група али група није квалификаторна околност. Дакле оставља се не мала зона некажњивости која нема оправдања. Тај недостатак се лако може отклонити.

Начин извршења кривичног дела је такође квалификаторна околност у случајевима када законодавац оцењује да извршење превазилази меру која редовно прати основно дело или је испољена безобзирност извршиоца. Код кривичног дела силовања постојаће тежи облик дела уколико је извршено на нарочито свиреп или понижавајући начин. Код кривичног дела изнуђивања исказа из чл. 136 ст. 2 уколико је праћено тешким насиљем а код дела изазивања националне, расне и верске мржње и нетрпељивости ако је учињено злостављањем, излагањем порузи националних, етничких или верских симбола.

Мотив учиниоца у извршењу дела постоји код кривичног дела промене породичног стања ако је дело извршено из користољубља или других ниских

побуда, као и код кривичног дела одузимања малолетног лица из чл.191 ст. 4. Код кривичног дела одавања пословне тајне је користољубље а код неовлашћеног искоришћавање ауторског дела или сродног права када је дело учињено у намери прибављања имовинске користи, иако имовинска корист није обележје дела. Код кривичног дела преваре из чл. 208 ст. 2 када је дело учињено само у намери да другог оштети, без обзира да ли је штета наступила.

ПРИМЕНА У ПРАКСИ

Иста, једна, тежа последица не може бити квалификаторна околност два различита кривична дела, већ само оног од њих из ког је произашла.

Окривљени је кршењем саобраћајних прописа проузроковао тешко телесно повређивање оштећене, док је њена смрт последица непружања помоћи од стране окривљеног. Са становишта правилног схватања узрочности у кривичноправном смислу то значи да се смрт оштећене једино може повезати за непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди. Стога та последица не може опстати у описима оба кривична дела, већ само оног од њих чијом радњом је непосредно узрокована (ради се о односу кривичних дела из чланова 296 и 297 КЗ).

Не може постојати стицај кривичног дела квалификованог тежом последицом и посебног дела које обухвата исту последицу. Код постојања кривичног дела силовања из кога је наступила смртна последица може постојати или квалификован облик силовања или стицај силовања и убиства када је смртна последица умишљајна а никако квалификовано силовање у стицају са убиством.

Две или више околности које дело чине квалификованим воде правној оцени дела према једној од њих, по правилу најтежој.

Околност која је обележје кривичног дела, према члану 54 став 3 КЗ, може се узети као отежавајућа околност под условом да прелази меру потребну за постојање кривичног дела или одређеног облика кривичног дела или ако постоје две или више оваквих околности а само једна је довољна за постојање тежег, односно лакшег облика кривичног дела.

Тежи облик основног кривичног дела из члана 289 став 3 у вези става 1 КЗ, постоји ако је наступила тешка телесна повреда неког лица (члан 297

став 3) као и ако је наступила смрт једног или више лица (члан 297 став 4 КЗ). Како су у конкретном случају наступиле обе последице: смрт једног лица и тешка телесна повреда другог то се кривично дело квалификује према тежој од тих последици (став 4) а наступање и друге теже последице може бити цењена као отежавајућа околност код одмеравања казне (ВКС Кзз 233/2016). Најтежи облици кривичних дела злоупотребе положаја службеног или одговорног лица када је корист остварена преко новчаног цензуса претходних квалификованих облика конзумирају претходне, тако да ће постојати само тај, најтежи облик дела.

Одсуство умишљаја код основног кривичног дела не мора да за собом повлачи и апсолутно одсуство кривице учиниоца, па ни за тежу последицу.

Уколико је из основног дела произашла тежа последица али основно дело није извршено са умишљајем који је услов постојања основног дела, неће постојати то кривично дело квалификовано тежом последицом али зато може постојати друго кривично дело у којем је садржана тежа последица. „Када је кривично дело тешке телесне повреде нехатно учињено, па је услед истог наступила тежа последица – смрт повређеног која се такође може приписати нехату учиниоца, у радњи оптуженог постоји само кривично дело убиства из нехата (ВСС Кж 1335/65).

ТЕЖА КРИВИЧНА ДЕЛА

Код посебно предвиђених, тежих кривичних дела, квалификаторне околности дела су таквог значаја да дају нови вид већ постојећем делу, тако да то дело постаје ново дело. Квалификаторне околности чине саставни део бића новог, тежег дела.

Честа су кривична дела у нашем КЗ која су прописана као посебна управо због теже последице, било умишљајне или нехатне. То је већ друго по реду кривично дело у нашем КЗ, односно кривично дело тешко убиство. У ранијем периоду ово кривично дело није постојало као самостално већ је представљало квалификоване облике „обичног” убиства. Убиство је било прописано ставом један одредбе а тежи облици наредним ставовима одредбе. Кривично дело тешког убиства нема своју, посебну, радњу извршења већ преузима радњу извршења кривичног дела убиства. Уосталом, већ и назив

кривичног дела: тешко убиство у себи садржи назив основног кривичног дела: убиство; као и да је тежак облик овог дела. Потпуно је идентична ситуација са кривичним делом тешке крађе из члана 204 КЗ, јер и ово кривично дело позајмљује радњу кривичног дела крађе. Још карактеристичнија су кривична дела која се у свом бићу директно позивају на основна дела, прописујући само тежу последицу, попут кривичних дела тешка дела против здравља људи, тешка дела дела против опште сигурности, безбедности јавног саобраћаја, уставног уређења и безбедности Србије.

Међутим, за разлику од претходног, постоје кривична дела која су због теже последице прерасла у друго кривично дело и код којих је та тежа последица прикривена, односно на њу се не указује директно. Једно, лакше, дело је због теже последице садржано у другом, тежем делу. Кривично дело тешке крађе из става 1 тачка 1 садржи у себи кривично дело оштећења туђе ствари, кривично дело принуде је садржано у кривичном делу разбојништва а проневера је посебан вид утаје. У овим случајевима је у тежем садржано лакше, односно у већем је садржано мање.

Особито тешки случајеви кривичних дела ослањају се на ранијим законом предвиђену општу норму о одговорности за особито тешке случајеве. Особито тешки облици кривичних дела представљају субквалификацију ових дела, најтеже облике у којима се та дела могу појавити.

ЗАКЉУЧАК

Основном принципу дела са тежом последицом, да и у односу на тежу последицу мора постојати виност исказана као нехат, пракса судова олако приступа. Закључак произлази и из најчешће коришћене фloscuле у пресудама, која је присутна и у теорији, да се тежа последица „приписује” нехату учиниоца. Ова формулација се до данас задржала у пракси иако представља преузимање законске одредбе КЗ/1951 а брисане КЗ/2006 године. Тиме се умањује обавеза да се нехат учиниоца у сваком појединачном случају мора утврдити, уводећи кривицу за тежу последицу у зону објективне одговорности. Раније постојећи Савезни суд је укинуо пресуде окружног и врховног суда у којима је наведено да се тежа последица може приписати нехату учиниоца а нису дати разлози за тај облик виности, чиме је учињена повреда закона. Тежи облик дела није прост збир основног дела и теже

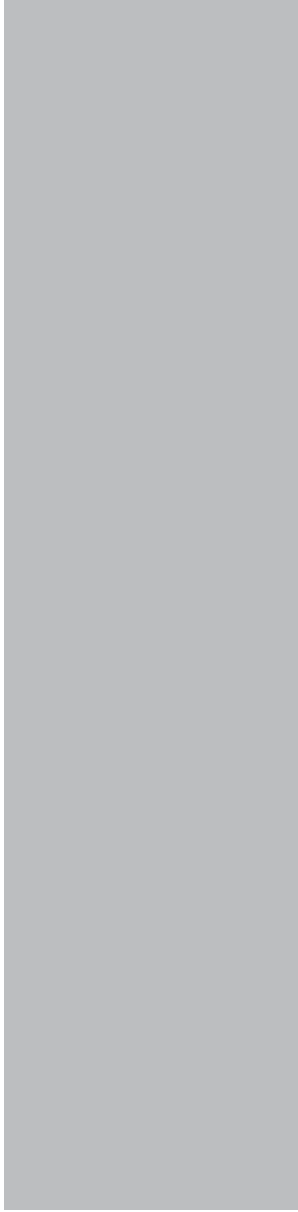
последнице већ представља целину у животном и кривичноправном смислу, са унутрашњом повезаношћу тих делова.

Радње учиниоца, према градацији постављеној у овом раду, могу бити оцењене као: 1) основно дело, 2) исто дело квалификовано тежом последицом, 3) тежи облик основног дела и 4) посебно, тешко дело утемељено на основном делу. Висина запрећених казни за поједине облике дела или тешког дела као посебно прдвиђеног, морала би да прати градацију дела по тежини. Посебно када се ради о тешким делима за која су запрећене најтеже казне. Погодан пример је кривично дело тешког убиства. Међутим, законодавац изменама које су ступиле на снагу 1. 12. 2019. године одступа од претходног, тако што за квалификоване облике кривичних дела из чланова 392 став 3; 178 став 4; 179 став 3 и 181 став 5 КЗ предвиђа најтежу казну доживотног затвора. Прописивање најтеже законом предвиђене казне за квалификоване облике основних дела, готово да није познато у упоредном праву. Запрећена најтежа казна је довољан разлог да наметне потребу издвајања квалификованих облика кривичних дела, за које је та казна запрећена, у посебна дела, односно једно дело које би обухватило тешке случајеве побројаних дела.

Готово је немогуће поставити јединствене моделе кривичних дела квалификованих тежом последицом, нити их сажети у мањи број критеријума за њихово одређивање.

Бројност кривичних дела која садрже квалификоване облике и широка лепеза животних догађаја које кривична дела покривају, те потреба да се квалификовани облици прилагоде сваком од основних дела, не дозвољава ни законодавцу, ни теорији да их сведу на неколико правила. То није успео ни овај рад.

ПРАВНИ СТАВОВИ, ЗАКЉУЧЦИ И ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА



**Врховном Касационом суду
Апелационом суду у Новом Саду
Апелационом суду у Београду
Апелационом суду у Крагујевцу
- председницима кривичних одељења -**

Поводом предстојећег заједничког састанка представника кривичних одељења Апелационих судова Републике Србије и Врховног Касационог суда, који би требало да се одржи у Нишу крајем марта месеца, Апелациони суд у Нишу је дана 11.3.2021. године одржао седницу кривичног одељења где је дао одговоре на спорно питање које кандидује за предстојећи састанак.

Спорно питање које Апелациони суд у Нишу кандидује за заједничку седницу:

1. Да ли је против решења које је донето на претресу пред другостепеним судом а којим се издваја незаконит доказ, дозвољена посебна жалба и ако јесте коме, у ситуацији када се жалбом браниоца окривљеног на првостепену пресуду указује на битну повреду одредаба кривичног поступка из чл.438. ст.2.тач.1.ЗКП јер се пресуда заснива на доказу на коме се по одредбама законика не може засновати а другостепени суд на претресу издваја управо тај доказ на који се жалбом указује и на коме је првостепени суд између осталог засновао осуђујућу пресуду. ?

Одговор усвојен већином гласова:

Уколико је на претресу пред другостепеним судом донето решење о издвајању незаконитих доказа, на такво решење није дозвољена посебна жалба.

Реферат судије Др. Дијане Јанковић:

1. Законик о кривичном поступку одредбом чл.16. ст.1 ЗКП одређује законски појам незаконитих доказа, док су у чл.84. ЗКП прописане одредбе о издвајању незаконитих доказа из списка предмета и о њиховом уништавању после правноснажности одлуке којом је окончан кривични поступак у коме су издвојени.

Питање које би претходило постављеном питању је: да ли се на претресу пред другостепеним судом доноси решење о издвајању недозвољених доказа, у ситуацији која је наведена у постављеном питању?

Законик о кривичном поступку прописао је фазе поступка када незаконити докази могу бити издвојени, те је прописна општа одредба чл.237. ЗКП о издвајању незаконитих доказа, затим одредба чл.337. ЗКП приликом испитивања оптужнице, одредба чл. 346. ЗКП на припремном рочишту, одредба чл. 358. ЗКП у припремању главног претреса, одредба чл.407. ЗКП на главном претресу и одредба чл. 445. ЗКП пред судом другог степена од стране судије известиоца.

ЗКП садржи одредбу чл.445. ст.2. ЗКП којом је прописано да судија известилац ако утврди да се у списима налазе записници или обавештења из члана 237. ст. 1. и 3. овог законика, донеће решење о њиховом издвајању из списка, против којег није дозвољена посебна жалба.

Међутим, наведено се односи на фазу другостепеног поступка, која претходи претресу или седници већа. Судија известилац након пријема списка предмета поводом жалбе (чл.445. ст.1. ЗКП) најпре проверава да ли се у списима предмета налазе незаконити докази, па ако утврди да је то случај, донеће посебно решење о њиховом издвајању (чл.445. ст.2. ЗКП).

Судија известилац не може извршити издвајање доказа који се побијају жалбом, јер само другостепено веће може одлучивати о жалбеним наводима. Другостепени суд доноси одлуку о жалби у седници већа или на основу одржаног претреса (чл.446.ст.1. ЗКП).

Одлучивање о незаконитости доказа пред другостепеним судом има одређене специфичности у односу на првостепени поступак, због саме природе поступка пред судом другог степена, јер другостепени суд испитује пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби (чл.451. ст.1. ЗКП) и расправља по правилу о основаности жалбених навода.

Одредбом чл.438. ст.2. тач.1. ЗКП је прописано да битна повреда одредаба кривичног поступка постоји ако се пресуда заснива на доказу на коме се по одредбама ЗКП не може заснивати, осим ако је, с обзиром на друге доказе, очигледно да би и без тог доказа била донесена иста пресуда.

Дакле, према наведеној законској одредби битна повреда одредаба кривичног поступка не постоји, иако се пресуда заснива на доказу на коме се према одредбама ЗКП не може заснивати, ако је с обзиром на друге доказе, очигледно да би и без тог доказа била донета иста пресуда. Заснивање пресуде на доказу на коме се по одредбама ЗКП не може заснивати представља битну повреду одредаба кривичног поступка, релативизовану могућношћу да се утицај ове повреде занемари „ако је, с обзиром на друге доказе, очигледно да би и без тог доказа била донесена иста пресуда“.

Из наведеног произилази да забрана заснивања пресуде на недозвољеним доказима није апсолутна и да ЗКП допушта да се пресуда заснује и на доказима који су проглашени за незаконите по одредбама ЗКП, под условом да у датом случају има и законитих доказа у мери која је била довољна за изрицање исте пресуде.

Из наведеног даље следи да законодавац није прописао да је суд другог степена у обавези да издвоји незаконите доказе, под наведеним условима (у случају да се жалбом предлаже издвајање незаконитих доказа), јер је по наведеној законској одредби (чл.438. ст.2. тач.1. ЗКП) суду правног лека остављена могућност да оцени да ли ће незаконити докази остати у пресуди, а у склопу осталих изведених доказа.

Такође, уколико суд правног лека оцени да се ради о незаконитом доказу и да су жалбени наводи основани, а да остали докази нису довољни да потврде наводе оптужбе, тј. да без тог доказа не би била донесена иста (осуђујућа) пресуда, веће ће одржати претрес пред другостепеним судом у смислу одредби чл.449. и чл.450. ЗКП и након одржаног претреса донети ослобађајућу пресуду.

Уколико странке предложе непосредно на претресу пред другостепеним судом издвајање незаконитих доказа, веће није у обавези да о томе доноси посебно решење и да на претресу пред другостепеним судом одлучује да ли су докази који су већ изведени пред првостепеним судом, и који се само понављају, законити или незаконити, јер се ради о жалбеном наводу који ће бити цењен приликом одлучивања о жалби.

Одредбом чл.449. ст.1. ЗКП је прописано да ће се претрес пред другостепеним судом одржати ако потребно да се због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања изведу или понове докази изведени или одбијени од стране првостепеног суда, те у том смислу се на претресу

пред другостепеним судом понављају докази који су већ изведени пред првостепеним судом, а оцена законитости односно незаконитости ће бити цењена као жалбени навод.

Другостепени суд ће у сваком случају након одржаног претреса донети пресуду и у оквиру жалбених навода, ценити законитост, односно незаконитост доказа, те зависно од тога донети и одлуку.

Одредбом чл.450. ст.6. ЗКП, је прописано да ће се одредбе о главном претресу пред првостепеним судом сходно примењивати и на претресу пред другостепеним судом, ако ЗКП није нешто друго одређено.

На претресу пред другостепеним судом неће се сходно примењивати одредбе које се примењују на претресу пред другостепеним судом из чл.407. ст.2 ЗКП, а које се односе на издвајање незаконитих доказа, јер је Законом о кривичном поступку у том погледу нешто друго одређено.

ЗКП је прописао да незаконите доказе пред судом правног лека може издвојити судија известилац након пријема списка у смислу чл.445.ст.2. ЗКП, при чему судија известилац није овлашћен да издваја доказе који су обухваћени жалбеним наводима, јер другостепени суд доноси одлуку о жалби само у седници већа или на претресу, те у оквиру одлуке другостепеног суда ће бити цењени и жалбени наводи о незаконитости доказа, који се истичу као битна повреда одредаба кривичног поступка из чл.чл.438. ст.2. тач.1.ЗКП, без доношења посебног решења о њиховом издвајању.

Сходно наведеном сам става:

Веће другостепеног суда на претресу пред другостепеним судом, неће доносити посебно решење о издвајању незаконитих доказа, јер се ради о жалбеним наводима који се цене у оквиру одлуке другостепеног суда.

2. Уколико су кривичне судије другог мишљења, те уколико су става да треба донети посебно решење о издвајању незаконитих доказа на претресу пред другостепеним судом, мишљења сам да на такво решење није дозвољена посебна жалба.

Одредбом чл.450. ст.6. ЗКП, је прописано да ће се одредбе о главном претресу пред првостепеним судом сходно примењивати и на претресу пред другостепеним судом само ако ЗКП није нешто друго одређено.

У конкретном случају, на претресу пред другостепеним судом не могу се применити одредбе о праву на жалбу на решење о издвајању незаконитих доказа на главном претресу из првостепеног поступка из чл.407. ст. 2 ЗКП, јер ЗКП предвиђа посебне одредбе у том правцу.

Ово стога јер је законодавац одредбом чл.445. ст.2. ЗКП изричито прописао да против решења којим је судија известилац издвојио незаконите доказе из списка предмета посебна жалба није дозвољена. Такође одредбом чл. 446. ст.4 ЗКП је прописано да је судија известилац и председник већа на претресу.

Одредба чл. чл.445. ст.2. ЗКП ће се у погледу права на жалбу, сходно применити и на решење о издвајању незаконитих доказа које је донето на претресу пред другостепеним судом, јер из наведеног произилази и да је интенција законодавца да пред судом другог степена није предвиђена жалба на решење о издвајању незаконитих доказа.

Законодавац је изричито предвидео да на решење о издвајању списка пред судом другог степена није дозвољена жалба, а поред тога ради се о жалбеном наводу, те би у том случају се дошло у ситуацију, да о жалби по којој поступа једно веће о жалбеним наводима из те жалбе, одлучује друго веће.

Поред тога, одредбом чл.465.ст.4. ЗКП је прописано да против решења другостепеног суда жалба није дозвољена, осим ако овим законом није другачије прописано, а у конкретном случају није прописана посебна жалба на решење о издвајању незаконитих доказа пред судом другог степена.

Сходно наведеном је одговор на постављено питање да: Уколико је на претресу пред другостепеним судом донето решење о издвајању незаконитих доказа, на такво решење није дозвољена посебна жалба.

Мањински став судија кривичног одељења је да је против предметног решења дозвољена посебна жалба о којој треба да одлучи друго веће другостепеног суда.

Председник кривичног одељења

**С у д и ј а,
Зоран Поповић**

ГРАЂАНСКО ПРАВО
ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Слађана Стојановић

Судија Апелационог суда у Нишу

ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ, НЕДОУМИЦЕ И ДИЛЕМЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА У ПАРНИЦАМА ИЗ РАДНИХ ОДНОСА

„Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat, est autem a iustitia appellatum: nam ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi notitiam profiteretur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes. (Ulpianus-D.1,1,1). Сваки онај ко се бави правом, треба прво да зна одакле потиче назив „право“(ius). А оно је названо према правди(iustitia); јер као што је лепо исказао Целзус, право је вештина доброг и правичног. Због тога нас правнике понеко назива и свештеницима (правде). Ми, наиме, служимо правди и посвећујемо се сазнавању шта је добро и правично, одвајајући правично од неправичног, разликујући дозвољено од недозвољеног, желећи да људе учинимо добрим не само због стаха од казни, већ много више тако што ћемо им предочавати предности, усвајајући на тај начин, ако се не варам, истиниту, а не лажну филозофију.¹

Република Србија уређује и обезбеђује између осталог систем у области радних односа, заштите на раду, запошљавања, социјалног осигурања и других облика социјалне сигурности; друге економске и социјалне односе од општег интереса, како је то прописано одредбом члана 97. став 1. тачка 8. Устава РС („Службени гласник РС“ 98/06.), док је одредбом члана 99. став 1. тачка 7., прописано да законе и друге опште акте из надлежности РС доноси Народна скупштина. Закони и други општи акти из надлежности

¹ Ризница правних изрека-стр.118

РС доносе се у поступку који је прописан Уставом и Пословником Народне Скупштине („Службени гласник РС“ 52/10...20/12).

Одредбом члана 1. Закона о раду („Службени гласник РС“ 24/05...95/18), ставом 1., прописано је да се права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, уређују овим законом и посебним законом, у складу са ратификованим међународним конвенцијама. Ставом 2. истог члана прописано је да се права, обавезе и одговорности из радног односа уређују и колективним уговором и уговором о раду, а правилником о раду, односно уговором о раду - само када је то овим законом одређено.

Међусобни однос закона, колективних уговора, правилника о раду и уговора о раду прописан је одредбама члана 8-11 Закона о раду.

„Хијерарсијски поредак свих извора радног права, после ступања на снагу важећег Устава, изгледа овако: 1) Устав и у истој равни са њим – општеприхваћена правила међународног права, 2) потврђени међународни уговори, 3) закон, 4) подзаконски акт, 5) колективни уговор, односно правилник о раду, 6) уговор о раду.

Однос између ових извора успостављају два правила: негативно и позитивно. -Негативно правило одређује да извор права на нижем хијерарсијском нивоу не може садржати одредбе којима се запосленима утврђују мања права или неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени извором права на вишем хијерархијском нивоу. -Позитивно правило одређује да извор права на нижем хијерархијском нивоу може садржати одредбе којима се запосленима утврђују већа права и повољнији услови рада од права и услова који су утврђени извором права на вишем хијерархијском нивоу, као и права која нису утврђена извором права на вишем хијерархијском нивоу, ако извором на вишем хијерархијском нивоу није другачије одређено.

Ова два правила омогућују да закључимо: Извор права на нижем хијерархијском нивоу усклађен је са извором права на вишем хијерархијском нивоу ако је за запослене једнако повољан као он, или ако је од њега повољнији. Извор права на нижем хијерархијском нивоу није усклађен је са извором права на вишем хијерархијском нивоу, ако је за запослене неповољнији од њега, или ако утврђује права и услове које извор на вишем хијерархијском нивоу не допушта.

Неусклађена одредба извора на nižем хијерархијском нивоу се не примењује. Уместо ње примењује се одредба извора на вишем хијерархијском нивоу.

Наведена правила и њихове импликације примењују се на однос између општег колективног уговора, посебног колективног уговора и колективног уговора (односно правилника о раду) код послодавца.²

Приликом доношења закона и других прописа интенција законодавца је да закон буде јасан и као такав применљив у пракси. Истовремено, са доношењем појединих закона, а некада непосредно након тога, доноси се и аутентично тумачење тог закона или појединих одредаба, на начин и у поступку који је прописан одредбама члана 194 и 195 Пословника Народне скупштина, што представља неку врсту помоћи приликом примене закона.

Међутим, закони и прописи су једно а догађаји у пракси су нешто сасвим друго. Као што се у животу не може све унапред да предвиди, тако и законима и законским прописима је просто немогуће да се стриктно регулишу и уреде сви догађаји и ситуације који се јављају у пракси због чега се законски прописи тумаче, а потом примењују. У овом реферату, ја се нећу бавити начинима и методима тумачења права, али желим да укажем на неке правне празнине, недоумице и дилеме које се јављају приликом примене појединих законских прописа а све у циљу отклањања нејасноћа и проналажења најбољег могућег решења у тим случајевима, и од каквог је то значаја.

Па да кренемо.

Примена начела хитности у парницама из радних односа.

Када се ради о поступку у парницама из радних односа мора се имати у виду да се трећи део Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ 72/11...18/20) односи на посебне поступке, и у оквиру тога, одредбама члана 436-441 регулисан је поступак у парницама из радних односа-глава XXIX. Одредбом члана 436. овог закона прописано је да, ако одредбама ове главе није другачије прописано, у парницама из радних односа сходно се примењују остале одредбе овог закона. Дакле, у парницама из радних односа примењују се посебна правила која су прописана одредбама члана 436-441,

² Проф. др. Зоран Ивошевић-Извори и судска заштита права запослених, Зборник радова, Глосаријум 2009- Извори, остваривање и заштита права из радног односа, стр.11. и 12.

а уколико тим одредбама није нешто друго прописано примењују се остале одредбе ЗПП.

Одредбом члана 438.ЗПП прописано је да у поступку и парницама из радних односа, а нарочито приликом одређивања рокова и рочишта суд посебно води рачуна о потреби хитног решавања радних спорова, док је у одредбом члана 440, у складу са начелом хитности прописано да ће суд у пресуди којом налаже извршење неке чинидбе одредити рок од 8 дана за њено извршење, да ако тужени не дође на рочиште за главну расправу, а уредно је позван, суд ће да одржи рочиште и да одлучи на основу утврђеног чињеничног стања, а да ће о последицама изостанка са рочишта за главну расправу из става 1.овог члана, суд упозорити туженог у позиву за рочиште.

Дакле, напред наведеним законским одредбама прокламовано начело хитности у парницама из радних односа, па је очигледно је да је интенција законодавца да се радни спорови окончају у што краћем року

Чланом 299.ЗПП између осталог прописано је да суд може изузетно, у случају ако се ради о поступцима који су хитни, одмах да закаже рочиште и достави тужбу са прилозима, а чланом 302. истог закона прописано је да припремно рочиште није обавезно ако је спор хитан.

Полазећи од напред наведених законских прописа, намеће се питање: Да ли у парницама из радних односа треба достављати тужбу туженом на одговор и заказивати припремно рочиште, и у вези с тим да ли постоји законски основ да се у тим поступцима донесе пресуда због пропуштања(одредба члана 350. ЗПП)?

Имајући у виду досадашњу судску праксу наведено питање се није постављало као спorno, судови и у овим поступцима достављају тужбу туженом на одговор, заказују припремна рочишта, доносе пресуде због пропуштања. Да ли је овакво поступање судова у складу са прокламовним начелом хитности?

Основни и евентуални захтев и фикција о изјављеној жалби.

Одредбом члана 197.став 2.ЗПП прописано је између осталог да тужилац може да истакне у једној тужби, два или више тужбених захтева против истог туженог, ако су ти захтеви у међусобној вези, и то на начин да суд усвоји следећи од тих захтева, ако нађе да претходни захтев није основан.

„Евентуална кумулација је допуштена под одређеним условима. Пре свега, између кумулираних захтева (основног и евентуалног) треба да постоји међусобна веза. Повезаност основног и евентуалног захтева може да буде стварна и правна. Међусобна веза се испољава или у томе што захтеви имају исти чињенични и правни основ, или у томе што су усмерени на остварење идентичног правног или економског циља.“³

Када странка у току поступка, у истој тужби, постави два или више тужбена захтева, који су у међусобној вези, редослед одлучивања о наведеним захтевима одређује сам тужилац. Тужилац уствари један захтев одређује као основни, предлажући да тек ако суд не усвоји тако постављен захтев, усвоји следећи постављени захтева који је у тужби истакнут као наредни односно евентуални. Уколико суд усвоји основни захтев нема основа да одлучује о евентуалном захтеву обзиром да је тужилац остварио жељени циљ и добио тражену правну заштиту.

„Примарни и евентуални тужбени захтев не смеју бити идентични у погледу свог предмета. У ситуацији када тужилац кроз ове захтеве тражи новац, онда су захтеви идентични и нема места постојању примарног и евентуалног тужбеног захтева. (одлука Вишег трговинског суда, Пж.7467/2009).“⁴

„Уколико је закључио да је главни захтев неоснован, суд мора да га изричито одбије као неоснованог јер је то законски услов да одлучује о евентуално истакнутом захтеву. Истом одлуком, којом одбија као неоснован главни захтев, суд одлучује о основаности или неоснованости наредног, евентуалног захтева. Суд мора истовремено да одлучи и о основном и о евентуалном захтеву јер није допуштено раздвојено одлучивање о кумулираним захтевима. Делимична пресуда, пошто се ради о захтевима који се искључују, није допуштена јер би тада могло да дође до противуречних одлука. Осим тога, тужилац је захтевао да суд усвоји само један од више кумулираних захтева.“⁵

3 Др. Гордана Станковић – Фикције о изјављивању жалбе у парничном поступку“ Врховни суд Србије-Билтен судске праксе бр.4/2006 стр.153

4 Коментар Закона о парничном поступку у издању Службеног гласника- проф. др. Невена Петрушић и Драгољуб Симоновић стр.388

5 Др. Гордана Станковић – Фикције о изјављивању жалбе у парничном поступку“ Врховни суд Србије-Билтен судске праксе бр.4/2006 стр.167

У пракси тужиоци напред наведено губе из вида и као основни и евентуални захтев означавају захтеве који су идентични у погледу свог предмета, (нпр. када се тражи исплата новчаног износа по основу неисплаћене зараде, и то у основном захтеву исплата износа обрачунатих према уговору о раду или колективном уговору, а у евентуалном захтеву се тражи исплата мањих износа у висини минималне зараде), а и сами судови врло често о тим захтевима одлучују као о основном и евентуалном захтеву. Поступање на такав начин и одлучивање о постављеним захтевима као о основном и евентуалном, (иако су исти идентични у погледу предмета одлучивања, и евентуални захтев је садржан у основном), у пракси доводи до невероватних ситуација тако да суд ставом првим одбија захтев који је означен као основни, а ставом другим изреке исте пресуде, усваја захтев који је означен као евентуални, а судови очигледно приликом одлучивања губе из вида постојање института литиспенденције.

„У поступку по правном леку поводом одлуке којом је одлучено о евентуално спојеним захтевима постављају се питања која се тичу овлашћења за изјављивање жалбе, обима побијања и граница судског одлучивања. У одредбама ЗПП законодавац није предвидео посебна правила о испитивању жалбе и о одлучивању инстанционог суда уколико настане правна ситуација која ће у наставку овог рада бити изложена.

Специфичност инстанционог поступка поводом жалбе на одлуку којом је одлучено о евентуално спојеним тужбеним захтевима је у томе што је законодавац пропустио да регулише одређене особености карактеристичне за овај поступак. Због тога је суд био стављен у позицију да креира фикције о изјављивању жалбе.“⁶

Ја се не бих сложила са ставом да у случају када је одбијен основни тужбени захтев тужиоца а усвојен евентуални, да тужилац нема право да изјави правни лек јер за то нема правни интерес пошто му је усвајањем једног од његових захтева пружена тражена правна заштита. Наиме, моје мишљење је да на страни тужиоца и у том случају постоји правни интерес за изјављивање жалбе на одлуку којом је одбијен његов основни захтев, и чини ми се да су и судови у својим одлукама изразили такво становиште приликом одлучивања у жалбеном поступку.

⁶ Др. Гордана Станковић – Фикције о изјављивању жалбе у парничном поступку“ Врховни суд Србије-Билтен судске праксе бр.4/2006 стр.167

„Уколико тужени изјави жалбу против одлуке којом се усваја евентуално истакнути захтев, настаје специфична ситуација у којој се срећемо са фикцијом о изјављивању жалбе. Ова специфична ситуација се може тумачити на два начина.

У првом случају, суд је одбио као неоснован основни захтев и усвојио евентуални захтев. Тужени нема правни интерес да изјави жалбу против одлуке којом је суд одбио као неоснован основни захтев јер је у том делу пресуде успео са својим захтевом за пресуду пошто је суд одбио главни захтев. Међутим, тужени може да се жали против одлуке суда о усвајању евентуално истакнутог захтева. Ако тужени изјави жалбу, уколико се примени екстензивно тумачење, може се сматрати да је тужени изјавио жалбу против целе пресуде. У том случају постоји фик-ција да се тужени жалио и против одлуке на коју није могао да изјави ово правно средство.

Кад је тужени изјавио жалбу против одлуке којом је усвојен евентуални захтев, у том случају може да постоји још једна фикција о изјављивању жалбе. Наиме, може да се сматра као да је и тужилац изјавио жалбу против побијане пресуде и то у оном делу у коме је суд одбио као неоснован његов главни захтев. Иако је очигледно да жалбене радње тужиоца нема, у судској пракси се сматра као да је жалба изјављена.

Иако у наведеним случајевима жалба није изјављена јер није предузета жалбена парнична радња којом се напада одређена судска одлука, у пракси се сматра, по природи ствари, да је жалба изјављена.“⁷

Непостојање правног интереса за подношење тужбе и могућност одбацивања тужбе у жалбеном поступку.

Одредбом члана 194. став1. Закона о парничном поступку прописано је да тужилац може у тужби да тражи да суд само утврди постојање, односно непостојање неког права или правног односа, повреду права личности или истинитост, односно неистинитост неке исправе. Према ставу 2 тужба за утврђење може да се поднесе ако тужилац има правни интерес да суд утврди постојање, односно непостојање неког спорног права или правног односа, пре доспелости захтева за чинидбу из истог односа или истинитост односно неистинитост неке исправе, или ако тужилац има неки други правни интерес.

⁷ Др. Гордана Станковић – Фикције о изјављивању жалбе у парничном поступку“ Врховни суд Србије-Билтен судске праксе бр.4/2006 стр.168

Ставом 3.истог члана прописано је да се тужба за утврђење може да се поднесе ради утврђивања постојања, односно непостојања чињенице, ако је то предвиђено законом или другим прописом.

Правни интерес постоји када тужилац има оправдану потребу за пружањем деклараторне заштите, као и у случајевима када је посебним прописима предвиђена могућност тражења деклараторне заштите. Уколико није прописима предвиђена могућност тражења деклараторне заштите тужилачка страна је дужна да правни интерес за подизање деклараторне тужбе учини вероватним, тј. да докаже да постоји опасност да ће тужени својим понашањем повредити неко његово право, и у тим случајевима мора да постоји правни интерес. Правни интерес је процесна претпоставка о којој суд води рачуна по службеној дужности и по приговору странака, у току читавог поступка, све до закључења главне расправе. У случајевима у којима не постоји правни интерес тужиоца за подношење тужбе из члана 194. овог закона, првостепени суд тужбу одбацује на основу члана 294.став1. тачка 6. ЗПП.

Међутим, Закон о парничном поступку не прописује како поступати у случајевима када не постоји правни интерес тужиоца за подношење тужбе, а првостепени суд тужбу није одбацио већ је о таквој тужби одлучивао, и против те одлуке је изјављена жалба. Која су овлашћења другостепеног суда?

У коментару Закона о парничном поступку, с позивом на одлуку Врховног суда Србије, Рев. 4882/97 наведено је да: „Недостатак те процесне претпоставке постаје правно безначајан доношењем пресуде, јер није могао утицати на њену тачност. Другостепени суд, дакле, не може укинути пресуду и одбацити тужбу само због непостојања правног интереса.“⁸ Међутим, судска пракса је у последње време чини ми се заузела јединствени став, који је по мени у оваквој чињеничној и правној ситуацији логичан и правно прихватљив, по коме је другостепени суд у тим случајевима овлашћен да укине првостепену пресуду и тужбу одбаци, с позом на примену одредбе члана 391.став 2. Закона о парничном поступку.⁹

⁸ коментар Закона о парничном поступку у издању Службеног гласника- проф. др. Невена Петрушић и Драгољуб Симоновић стр.375,

⁹ пресуде Апелационог суда у Нишу: Гж 3381-16, Гж1 2971-18;

Постоје ли одредбе Закона о раду, које изазивају недоумице и дилеме у њиховој примени у пракси, и да ли постоје правне празнине у овом закону?

Да кренемо од трошкова превоза запосленог за долазак и одлазак са рада?

Одредбом члана 118. тачка 1. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005,...32/2013), прописано је да запослени има право на накнаду трошкова у складу

са општим актом и уговором о раду за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају. Новелираном одредбом члана 118. ст. 1 тач. 1. Закона о раду (“Службени гласник РС” 75/2014) који је у примени од 29.07.2014. године, прописано је да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз.

Да ли је наведена одредба довољно јасна и разумљива и шта је то што је изазвало вођење многобројних спорова пред судовима за накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запосленог?

Наведеном законском одредбом прописано је још од 2005.године, када је донет Закон о раду, па све до данашњег дана, да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају. Изменама и допунама из 2014.године остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају у складу са општим актом и уговором о раду, могуће је само под условом ако послодавац није обезбедио сопствени превоз.

Дакле, наведена законска одредба 2014.године само је допуњена прописивањем још једног услова за остваривање овог права.

Шта се дешава у судској пракси?

Полазећи од напред наведене законске одредбе, из многобројних пресуда након 2005.године произилази да су судови заузели становиште да запосленом припада накнада трошкова превоза ако је то прописано актом послодавца или уговором о раду, у износу и на начин како је то овим актима прописано. Уколико наведено право није прописано актом

послодавца или уговором о раду, судови су сматрали да се ради о непотпуној правној норми која је садржана у Закону о раду и да се као таква не може непосредно примењивати, и у тим случајевима су захтеви запослених одбијани као неосновани. Накнада трошкова превоза запосленима вршена је само за случају коришћења јавног превоза, и на начин како је то прописано актом послодавца или уговором о раду, и послодавац није имао обавезу да запосленима накнађује трошкове превоза сопственим аутомобилом.¹⁰ У време примене овог става пред судовима спорови за накнаду трошкова превоза били су незнатни и малобројни.

Међутим, иако се наведени законски пропис до 2014.године у овом делу није мењао, а након 2014. за остваривање овог права прописа је још један услов, судска пракса се, на један неприметан начин, потпуно изменила. Према садашњој судској пракси обавеза послодавца да запосленом накнади трошкове превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају прописана је наведеном законском одредбом која се непосредно примењује. Према овом становишту превозном картом у јавном саобраћају сматра се трошак по основу превоза запосленог од места становања до места рада, и самим тим је без значаја да ли је послодавац својим актом или уговором о раду прописао остваривање овог права.

Имајући у виду напред изражен став судске праксе, поставља се питање шта је то што је законом, у погледу остваривања овог права, остављено послодавцу да регулише својим актом или уговором о раду? Да ли то значи да послодавац има овлашћење да својим општим актом или уговором о раду, пропише врсту превозне карте (једнократна – за вожњу у једном правцу, дневна или месечна), као и минималну односно максималну раздаљину од места становања до места рада на којој се накнађују трошкови превоза запосленом, као и обавезу запосленог да се обраћа послодавцу захтевом за исплату трошкова превоза, и како, на који начин и у којој висини се утврђују трошкови превоза који припадају запосленом на релацији на којој нема организованог јавног превоза? Многобројни посебни колективни уговори прописују напред наведено право запосленом, али врло ретко да неко од тих посебних колективних уговора садржи ближе услове и критеријуме под којима запослени ово право може да оствари.

¹⁰ Коментар Закона о раду Остоје Милосављевића и Жељка Албаназе - 2.издање Пословног бироа 2005 Београд: Бирографија, страна 167.

Судови су приликом одлучивања пошли од тога да остваривање овог права закон ни на који начин не условљава-у смислу раздаљине од места рада до места становања, а да је за оцену основаности захтева релевантна чињеница удаљеност места становања од места рада која доводи запосленог у ситуацију да му је превоз до посла и натраг реална и објективна потреба, као и присутност запосленог на раду. Одговор на питање која је то најмања раздаљина која указује да постоји реална потреба за коришћењем превоза потражила је судска пракса, која је на жалост променљива категорија. Наиме, појавом напред наведених спорова судска пракса је заузела став да у случају ако је удаљеност места становања од места рада 500 метара и више, постоји реална потреба за коришћењем превоза на страни запосленог и послодавац је обавезиван да накнади трошкове превоза запосленом на тој удаљености. Временом се судска пракса променила, и сада је став да наведена удаљеност мора бити већа, односно најмање 700-800 метра, па се у случају мање удаљености захтеви запослених одбијају као неосновани. Измењена судска пракса по овом питању итекако утиче на правну стабилност, имајући у виду да су трошкови превоза појединим запосленим лицима којима је место рада удаљено 500-700 метара од места становања за један период признати, док су тим истим запосленима, иако није дошло до промене места рада и места становања, за период након тога захтеви одбијени као неосновани. Понекад и здравствено стање запосленог може да утиче да и на мањој раздаљини постоји реална потреба на страни запосленог за коришћењем превоза ради доласка и одласка с посла. Трошкови превоза се признају у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, и наведени трошкови припадају запосленом у периоду у коме је запослени фактички долазио на посао и радио на свом радном месту, али не у случају ако је рад обављао од куће јер у том случају нема трошкова превоза.

Према садашњој судској пракси на остваривање овог права без значаја је чињеница ако је послодавац својим општим актом, као услов за остваривање наведеног права прописао подношење захтева, или пружање доказа доказа да је запослени стварно сносио трошкове превоза у смислу достављања карата или потврде од стране овлашћеног превозника на тој релацији.¹¹

Међутим, судска пракса још-увек није дала одговор на питање да ли је послодавац овлашћен да својим актом пропише максималну удаљеност на

11 Одлука Врховног касационог суда Рев2 1756/2018 од 05.09.2018.године

којој запосленима накнађује трошкове превоза? Приликом тражења одговора на ово питање треба поћи од тога да ова удаљеност мора представљати разумну раздаљину коју запослени може да пређе ради благовременог доласка и одласка с посла и при-том очува своју радну способност.

Није довољно јасан ни појам „сопственог превоза“. Да ли се под наведеним појмом подразумева искључиво превоз који организује послодавац, и њиме се могу превозити само запослени код тог послодавца, или се под тим појмом подразумева и превоз који организује послодавац за своје запослене, закључењем одређеног уговора и ангажовањем овлашћеног ауто-превозника на свом подручју и о томе обавести своје запослене, без обзира што се тим превозом могу превозити и друга лица.

Указујем да је један од Градова на територији РС пошао од тога да је према Законом о основама система образовања и васпитања прописана обавеза јединице локалне самоуправе, да у буџету обезбеђују средства за превоз запослених као оснивачи школских установа на свом подручју, и закључио је уговор са овлашћеним ауто-превозником којим је предвиђено да тај ауто-превозник између осталих неће наплаћивати карте ђацима и особљу школа, за време важења тог уговора. О томе су обавештене поједине школске установе на територији тог града, и поједине школе о томе су обавестиле своје запослене и у једном периоду им делиле картице за бесплатан јавни превоз, с тим што нема доказа да су сви запослени преузели те картице. Након тога поднете су тужбе од стране запослених у школама на територији тог града ради исплате трошкова превоза. Прво и основно питање на које су судови потражили одговор је: да ли су локалне самоуправе овлашћене да организују превоз тих запослених, да ли је потребно да се са тим сагласи надлежна школска установа, те да ли се такав превоз може сматрати „сопственим превозом“.

Полазећи од тога, да је послодавац запосленима у наведеним случајевима одређена школска установа на територији тог града, судови су закључили да се наведени превоз ни у ком случају не може сматрати „сопственим превозом“ који обезбеђује послодавац, и да уколико нема изричите сагласности запосленог за коришћењем таквог превоза, која се може испољити и у виду преузимања кртице за коришћење истог, запосленом припада право на накнаду трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају. У оваквој чињеничној и правној ситуацији чини ми се да је напред изражен став суда једино могућ и логичан, у прилог чега иде и чињеница да наведени

превоз није организован искључиво и само за запослене у школама на територији тог града.

На основу напред наведеног сами закључите од каквог и коликог значаја може бити одлука о начину организовања превоза запослених, јер суд у том граду оптерећују многобројни спорови у којима запослени траже накнаду трошкова превоза од одређене школе -а свог послодавца. Међутим, судски поступци се ту не завршавају, против одлука првостепеног суда изјављују се жалбе, тако да осим трошкова првостепеног поступка настају трошкови и другостепеног поступка. У овим споровима тужиоце по неписаном правилу заступају адвокати, док тужене школе заступа Градски Правобранилац тог града. Дакле, да су законски прописи били мало јаснији и прецизнији када је у питању могућност организовања „сопственог превоза“ од стране послодавца за своје запослене, не би дошло до масовне појаве наведених спорова и изазивања трошкова поступка, а смањила би се и оптерећеност судова и Градског Правобраниоца тог града.

Право на накнаду штете по основу неискоришћеног годишњег одмора у случају престанка радног односа.

Одредбом члана 71. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), прописана је дужност послодавца да у случају престанка радног односа запосленом изда потврду о неискоришћеном броју дана годишњег одмора, док је одредбом члана 76. тог истог закона прописано да ако кривицом послодавца запослени не користи годишњи одмор, има право на накнаду штете у висини просечне зараде у претходна три месеца, утврђене општим актом и уговором о раду. Изменама и допунама Закона о раду (“Службени гласник РС“ 75/2014), који је у примени од 29.07.2014. године, брисан је напред наведени члан 71. а новелираном одредбом члана 76. став 1. прописана је дужност послодавца да у случају престанка радног односа запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду, уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора, док је ставом 2. истог члана је прописано да ова накнада има карактер накнаде штете.

И за период примене Закона о раду пре наведених измена и допуна из 2014.године, вођени су спорови за накнаду штете због неискоришћеног годишњег одмора, па и у случају престанка радног односа запосленом ако

кривицом послодавца запослени није искористио годишњи одмор. Дакле, у том периоду, постојање кривице због неискоришћеног годишњег одмора био је услов за накнаду штете по овом основу, како је то и закон прописивао. Међутим, након тога, имајући у виду напред наведене измене и допуне, судови су у многобројним одлукама заузели став и изразили мишљење да кривица послодавца није од значаја за остварење овог права запосленог. Наиме, судови су пошли од тога да је одредбом члана 60.став 4 Устава РС прописано да свако има право између осталог на плаћени годишњи одмор и да се тог права не може одрећи. Самим тим, обзиром на карактер права на годишњи одмор, да се истог запослени не може одрећи, нити му се то право може ускратити, то запосленом за дане неискоришћеног годишњег одмора припада накнада у висини која се обрачунава на начин који је прописан одредбом члана 76.Закона о раду.

Имајући у виду напред наведене одредбе Закона о раду након измена и допуна из 2014.године, полазећи од тога која је била интенција законодавца приликом измена Закона о раду из 2014.године, може се поставити питање: Да ли је напред наведени став суда прихватљив и логичан?- односно да ли је за накнаду штете по овом основу, без значаја питање кривице због чега запослени није искористио припадајуће дане годишњег одмора до момента престанка радног односа?

Од када тече право запосленог на камату на неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа у случају престанка радног односа?

Одредбом члана 186. наведеног закона прописано је да је послодавац дужан да запосленом, у случају престанка радног односа, исплати све неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа у складу са општим актом и уговором о раду. Исплату обавеза из става 1. овог члана, послодавац је дужан да изврши најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа.

У појединим случајевима, када се ради о накнади штете због неискоришћеног годишњег одмора судови су с позивом на члан 186 Закона о раду изразили став да то потраживање доспева у року од 30 дана од дана престанка радног односа.¹²

12 Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 1. 1076-19 од 21.01.2020. године

Наведени став може бити прихватљив и логичан у случају ако се ради о праву на годишњи одмор који би запослени могао да користи и у периоду након престанка радног односа да није дошло до престанка радног односа. Међутим, да ли се овакав став може прихватити у случају ако је рок у коме је запослени могао да користи годишњи одмор истекао пре престанка радног односа; и шта у случају ако је запослени у периоду за који тражи накнаду штете био радно ангажован по основу већег броја уговора о раду на одређено време, са или без прекида у смислу одредаба Закона о раду?

Тражећи одговор на ово питање мора се имати у виду да, када су у питању неисплаћене зараде, судови су пошли од одредбе члана 110. став 1. Закона о раду и заузели став да је одредбом члана 186. Закона о раду, дата могућност послодавцу да запосленом у случају престанка радног односа исплати остварену а неисплаћену зараду, накнаду зараде и друга примања, најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа, али да ова одредба не утиче на доспелост остварених, а неисплаћених потраживања, наводећи да новчана потраживања из радног односа доспевају до дана престанка радног односа, у зависности од основа потраживања, у складу са законом и општим актом. Према овом становишту потраживање зараде доспева у року који прописује Закон о раду у члану 110. став 1., а право на исплату регреса за коришћење годишњег одмора истеком године на у којој се стиче право на коришћење годишњег одмора и годишњи одмор користи.¹³

Дакле, наведено питање је наизглед безначајно, али ако се у судској пракси заузме различито становиште од када тече право на исплату законске затезне камате када се ради о исплати напред наведених потраживања, то наведени пропуст законодавца може и те како да утиче на правну стабилност и повреду права на правично суђење.

Одредбом члана 191. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005,... 75/2014), прописане су правне последице незаконитог престанка радног односа.

Ставом 1., 2., 3., и 4 прописано је право запосленог у случају када суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног основа, ако запослени тражи да се врати на рад, и накнаду штете, поред враћања на рад запослени има право и на накнаду штете која се утврђује се у

13 Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.1. 1583-20 од 23.07.2020. године

висини изгубљене зараде која у себи садржи припадајући порез и доприносе у складу са законом, у коју не улази накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, бонуси, награде и друга примања по основу доприноса пословном успеху послодавца.

Ставом 2 напред наведеног члана је прописано шта не улази у накнаду штете, па се може поставити питање: **Да ли приликом досуђивања накнаде штете у виду изгубљене зараде треба урачунавати и теренски додатак, као и додатак по основу ноћног и сменског рада?**

Чињеница је да напред наведеном законском одредбом из накнаде штете није искључена зарада по основу теренског додатка, нити увећање зараде по основу ноћног и сменског рада, и ако се иде том логиком приликом досуђивања накнаде штете запосленом у тај износ треба урачунати и износ по основу теренског додатка, као и увећање по основу сменског и ноћног рада а које је остварио упоредни радник. Колико је мени познато за сада судска пракса поступа на напред наведени начин.

Међутим, чини ми се да приликом одлучивања треба поћи од самог смисла и појма института теренског рада те да се теренски додатак исплаћује запосленом из разлога што се рад обавља на терену, као и да се зарада запосленом увећава по основу ноћног и сменског рада када се рад обавља ноћу, односно по сменама. Дакле, наведена увећања запосленом припадају због додатних напора запосленог јер се рад реализује под одређеним додатним околностима тј. на терену, ноћу или по сменама. У случају накнаде штете запосленом нема тог додатног напора, самим тим, према другом схватању, ни основа да му се у износ штете урачуна и накнада по основу теренског, ноћног и сменског рада, иако ова увећања наведеним ставом нису изричито искључена.

Ставом 5. истог члана прописано је право запосленог у случају када суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног основа а запослени не захтева да се врати на рад, суд ће, на захтев запосленог, обавезати послодавца да запосленом исплати накнаду штете у износу од највише 18 зарада запосленог, у зависности од временаведеног у радном односу код послодавца, година живота запосленог и броја издржаваних чланова породице. Ставом 6. истог члана прописано је да ако суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног основа, али у току поступка послодавац докаже да постоје околности које оправдано

указују да наставак радног односа, уз уважавање свих околности и интереса обе стране у спору, није могућ, суд ће одбити захтев запосленог за враћање на рад, и досудиће накнаду штете до износа који је прописан тим ставом; док је ставом 7. прописано да ако суд у току поступка утврди да је постојао основ за престанак радног односа, али да је послодавац поступио супротно одредбама закона којима је прописан поступак за престанак радног односа, суд ће одбити захтев запосленог за враћање на рад, досудиће накнаду штете до износа који је прописан тим ставом. Ставом 8. и 9. истог члана прописано је да се под зарадом из ст. 5. и 7. овог члана сматра се зарада коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме му је престао радни однос. Накнада из ст. 1, 5, 6. и 7. овог члана умањује се за износ прихода које је запослени остварио по основу рада, по престанку радног односа.

Имајући у виду напред наведену законску одредбу у пракси се појавило питање: Да ли захтев запосленог за враћање на рад у случају из става 6., и 7 овог члана у себи садржи и захтев за накнаду штете? Какав је карактер штете која се досуђује применом става 5.,6., и 7. - да ли се ради о материјалној или нематеријалној штети? Од када тече право на камату на износ штете досуђен применом става 5.,6., и 7. наведеног члана?

Полазећи од тога да је напред наведеним законским одредбама дато овлашћење суду да, у случају када утврди да постоје околности прописане тим ставовима и због тога одбије захтев запосленог за враћање на рад, да запосленом досуди накнаду штете, чини ми се да захтев запосленог за враћање на рад, у случају из става 6., и 7., овог члана, у себи садржи и захтев за накнаду штете, и самим тим не постоји обавеза на страни тужиоца да тај захтев истакне у тужби да би суд о њему одлучивао.

Накнада штете у случајевима из става 5.,6., и 7., наведеног члана утврђује се у износу до 18, односно 36 или 6 зарада запосленог, како је то прописано тим ставовима, у зависности од временаведеног у радном односу код послодавца, година живота запосленог, и броја издржаваних чланова породице. Под зарадом се сматра зарада коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме је запосленом престао радни однос, како је то прописано ставом 8., истог члана, и иста се умањује за износ прихода који је запослени остварио на основу рада по престанку радног односа. На први поглед потпуно је јасно како се утврђује износ штете који се запосленом

досуђује у наведеним случајевима. Међутим, у пракси су се појавила нека спорна питања у вези с тим.

Наиме, ако прихватимо становиште да захтев запосленог за враћање на рад у случајевима из става 6., и 7., садржи и захтев за накнаду штете, а током поступка ни тужилац ни тужени нису доставили доказе у погледу времена које је запослени провео у радном односу код послодавца, година живота запосленог и броја издржаваних чланова породице, нити износ зараде коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме је запосленом престао радни однос, поставља се питање: Како ће суд да утврди износ штете који припада запосленом уместо враћања на рад? Ако се имају у виду одредбе члана 228-233 ЗПП, чини ми се да суд у овом случају износ штете може једино да утврди по слободној оцени применом члана 232.ЗПП, имајући у виду све околности случаја које утичу на висину досуђеног износа, полазећи од принципа правичности. Приликом одређивање износа штете у таквом случају, када недостају подаци о износу зараде коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу у коме је запосленом престао радни однос, можда суд може као параметар да узме износ минималне зараде или просечне зараде на територији РС према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику за месец који претходи месецу у коме је запосленом престао радни однос, и у том случају на страни суда постоји обавеза да своју одлуку у том делу посебно образложи како би на тај начин била искључена произвољност суда.

Као спорно је и питање карактера штете која се досуђује применом члана 191.став 5.,6., и 7. Закона о раду?- да ли се ради о материјалној или нематеријалној штети?

Према преовладајућем схватању у наведеном случају ради се о накнади материјалне штете, која се утврђује на начин како је прописано напред наведеним законским одредбама, и запосленом на досуђени износ штете припада право на камату од дана престанка радног односа до исплате.

Постоји и друго мишљење које је по мени логичније и прихватљивије. По овом мишљењу штета која се запосленом досуђује на основу члана 191. став1. има карактер материјалне штете, међутим чини ми се да је штета која се досуђује на основу става 5.,6., и 7 истог члана потпуно други вид штете јер се иста се исплаћује због губитка или престанка права на рад, и као таква има карактер нематеријалне штете јер представља вид сатисфакције

запосленом због губитка или престанка права на рад код послодавца, као једног личног права, и на досуђени износ штете запосленом припада камата од дана пресуђења до исплате, јер се на тај дан применом члана 200 ЗОО одређује износ припадајуће штете.

Која су овлашћења суда у поступку оцене законитости решења о престанку радног односа применом члана 179. став 1. тачка 3. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), односно на основу члана 179. став 3. тачка 8. истог закона након измена и допуна („Службени гласник РС“ 75/14)? У пракси се појавило као спорно питање да ли је суд овлашћен да уместо отказа уговора о раду запосленом изрекне неку од прописаних блажих мера?

Одредбом члана 179. став 1. тачка 3. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) прописано је да послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдан разлог, који се односи на радну способност запосленог, његово понашање и потребе послодавца и то ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца. Одредбом члана 180. став 3. тог закона прописао је да ако постоје олакшавајуће околности или ако природа повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине није довољан разлог за отказ уговора о раду, послодавац може у упозорењу да запосленог обавести да ће му отказати уговор о раду ако поново учини исту или сличну повреду, без поновног упозорења. Чланом 170. истог закона прописано је да се у том случају запосленом може уместо отказа изрећи и мера привременог удаљења са рада у трајању до три дана без накнаде зараде. Након измена и допуна Закона о раду („Службени гласник РС“ 75/14), одредбом члана 179. став 3. тачка 8. прописано је да послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца. Међутим, одредбом члана 179. а истог закона прописано је да послодавац запосленом може за повреду радне обавезе или непоштовања радне дисциплине у смислу члана 179. став 2. и 3. овог закона, ако сматра да постоје олакшавајуће околности, или да повреде радне обавезе односно непоштовање радне дисциплине, није такве природе да запосленом треба да престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, изрекне: 1. привремено удаљење са рада без накнаде зараде у трајању до 15 радних дана; 2. или

новчану казну у висини од 20% основне зараде запосленог за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању од три месеца; 3. или опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења ако у наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовања радне дисциплине.

У судској пракси су се појавила **два различита схватања**.

Прво схватање, полазећи од напред наведених законских прописа, закључује да не постоји правило да се код сваке повреде радне дисциплине отказује уговор о раду, и да се уговор о раду отказује само у случају ако се понашање запосленог не може толерисати јер је исто по разумној оцени неподношљиво, а послодавац приликом одлучивања мора имати у виду околности конкретног случаја, јер свака повреда не мора бити санкционисана најтежом дисциплинском санкцијом. У зависности од тога да ли се ради о лакшој или тежој повреди радне дисциплине, послодавац ће да одлучи да ли ће отказати уговор о раду или ће запосленом да изрекне неку блажу санкцију. У поступку испитивања законитости одлуке о престанку радног односа у овим случајевима суд није овлашћен да уместо отказа запосленом изрекне неку од блажих мера, али је овлашћен да цени ли је повреда радне дисциплине која се запосленом ставља на терет такве природе да запосленом треба да престане радни однос, а све у зависности од тога да ли се понашање запосленог може или не може толерисати јер је исто по разумној оцени неподношљиво.¹⁴

По другом схватању, напред наведеним законским прописима остављено је послодавцу да сам бира да ли ће због учињене повреде запосленом отказати уговор о раду или ће изрећи блажу меру, и суд није овлашћен да испитује да ли се ради о повреди за коју је послодавац могао да изрекне и блажу меру уместо отказа уговора о раду. Ако се послодавац одлучи за отказ, суд само цени да ли постоји повреда.

У пракси се као спорно питање појавило: Да ли поводом истог чињеничног догађаја, услед различите правне квалификације, запослени може два пута да одговара, те да ли послодавац има право да запосленом, услед различите правне квалификације једног те истог догађаја, изрекне две потпуно различите мере?

¹⁴ пресуде Врховног касационог суда: Рев.2. 105/2015 од 02.12.2015. године ; Рев.2. 2200/2018 од 23.11. 2018. године ;

Одредбом члана 179. ст. 1. тач. 4. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), као оправдан разлог за отказ уговора о раду прописан је ако је запослени учини кривично дело на раду или у вези са радом, односно након измена и допуна Закона о раду („Службени гласник РС“ 75/14), чланом 179. став 1. тачка 2. као оправдан разлог за отказ уговора о раду прописано је ако је запослени правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом. Овај разлог за престанак радног односа везан је за учињено кривично дело на раду или у вези са радом, а након измена наведених измена и допуна за употребу овог отказног разлога мора да постоји правноснажна кривична пресуда којом је запослени осуђен за кривично дело на раду и у вези са радом. Дакле, Закон о раду пре наведених измена и допуна није прописивао постојање правноснажне кривичне пресуде, али је судска пракса заузела став да за употребу овог отказног разлога мора да постоји правноснажна кривична пресуда, па је очигледно изменама и допунама, дотадашњи став судске праксе прихваћен од стране законодавца. Поводом једног догађаја запосленом се може утврђивати одговорност за повреду радне обавезе код послодавца, а може одговарати и за кривично, уколико су се за то стекли услови, и то су две потпуно одвојене врсте одговорности. Кад наступи овај отказни разлог уговор о раду се може отказати без обзира на врсту казне која је у кривичном поступку изречена за то дело.

Међутим, шта се дешава уколико је учињену повреду послодавац квалификовао као повреду радне дисциплине, и запосленом изрекао новчану казну, а након тога, пошто је против запосленог због тог истог догађаја покренут и вођен и кривични поступак, и у том поступку запослени је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом, да ли сада послодавац, с позивом на ову пресуду и повреду, запосленом може да откаже уговор о раду?

Да би смо добили одговор одговор на ово питање да ли треба поћи од одредбе члана 34. став 4. Устав РС којим је прописано да нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, нити судска одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном правном леку. Истим забранама подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело.

Имајући у виду напред наведену одредбу Устава, као и да Закон о раду ни једном одредбом не предвиђа могућност да послодавац може поводом истог чињеничног догађаја, више пута одлучивати и кажњавати запосленог, па ни у случају када тај догађај различито квалификује, у појединим пресудама суд је заузео став да у случају када је запосленом за учињену повреду радне обавезе послодавац већ изрекао новчану казну, нема законског основа да послодавац запосленом поново, поводом истог догађаја, и на основу истог чињеничног стања изриче било коју другу меру, а самим тим ни отказ Уговора о раду. Дакле, према овом схватању, поводом једног догађаја запослени не може два пута одговарати за повреду радне обавезе код послодавца, без обзира на правну квалификацију.¹⁵

Међутим, има и схватања које полази од тога да се ради о повредама које су различито правно квалификоване, па је без значаја је чињенице што су те повреде квалификоване на основу истог чињеничног стања.

У споровима из радних односа осим Закона о раду примењују се и многобројни други закони. Да видимо да ли у судској пракси постоје недоумице и дилеме у примени тих прописа?

Да кренемо од тога да ли је и од каквог значаја на остваривање права на накнаду штете због незаконитог рада органа у поступку пред редовним судом, ако запослени није водио управни спор против одлуке којом је одлучивано о његовим правима и дужностима, када је то законом прописано?

Законом о државним службеницима, (“Службени гласник РС”, бр. 79/2005, ...95/2018), у члану 140. став1. прописано је да о правима и дужностима државног службеника одлучује руководилац решењем, ако овим или другим законом или другим прописом није другачије одређено. При одлучивању о правима и дужностима државног службеника примењује се закон којим се уређује општи управни поступак, изузев код одлучивања о одговорности за штету. Одредбом члана 142. истог закона прописано је да жалбене комисије одлучују о жалбама државних службеника на решења којима се у управном поступку одлучује о правима и дужностима, да жалбене комисије примењују закон којим се уређује општи управни поступак. Жалбена комисија је дужна да одлучи у року од 30 дана од дана њеног пријема ако овим законом није

15 пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.1. бр.263/19 од 12.05.2020. године

другачије одређено, иначе се сматра да је жалба одбијена. Против одлуке жалбене комисије може да се покрене управни спор, што је прописано у чланом 143. овог закона.

Када се државни службеник руководиоцу обрати са захтевом за остваривањем неког права, и његов захтев буде одбијен, а након тога жалба запосленог изјављена против тог решења од стране жалбене комисије буде одбијена, и запосленом дата правна поука да је то решење коначно у управном поступку и да против њега није дозвољена жалба али да се исто може оспоравати тужбом у управном спору, а запослени не покрене нити води спор пред Управним судом, да ли има основа да у поступку пред редовним судом, по основу накнаде штете, одговора послодавац због неправилног и незаконитог рада послодавца, а на основу члана 172. Закона о облигационим односима?

На основу многобројних судских одлука може се закључити да су судови по овом питању чини ми се заузели јединствен став да се ради о спору из судске надлежности, и да постоји основ за одговорност послодавца по основу накнаде штете због незаконитог и неправилног рада, с позивом на члан 172. Закона о облигационим односима. Имајући у виду напред наведени став судске праксе намеће се питање: од каквог је значаја напред наведена одредба члана 140. став 1. Закона о државним службеницима?

Када је послодавац правно лице чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које се искључиво или претежно финансира кроз уступљене јавне приходе или из републичког буџета односно буџета Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, да ли за обавезе настале према запосленом одговара оснивач и када?

Одредбом члана 414., ставом 1. ЗОО прописано је да сваки дужник солидарне обавезе одговара повериоцу за целу обавезу и поверилац може захтевати њено испуњење од кога хоће све док не буде потпуно испуњена, али кад један дужник испуни обавезу, она престаје и сви се дужници ослобађају. Ставом 2. истог члана прописано је да од више солидарних дужника, сваки може дуговати са другим роком испуњења, под другим условима и уопште са различитим одступањима.

Према одредби чланом 14. став1. Закона о стечају („Сл. Гласник РС“, бр.104/09 и 95/18), стечајни поступак се не спроводи, поред осталих правних

лица наведених у тој одредби, ни према правним лицима чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе која се искључиво или претежно финансирају кроз уступљене јавне приходе или из Републичког буџета односно буџета Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. Према ставу 3. истог члана за обавезе правног лица, над којима се у складу са став1. овог члана не спроводи стечајни поступак солидарно одговарају његови оснивачи односно власници као чланови или акционари.

Дакле, наведеном законском одредбом је установљена солидарна одговорност оснивача правних лица над којим се у складу са одредбом члана 14.став 1. Закона о стечају не спроводи стечајни поступак.

Закону о стечају је специјални закон којим се уређује услови и начин покретања и спровођења стечаја над правним лицима али је тим законом установљена одговорност оснивача правних лица над којим се, у складу са одредбом члана 14.став 1. Закона о стечају, не спроводи стечајни поступак. Да би се у овим случајевима активирала одговорност оснивача потребно је да су испуњени следећи услови: 1. да се ради о правном лицу чији је оснивач Република Србија, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе; 2. да се то правно лице искључиво или претежно финансира из буџета.

Међутим, према становишту судске праксе, сама чињеница да је рачун основаног субјекта над којим се не спроводи стечај дужи период у блокади не доводи аутоматски до примене наведене одредбе Закона о стечају, односно одговорности оснивача. Наиме, осим напред наведених услова, потребно је и да запослени у извршном поступку не може да наплати своје потраживање јер је наступио један од разлога прописан одредбом члана 129. став1. тачка 4. и 6. Закона о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/15 ..., 9/20), односно ако странка која је правно лице престала да постоји, а нема правног следбеника, или ако је извршење постало немогуће или не може да се спроведе из других разлога (пропао је предмет извршења, извршни дужник нема имовину и сл.), у ком случају се по службеној дужности обуставља извршни поступак.¹⁶

16 пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1. 2136-17 од 22.03.2018. године

Одредбом члана 167. Закона о стечају прописане су правне последице потврђивање плана реорганизације, између осталог да се подonoшењу решења о потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене планом реорганизације, уређују искључиво према условима из плана и да усвојен план реорганизације представља извршну исправу. По изричитој одредби тог члана, доношењем решења о потврђивању усвајања плана реорганизације престају све последице отварања стечајног поступка, а према ставу 5. тог члана изједначени су повериоци који су обухваћени усвојеним планом реорганизације, са оним повериоцима чија су потраживања настала пре усвајања плана, а који нису обухваћени планом. Одредбом члана 156. став 1. тачком 15 прописано је да план реорганизације, садржи рок спровођења плана који не може бити дужи од пет година. Непоступање по усвојеном плану, представља разлог за покретање стечајног поступка у смислу одредбе члана 173. Закона о стечају и спровођењу стечајног поступка банкротством стечајног дужника.

Дакле, у ситуацији када је усвојен план реорганизације стечајног дужника и стечајни поступак обустављен, поверилачева потраживања која су доспела до усвајања плана, могу се намирити само у складу са планом реорганизације, а у случају да није поднета пријава потраживања у поступку стечаја, може се захтевати утврђење постојања потраживања која су настала до доношења плана реорганизације, под условима одређеним планом реорганизације, односно само у складу са условима одређеним за испуњењем потраживања поверилаца исте класе у коју би се то потраживање могло сврстати.

Међутим, у пракси се као спорно поставило питање шта са потраживањима која су настала после доношења одлуке суда о усвајања плана реорганизације, али у року који је одређен за спровођење истог? - да ли се та и та потраживања намирају у складу са планом реорганизације, као и потраживања поверилаца која су доспела до усвајања плана реорганизације?

Поводом овог питања у судској пракси постоје два потпуно различита схватања.

Прво схватање полази од тога да је циљ реорганизације наставак привредне активности и очување правног субјективитета, као и од одредбе члана 21. став 1. Устава РС којом је прописно да су пред Уставом и законом

сви једнаки. Према овом схватању, повериоци чија су потраживањима настала после доношења одлуке суда о усвајања плана реорганизације, али у периоду који је одређен за спровођење истог, нису лишени могућности намирења свог потраживања, али само под условима одређеним планом реорганизације, односно само у складу са условима одређеним за испуњење потраживања поверилаца исте класе у коју би се то потраживање могло сврстати.

Према другом становишту усвојени план реорганизације представља оквир за утврђивање односа парничних странака, то је нови уговор о регулисању обавеза између стечајног повериоца и дужника, али само за временски период до тренутка ступања на правну снагу истог. Правноснажношћу плана реорганизације тужени излази из посебног статуса који је имао од тренутка отварања стечајног поступка и наставља нормално да послује, и самим тим је у обавези да запосленима исплати сва потраживања настала по основу рада настала након тога, па и она која су настала у време спровођења плана реорганизације.

У судској пракси се појавио институт „радно неангажованих радника“, који не познаје Закон о раду, а ни остали законски прописи који су у примени.

Да би судови могли да одлучују о правима радно неангажованих радника, мора се поћи од тога како је настао појам „радно неангажованих радника“ и која се то лица подразумевају под овим појмом?

Услед ратних дешавања на подручју КИМ 1999. године наступиле су промене у виду принудног измештања појединих установа и институција из свог седишта тако да је један број запослених наставио је са радом у објектима изграђеним средствима УМНИК-а на простору КИМ (Грачаница и Лапље Село), док је један број запослених радно ангажован у другим установама и институцијама на територији КИМ, као и ван КИМ, а један број запослених је остао нераспоређен.

Влада РС -Кабинет копредседника Комитета за сарадњу са Цивилном мисијом УН донео је Закључак 03.бр.80/16 од 25.01.2000 године, којим је прецизирано да сви запослени у државним органима, органима локалне самоуправе, јавним предузећима чији је оснивач РС и установама у области здравља, просвете и другим јавним службама са подручја АП КИМ, задржавају статус запослених у тим органима, предузећима и установама и одлучено да запосленима који не раде припада плата од 80% од плате која би

им припала да раде а живе ван територије КИМ, односно у висини од 100% од плате која би им припала да раде-који су остали да живе на територији КИМ. Након тога Влада је Закључком 05 број 02-4586/2003-001 од 17.јула 2003. године, као и Закључком 05 бр.120-335/2007 увећавала наведену накнаду запосленима који нису били радно ангажовани.

Дакле, радно неангажовани радници су лица, која су задржала статус запослених у наведеним органима, предузећима и установама, иако не раде, и исплаћивана им накнада на основу напред наведених Закључака.

У споровима у којима се у својству тужиоца појављују радно неангажовани радници, као предмет спора јавља се исплата јубиларне награде, накнада штете у виду разлике између накнаде која им је исплаћивана на основу напред наведених закључака и зараде коју би остварили да су радили, и судови су у тим споровима заузели становиште да нема основа за исплату јубиларне награде у ситуацији када запослени дуги низ година не ради јер се јубиларна награда исплаћује за године рада у радном односу, нити постоји основ за исплату тражене разлике између исплаћене накнаде и зараде која би им припала да су радили.

Обзиром да су у току 2015.године, на препоруку Владе РС, отказани уговори о раду запосленима који нису радно ангажовани, а самим тим и престанка радног односа уз исплату отпремнине, уз образложење да за радом тог лица не постоји потреба услед смањења посла и промене организације рада, појавили су се и спорови са захтевом за поништај тих решења, али и спорови у којима се тражи исплата разлике у отпремнини.

Према израженом мишљењу садржаном у појединим одлукама другостепеног суда, судови у овим случајевима приликом одлучивања морају поћи од тога од када запослени има статус „радно неангажованог радника“, и када је за такав статус сазнао, те да ли је у складу са тада важећим прописима покретао поступак пред судом за поништај тог статуса или се са тим статусом сагласио, и уколико се са наведеним статусом запослени сагласио да ли је у том случају за радом запосленог престала потреба већ дуги низ година, а самим тим да ли тај статус сам по себи искључује примену било ког критеријума за утврђивање технолошког вишка, јер се исти може изједначити са статусом технолошког вишка.

У пракси се често појављује недоумица и одговор на питање: **Како поступати у ситуацији када постоји разлика у тумачењу и примени прописа између Врховног касационог суда и Уставног суда?**

Указаћу само на поједине одредбе Устава, а одговор на ово питање потражите сами.

Одредбом члана 4.Устава РС прокламована је подела власти на законодавну, извршну и судску, и да се њихов однос заснива на равнотежи и међусобној контроли, као и да је судска власт независна, док је одредбом члана 166. прописано да је Уставни суд самосталан и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе. Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће. Устав у члану 168.став 3.прописује да Закон или други општи акт који није сагласан Уставу или закону престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда у службеном гласилу, док је чланом 171.став1. прописано да је свако је дужан да поштује и извршава одлуку Уставног суда.

И да завршим.

Ја сам у овом реферату приказала и указала само на поједине правне празнине и недоумице и дилеме које се јављају у судској пракси приликом примене законских прописа. Судије у споровима из радних односа, осим Закона о раду, примењују сијасет других закона, подзаконских прописа, колективних уговора и уговоре о раду, и морају да располажу изузетним знањем и вештином да одређени законски пропис примене на конкретан случај и на дато чињенично стање, водећи рачуна да се тумачење закона и његова примена у пракси и у конкретном случају не претвори у произвољност и самовољу. Наиме, уколико не постоји законска одредба коју треба применити на конкретан случај-односно постоји правна празнина, или ако законска одредба коју треба применити није довољно јасна, тада на сцену ступа судска пракса. Уколико судска пракса није јединствена, то може довести до неједнаког поступања судова у истој чињеничној и правној ситуацији и до повреде права на правично суђење, а у ситуацијама када се мења дугогодишња судска пракса, иако није дошло до измене законских прописа, то може да доведе не само до правне несигурности већ и до

појаве огромног броја предмета што додатно утиче на оптерећења судова, али и на стварање огромних трошкова поступка који и те како у појединим случајевима могу да оптерете буџет.

Дана 07.09.2020. године

У Нишу

Intentio inservire debet legibus, non legis intentioni. **Циљ треба подчинити законима, а не законе циљу.**“ - Ризница правних изрека-стр.27.

„Садашњост испашта грешке прошлости и чини нове које ће будућност понети на својим плећима“ - М. Настасијевић - Ризница правних изрека-стр.26

Милица Златковић,
судија Апелационог суда у Нишу

МЕХАНИЗМИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА СА ОСВРТОМ НА ПРОТОКОЛ БРОЈ 16

Резиме:

Након што је 1950. године усвојена, Конвенција за заштиту људских права и основних слобода, је ради усклађивања са развојем савременог друштва неколико пута била подвргнута допунама и изменама и у ту сврху донето је укупно 16 протокола, од којих су до сада, Протоколи број 11 и 14 донели значајније промене у саставу и начину рада Еуропског суда за људска права, а све у циљу што ефикаснијег система пружања правне заштите. Такође, у циљу постизања дугорочних резултата, главне смернице за реформу, пре свега Еуропског суда за људска права, биле су предмет разматрања међудржавних конференција, на основу којих су усвојене Декларације из Интерлакена, Измира, Бригхтона, Брисела и Копенхагена. Наведеним Декларацијама, поред осталог, потврђена је важност „система супсидијарности“, који је званично уведен са Протоколом број 15, иако је на неформалан начин заправо био присутан од самог настанка Конвенције, а који подразумева обавезу држава чланица да права и слободе утврђене Конвенцијом буду у потпуности осигуране на националном нивоу, што се у пракси појединих држава, међу којима Република Србија свакако има водеће место, показало као веома тежак процес. У циљу још већег унапређења правне заштите, а пре свега у циљу превенције будућих случајева пред Европским судом за људска права, донет је Протокол број 16, који је ступио је на снагу 1. августа 2018. године, након што га је десет држава чланица потписало и ратификовало и који према мишљењу аутора, свакако завређује значајну пажњу, из разлога јер можда и више од осталих протокола утиче на побољшање судског дијалога између Еуропског суда за људска права и домаћих судова. Овим протоколом се заправо врши превенција будућих случајева пред Европским судом кроз могућност тражења „саветодавног мишљења“, које уистину

иако необавезујуће, држави заправо даје могућност да прихватањем истог, сама, у свом правном систему, спречи потетијално кршење људских права и основних слобода, а самим тим и унапреди ниво правне заштите и владавине права. Међутим, Република Србија до данас није ратификовала овај протокол, из за сада стручној јавности непознатих званичних разлога. Но, независно од тога, сврха овог рада је да укаже на учинковитост коју овај Протокол пружа, а све у циљу унапређења стандарда људских права на националном нивоу и спречавању настанка нових судских спорова, што је према мишљењу аутора, била и сврха неговог доношења.

Кључне речи:

Људска права, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, саветодавна мишљења, начело супсидијарности, Протокол број 16 уз Конвенцију.

УВОД

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода¹⁷ (у даљем тексту “Конвенција” или “Европска конвенција”), потписана је у Риму 4. новембра 1950. године, након завршетка Другог светског рата, а ступила је на снагу 3. септембра 1953. године. Настала са намером да након злочина и конфликта које је рат са собом неминовно носио, пошаље снажну поруку да су људско достојанство и равноправност основни предуслови пре свега мира, циљ доношења Конвенције био је успостављање јединствене заштите људских права и индивидуалних слобода који, уз владавину права, чине темељ истинске демократије, како је то прописано ст. 3. Статута Савета Европе¹⁸ и са доношењем Конвенције заправо је отпочео процес стандардизације европског права. Међутим, са почетком овог процеса, до данас, јављали су се различити проблеми на националним нивоима, што је и разумљиво ако се има у виду да Савет Европе чини 47 држава, те да Конвенција броји 47 високих страна уговорница, са не само различитим правним системима, већ пре свега различитим социолошким и културолошким приликама, али и нивоима развијености правне свести, па самим тим и механизма за имплементацију међународних стандарда у својим националним законодавствима.

¹⁷ https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf

¹⁸ http://www.podaci.net/_gCGO/zakoni/Zakon_o_ratifikaciji_Statuta_Saveta_Evroe/amied7.html

Како је Конвенција живи инструмент, доношењем Протокола вршено је унапређење првобитне правне заштите и у том смислу посебан значај свакако има **Протокол број 11**¹⁹, на основу кога је 1998. године, као стална институција за заштиту људских права у европску правну праксу уведен Европски суд за људска права, (у даљем тексту „Суд“ или „Европски суд“), те дата могућност учешћа појединца у међународном правном поступку. Међутим, сврха Конвенције није била примарна заштита индивидуалног права подносиоца представке, већ пре свега успостављање механизма за генералну заштиту људских права у најширем смислу.

Државни системи имају различит однос према важењу међународног права и у том смислу позната је подела на монистичке и дуалистичке системе. Дуалистички системи међународно и национално право виде као одвојене системе, што подразумева да норме међународног права не могу бити непосредно примењиване у националном законодавству, већ се на уставом прописан начин морају унети у унутрашњи правни систем. Наша држава прихвата тзв. монистички концепт, према коме се норме међународног права непосредно примењују и представљају саставни део правног поретка, како је то прописано одредбом чл. 18. став 2. Устава Републике Србије²⁰.

Такође, познато је и да Устави појединих земаља, као што су Албанија, Аустрија, Холандија, дају Европској конвенцији уставни ранг. Важно је поменути да је Еуропски суд у појединим својим одлукама, заузео становиште да су уставне одредбе појединих земаља у колизији са конвенцијским начелима и нама значајна одлука у том смислу је свакако „*Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине*“²¹, у којој је Суд утврдио да су уставне одредбе ове државе контрадикторне забрани дискриминације, утврђене чланом 14 Конвенције, а у вези с пасивним бирачким правом из члана 3 Протокола број 1.12, будући да је нашао да су припадници националних мањина били онемогућени да буду бирани у државне органе БиХ и на основу које одлуке је ова држава преузела обавезу да измени изборно законодавство које дискриминише припаднике националних мањина. Овај случај је значајан како због тога јер је Суд по први пут одлучивао у меритуму о повреди Протокола број 1, који гарантује право на слободне изборе, тако и из разлога јер је овом одлуком заправо исказан

19 https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P11_ETS155E_ENG.pdf

20 https://www.paragraf.rs/propisi/ustav_republike_srbije.html

21 [https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:\[%22003-2974573-3281658%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-2974573-3281658%22]})

став да обавезе које морају бити преузете на међународном нивоу не могу бити избегнуте позивањем на супротне норме унутрашњег права, па макар то биле и одредбе самог устава државе. У том смислу, ништа мање значајније нису ни одлуке *„Зорнић против Босне и Херцеговине“*²² и *„Пилав против Босне и Херцеговине“*²³, које такође упућују на нужност промене одређених уставних начела и законодавне регулативе. Такође, веома значајна је и одлука *„Курић и др. против Републике Словеније“*²⁴, која се тиче питања незаконито избрисаних грађана Словеније и заштите њихових права, будући да је након проглашења независности Република Словенија нелегално избрисала око 40.000 хиљада својих грађана и тиме им одузела сва загарантована права, док је у одлуци *„Д.Х. и др. против Републике Чешке“*²⁵, Суд такође нашао повреду члана 14 Конвенције, заједно са чланом 2 Протокола бр. 1.

Према мишљењу аутора, ово су само неке од веома значајних одлука донетих у односу на бивше југословенске републике или земље у окружењу, са сличним политичким наслеђем, као што је рецимо Република Чешка, у којима је Суд изказао став да Конвенција може имати и тзв. „надуставну важност“, јер наведене одлуке упућују на нужност усклађивања уставних начела држава чланица са начелима прокламованим Конвенцијом, те заправо постизању равнотеже између заштите појединачних грађанских права и заштите колективних права, што се у досадашњој пракси показало као нимало лак задатак.

С друге стране, у појединим држава као што су Белгија, Француска, Русија, Словенија, Шпанија и наша држава, Конвенција има надзаконски ранг. Међутим, иако се Европска Конвенција хијарархијски гледано у правном поретку наше земље налази одмах иза Устава, у пракси су евидентирани многобројни проблеми у њеној примени, па је у том контексту, над Србијом морао бити уведен специјални надзор од стране Комитета министара Савета Европе у случаја „несталих беба“ до доношења Закон о утврђивању чињеница

22 [file:///C:/Users/Micka/Downloads/CASE%20OF%20ZORNIC%20v.%20BOSNIA%20AND%20HERZEGOVINA%20-%20\[Bosnian%20Translation\]%20by%20the%20Ministry%20of%20Justice%20of%20Bosnia%20and%20Herzegovina.pdf](file:///C:/Users/Micka/Downloads/CASE%20OF%20ZORNIC%20v.%20BOSNIA%20AND%20HERZEGOVINA%20-%20[Bosnian%20Translation]%20by%20the%20Ministry%20of%20Justice%20of%20Bosnia%20and%20Herzegovina.pdf)

23 [file:///C:/Users/Micka/Downloads/CASE%20OF%20PILAV%20v.%20BOSNIA%20AND%20HERZEGOVINA%20-%20\[Bosnian%20Translation\]%20by%20the%20Ministry%20of%20Justice%20of%20Bosnia%20and%20Herzegovina.pdf](file:///C:/Users/Micka/Downloads/CASE%20OF%20PILAV%20v.%20BOSNIA%20AND%20HERZEGOVINA%20-%20[Bosnian%20Translation]%20by%20the%20Ministry%20of%20Justice%20of%20Bosnia%20and%20Herzegovina.pdf)

24 <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22kuric%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-141899%22%5D%7D>

25 <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-83256%22%5D%7D>

о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породицишта, а поводом одлуке *“Зорица Јовановић против Србије”*²⁶, којом је, поред осталог, наложено држави да успостави механизам за заштиту права и обештећење родитеља, чија су деца нестала након порођаја.

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСТУПКА ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Опште је позната чињеница да се наша држава налази на високо рангираном месту по броју поднетих предавки пред Међународним судом, али и да је Суд енормно оптерећен великим бројем представки које чекају на одлучивање. Према подацима из 2019. године, 59.800 преставки је чекало да о њима буде одлучено²⁷, што је ипак значајан помак у односу на 2014. годину, када је приближно 70.000 представки чекало на одлучивање²⁸. Међутим, оно што је забрињавајућ податак је, да се чак 70 % случајева у којима Суд утврди да је дошло до кршења Конвенције, односе на систематско кршење права које је претходно већ било утврђено у судској пракси. Из наведеног се закључује, да осим што је суд свакако преоптерећен великим бројем представки, у чак 70% случајева ради се заправо о идентичним или сличним ситуацијама о којима је суд већ заузео правно становиште у ранијим пресудама, што упућује на закључак да у великом броју случајева, државе уговорнице заправо не поштују, нити примењују правне закључке Европског суда.

Из наведеног разлога, ради побољшања ефикасности суда, високе стране уговорнице су на пет конференција на највишим међудржавним нивоима разматрале смернице и могућности за унапређење рада и реформу Суда, на основу којих су усвојене **Декларације из Интерлакена, Измира, Бригхтона, Брисела и Копенхагена**, којима је између осталог, потврђен супсидијаран карактер заштите људских права коју пружа Еуропски суд, што подразумева обавезу држава чланица да обезбеди механизме како би права и слободе утврђене Конвенцијом биле у потпуности осигуране на нивоу националних законодавстава.

26 http://www.zastupnik.gov.rs/uploads/jankovic_z_pr_21794-08_ser.pdf

27 https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2019_ENG.pdf

28 https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_Report_2014_ENG.pdf

Такође, у смислу унапређења правне заштите, до сада је донето укупно 16 протокола, од којих је поред Протокола број 11, посебно важан **Протокол број 14**²⁹, који предвиђа до сада најзначајнију реформу Европског суда. Овим Протоколом, уведена је надлежност судије појединца који одлучује о дозвољености представке, али је такође уведен и нови критеријум за доношење одлуке о прихватљивости представке – значајније оштећење (*сигнифицант дисадвантаге*). Доношењем овог Протокола, уведене су измене и у погледу постизања пријатељског поравнања, јер је Суд од тренутка ступања на снагу Протокола 14 у могућности да у сваком тренутку поступка предузима радње ради постизања пријатељског поравнања, док је до ступања на снагу Протокола 14, такву могућност имао само након што би представа била проглашена прихватљивом. Једна од такође значајних новина уведена Протоколом број 14 је могућност ратификовања Европске конвенције о људским правима од стране Европске Уније, на који начин је дата могућност појединцу да се обрати Суду и када сматрају да му је повређено неко право из Конвенције актом ЕУ, а не само њених чланица.

Како Европски суд свакако није суд тзв. „четврте инстанце“, нити може заузимати место националних судова и надлежних државних власти, који имају заједничку обавезу предузимања свих непходних мера ради споровођења одлука Суда, закључак је да је ипак на домаћим судовима највећа интенција да у примени права поштују конвенцијске стандарде, а посебно уколико је о томе Суд већ заузео правно становиште у већ донетим одлукама.

Управо из наведених тазлога усвојен је **Протокол број 15**³⁰, којим се желела још више унапредити ефикасност судског процеса и који је значајан и по томе што је његовим доношењем и званично уведено начело супсидијарности и слободне процене, али и смањен рок за подношење захтева са шест на четири мјесеца, укинута право странака на улагање приговора уступању надлежности над случајем Великом већу и измењена старосна граница у погледу година за избор судија. *Начелом супсидијарности*, као једним од најзначајнијих начела, утврђена је зправо заједничка одговорност држава чланица и Европског суда за делотворну примену Конвенције. Чланом 1 овог Протокола, прописано је да се додаје нова реченица на крају Преамбуле

29 https://bs.wikisource.org/wiki/Evropska_konvencija_o_ljudskim_pravima/Protokol_broj_14.

30 <http://www.zastupnik.gov.rs/cr/articles/dokumenti/protokol-15-uz-evropsku-konvenciju-o-ljudskim-pravima.html>

Конвенције, која ће гласити: „*Потврђујући да Високе стране уговорнице, у складу са начелом супсидијарности, имају првенствену одговорност за обезбеђивање права и слобода гарантованих Конвенцијом и Протоколима уз њу, и да у ту сврху уживају поље слободне процене које је подвргнуто контролној надлежности Европског суда за људска права који је основан овом Конвенцијом.*“

Иако је начело супсидијарности званично уведено Протоколом број 15, ово начело је према мишљењу струке, заправо саставни део Конвенције од самог почетка, па можда и најзначајније начело када је у питању делотворна примена конвенцијских стандарда, али и заједничка одговорност држава и Европског суда. Независно од изричитог увођења начела супсидијарност тек са доношењем Протокола број 15, Суд је на важност овог начела заправо указао још у одлуци „*Белгијска лингвистика*“³¹ из давне 1968. године, у којој је између осталог, закључио да је на државама чланицама да саме изаберу начин на који ће уредити посебне области од највишег државног интереса.

ПРОТОКОЛ БРОЈ 16

Протокол број 16 уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода³², ступио је на снагу 1. августа 2018. године, пошто га је потписало и ратификовало десет држава чланица³³. Састоји се од једанаест чланова, од којих првих пет представљају материјалноправне и процесне одредбе. Чланом 1. Протокола прописано је да највиши судови и трибунали Високе стране уговорнице, како је предвиђено у складу са чланом 10, могу од Суда тражити да да саветодавна мишљења о начелним питањима у вези са тумачењем или применом права и слобода дефинисаних Конвенцијом или протоколима уз њу, као и да Суд или трибунал који тражи мишљење може захтевати саветодавно мишљење само у контексту предмета који се води пред њим и постоји обавеза овог суда да наведе разлоге свог захтева и достави релевантну правну и чињеничну позадину предмета који је

31 <https://www.equalrightstrust.org/sites/default/files/ertdocs//Microsoft%20Word%20-%20Belgian%20linguistics%20case.pdf>

32 <http://www.zastupnik.gov.rs/cr/articles/dokumenti/protokol-16-uz-evropsku-konvenciju-o-ljudskim-pravima.html>

33 Протокол 16 потписале су и ратификовале следеће државе: Албанија, Арменија, Естонија, Финска, Француска, Грузија, Литванија, Сан Марино, Словенија и Украјина. Протокол су потписале без ратификације следеће државе: Андора, Босна и Херцеговина, Грчка, Италија, Холандија, Норвешка, Молдавија, Румунија, Словачка и Турска.

у току. Веће од пет судија Великог већа одлучује о томе да ли прихвата захтев за саветодавно мишљење и уколико захтев буде усвојен, донеће саветодавно мишљење са образложењем, које ће потом бити и јавно објављено.

Оно што је према мишљењу аутора од посебне важности, је могућност прописана чланом 2. тачком 3. према којој ће Веће и Велико веће, укључити по службеној дужности судију изабраног за Високу страну уговорницу из које је суд или трибунал који тражи мишљење, што даје могућност изабраном судији да практично учествује у креирању саветодавног мишљења. Ово је посебно важно, јер би се на овај начин Суду могло указати на постојање извесних друштвених, социолошких или пак политичких специфичности у правном систему државе која тражи мишљење, а које би могле бити од утицаја на конкретан случај. Према мишљењу аутора, учешће домаћег судије у креирању саветодавног мишљења је можда и најзначајније са политичког аспекта, јер би на овај начин национални судови избегли сваку могућност да њихове одлуке буду предмет било каквих политичких дијалога или полемика, будући да је у нашој држави позната веома честа тенденција „политичке оцене судских одлука“ и стављања истих у разне политичке контексте, што је са становишта судске струке често не само потпуно неистинито, већ и веома штетно за углед правосудне професије. Другим речима, на овај начин избегла би се могућност било каквог чак и покушаја утицаја извршне власти на судску и веома честе слике јавног мњења о постојању директног утицаја.

Иако саветодавна мишљења нису обавезујућа, како је то прописано чланом 5. Протокола, велика је важност да национални судови имају могућност да се приликом одлучивања, а нарочито у групним предметима, могу ослонити на мишљење Европског суда и на тај начин спречити будуће судске поступке пред овим судом. Могућност давања саветодавног мишљења, битна је и са становишта уједначавања судске праксе на националном нивоу, јер би се на овај начин избегла могућност доношења различитих судских одлука у предметима који имају исто чињенично и правно стање.

И поред наведених погодности које Протокол број 16 свакако пружа, осим што несумњиво побољшава и унапређује механизам заштите људских права, овим Протоколом се међудржавни дијалог, предвиђен начелом супсидијарности, заправо подиже на један виши ниво и финализује оно што се пре свега Декларацијама из Брајтона и Измира желело постићи. Овим протоколом дефинитивно се мења и однос Европског суда према

националним судовима, јер ће уместо до сада односа искључивог ауторитета Европског суда, овај однос попримати и примесе сардње, што је од великог значаја пре свега за боље прихватање улоге Суда у државама у којима постоји тенденција очувања националног законодавства по сваку цену. Са друге стране, овим Протоколом даје се могућност националним судовима да „ограниче простор“ Европског суда приликом заузимања правних ставова и укажу на специфичности појединих случаја, посебно у осетљивим предметима.

Конечно, ратификацијом овог начела и тражењем саветодавног мишљења, могу се на националном нивоу избећи евентуални „сукоби мишљења“ између Врховних и Уставних судова, те заузимање разлитих, често чак потпуно супротних правних становишта, која у правну праксу уносе додатну несигурност и имају велики утицај на неједначеност исте.

Нова процедура потписана овим Протоколом 16 у извесном смислу дерогоира строго формалну процедуру прописану члановима 47, 48 и 49 Конвенције, која легитимише Комитет Министара за покретање саветодавног механизма, али само у правним питањима која су везана за тумачење Конвенције и протокола уз њу. Протоколом број 16 се овај поступак доводи на један пријатељски терен и при томе омогућува достава писаних коментара и непосредно учешће националних судова у заседању, што је према мишљењу аутора веома значајна новина. Такође, чланом 36. ст. 3. Конвенције прописано је да Комесар за људска права Савета Европе може поднети писани поднесак и узети учешће у расправи у предметима пред већем или Великим већем, док члан 3. Протокола прописује да Комесар за људска права Савета Европе и Висока страна уговорница из које је суд или трибунал који тражи саветодавно мишљење имају право да доставе писане коментаре и учествују у заседању, што је такође напредно решење.

Конечно, како саветодавно мишљење није обавезујуће, уколико национални суд исто не би прихватио, појединцу свакако не би било ускраћено право да тражи заштиту пред Европским судом подношењем представке. Међутим, у таквом случају очекивано је да би већ дато саветодавно мишљење било само преведено у формалну одлуку, будући да приликом тражења мишљења мора бити достављена релевантна правна и чињенична позадина предмета који је у току, што упућује на закључак да би национални судови заправо били на губитку да уколико затраже саветодавно мишљење исто не прихвате, јер

је мало вероватно да би Суд у својој формалној одлуци одступио од раније датог мишљења.

И поред свих бенефита, које према мишљењу аутора Протокол број 16 свакако обезбеђује, за сада нису познати разлози због којих наша држава исти није ратификовала. Такође, није познато ни који би суд у нашој држави био овлашћен сходно члану 10. Протокола за обраћање Европском суду, а имајући у виду прописану обавезу да свака Висока страна уговорница Конвенције, у време потписивања или приликом депоновања инструмената ратификације, прихватања или одобравања, путем изјаве упућене Генералном секретару Савета Европе, наведе судове или трибунале које одређује у сврхе члана 1. став 1. овог Протокола. Румунија је рецимо, на листу судова који се могу обраћати Европском суду, поред Уставног и Врховног суда, уврстила и Апелационе судове и тиме дала могућност заправо свим највишим судовима у држави да могу имати непосредну комуникацију са Великим већем, што је према мишљењу аутора, изузетно целисходно решење, ако се има у виду да Апелациони судови у нашој држави у великом броју предмета поступају као последња инстанца, јер новчани цензус не дозвољава изјављивање ревизије.

ПРИМЕНА ПРОТОКОЛА БРОЈ 16 У ПРАКСИ

Што се тиче практичне примене Протокола број 16, до сада су донета само два саветодавна мишљења.

Прво саветодавно мишљење Великог већа од 10. априла 2019. године, дато је на захтев Касационог суда Француске, захтев број *III6-2018-001*³⁴, који је поставио следеће питање:

Да ли је страна у спору – Држава, прекорачила границу дозвољеног одступања од одредбе члана 8 Европске конвенције о људским правима и основним слободама, одбијањем уписа планиране мајке као законске мајке у Матичну књигу рођених, венчаних и умрлих, на основу оригиналног извода из матичне књиге рођених детета рођеног у иностранству у складу са договором о гестацијској сурогацији (сурогат материнства), док истовремено прихвата упис планираног оца, који је биолошки отац детета? У вези са тим, да ли је потребно правити разлику између случајева када је дете зачето

34 <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6380464-8364383#%7B%22itemid%22:%5B%22003-6380464-8364383%22%5D%7D>

коришћењем јажних ћелија планиране мајке и осталих случајева и да ли би могућност да планирана мајка законски усвоји дете свог супружника, биолошког оца детета и да се на тај начин успостави законски однос дете - родитељ, осигурала усклађеност са одредбама члана 8 Европске конвенције о људским правима и основним слободама?

Суд је поводом ових питања донео следеће правно мишљење:

Право на поштовања приватног живота детета према значењу члана 8 Конвенције подразумева да се домаћим законима омогући признавање законског односа дете-родитељ са планираном мајком, која је изводом из матичне рођених издатим у иностранству одређена као „законска мајка“;

Право на поштовања приватног живота детета према значењу члана 8. Конвенције не подразумева да такво признавање треба да буде у форми уписа у Матичну књигу рођених, венчаних и умрлих преписом из извода из матичне књиге рођених издатог у иностранству и да се могу користити и други инструменти, попут усвајања детета од стране планиране мајке, уз услов да се поступак успостављен домаћим законодавством може спровести брзо и ефикасно, у складу са најбољим интересом детета.

Друго саветодавно мишљење Великог већа од 29. маја 2020. године, дато је на захтев Уставног суда Јерменије, захтев број *III6-2019-001*, у вези употребе технике „бланкетне референце (упућивања)“ или „законодавства путем референце“ у дефинисању кривичног дела и стандардима поређења између кривичног закона који је био на снази у време када је дело извршено и измењеног кривичног закона.³⁵

Закључак:

Доношење Протокола број 16 није имало за циљ само растерећење Европског суда будућих представаки, већ пре свега стварање једног пријатељског дијалога између овог суда и националних судова, што је можда и највећи помак у досадашњој реформаторској пракси. Такође, на овај начин, националним судовима, па и законодавствима, на један мање формалан начин него што се то чини кроз званичне судске одлуке, биће приближена важност правилне примене и поштовања европских стандарда, који би свакако кроз институт саветодавних мишљења лакше нашли свој пут и место у националним законодавствима држава чланица.

³⁵ <https://strasbourgobservers.com/2020/06/05/advisory-opinion-no-2-a-slightly-bigger-rodent/>

Пракса показује да су до сада донета само два саветодавна мишљења, што је свакако незадовољавајуће и што говори у прилог уверењу једног дела стручне јавности, да се национални судови ипак неће користити овом могућношћу у великој мери, у тежњи очувања свог ауторитета приликом доношења судских одлука. С друге стране, у правној теорији се јавља и мишљење да је до сада донет мали број саветодавних мишљења због веома ригорозне процедуре приликом тражења истих и веома строгих критеријума на којима Европски суд инсистира приликом одлучивања о прихватљивости захтева.

Но, независно од разлога због којих није донет већи број саветодавних мишљења, било би свакако пожељно да Република Србија у што краћем року ратификује Протокол број 16, али и да већем броју највиших државних судова буде пружена могућност за непосредно обраћање Великом већу. На овај начин, осим што би се избегли будући спорови, неминовно би дошло и до помака у уједначавању судске праксе, што је један од горућих проблема нашег правосуђа, који за последицу има управо велики број представки пред судом у Стразбуру.

Такође, могућност учествовања националног судије у раду и заузимању става Великог већа о конкретном правном питању, непроцењива је, јер пружа директну могућност држави уговорници да учествује у креирању мишљења и унапред упозори на евентуалне специфичности случаја.

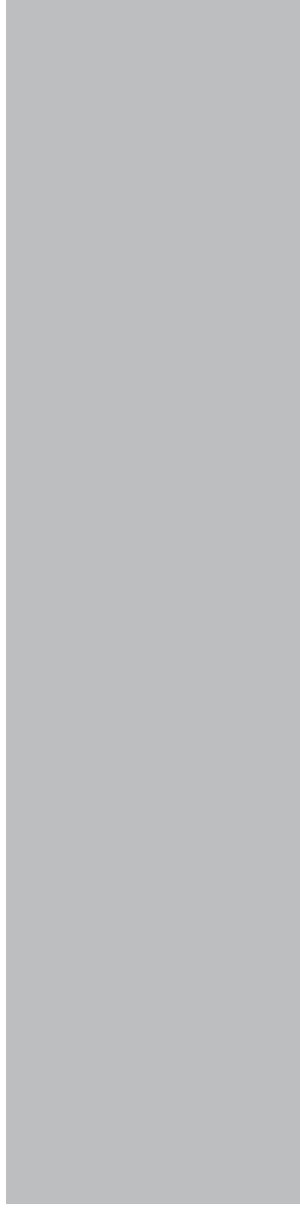
Коначно, тражењем саветодавних мишљења и применом истих, национални судови би у сваком погледу са себе скинули одговорност било какве политичке конотације, или евентуалног покушаја утицаја на судску власт, нарочито у великим групама предмета или предметима у којима се као једна од страна јављају држава или њени органи. Применом саветодавних мишљења не би само Европски суд био растерећен будућих представки, већ би и национални судови били растерећени пре свега неуједначене судске праксе, али и честог утиска јавности да судска власт није довољно независна у доношењу судских одлука.

Напомена:

Рад је објављен у часопису Глосаријум, број 11, новембар 2020.године, као тема броја, под насловом:

Инструментаријум за побољшање ефикасности рада Европског суда за људска права, са освртом на Протокол број 16

**ПРАВНИ СТАВОВИ,
ЗАКЉУЧЦИ И ОДГОВОРИ
НА СПОРНА ПИТАЊА**



**ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ
ОДРЖАНЕ ДАНА 19.02.2021. ГОДИНЕ**

Разматрање поступања у предметима по жалби на пресуде донете по тужбама ратнихвојних резервиста којима се, након правноснажног окончања парнице у којима је утврђена дискриминација, накнадно тражи објављивање пресуде као вид сатисфакције због повреде права личности (Гж. бр. 387/2021).

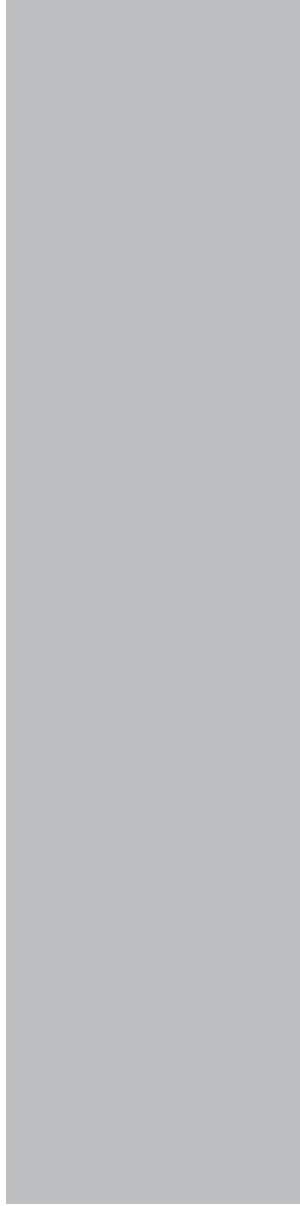
Констатује се да је, након гласања, једногласно заузет став да право на објављивање пресуде, којим се утврђује повреда права личности као вид нематеријалне штете – обештећења, застарева у роковима прописаним Законом о облигационим односима, за штету, који су одређени на пет година као објективни рок и три године, као субјективни рок. Рокови се имају рачунати од момента сазнања за учињењу штету и починиоца, односно од настанка штете.

Тужба за објављивање пресуде којим је утврђена повреда права личности се може самостално поднети, али такво тражење се третира као злоупотреба процесних овлашћења, па у том случају тужиоци немају право на трошкове поступка - ако би успели. Став Грађанског одељења је да донету првостепену пресуду треба потврдити, јер погрешна примена Закона не представља погрешну примену материјалног права, али дати образложење које се тиче правилне примене прописа, а то је чл. 199. Закона о облигационим односима и правилну оцену приговора застарелости везану за овај став.

Наведени закључци се односе на оне ситуације у којима је дискриминација утврђена применом чл. 21. Устава и Европске конвенције, а не примењују се на ситуације на које се примењује као *lex specialis*, Закон о забрани дискриминације.

ГРАЂАНСКО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА



СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СПОРОВИМА О ВАНУГОВОРНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ СА МЕЂУНАРОДНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Надлежност суда Републике Србије у спору за накнаду нематеријалне штете са иностраним елементом, постоји уколико су последице штетног догађаја, наступиле на територији Републике Србије.

**(чл. 53. Закона о решавању сукоба закона
са прописима других земаља)**

Из образложења:

У правном систему Републике Србије, правила о надлежности судова и других органа Републике Србије и одређивању меродавног права за статусне, породичне и имовинске, односно друге односе са међународним елементом, уређена су Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља. Одредбом чл. 53. тог закона, између осталог, прописано је да у споровима за вануговорну одговорност за штету, надлежност суда Републике Србије постоји ако је штета настала на територији Републике Србије. Под стандардом „настанак штете“, подразумева се како место где је дошло до директне последице извршења штетне радње, тако и место где су наступиле коначне штетне последице, макар и индиректне. У складу са тиме су уређена и правила о меродавном праву које се примењује у споровима вануговорне одговорности за штету, садржана у чл. 28. ст.1. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, којом одредбом је прописано да се у тим споровима примењује право места где је радња извршена или право места где је последица наступила, зависно од тога које је од та два права повољније за оштећеника.

У конкретном случају, штетне последице нематеријалне и материјалне штете тј вануговорне штете, тужилац је трпео у Републици Србији, у коју државу је транспортован непосредно након критичног догађаја, где је касније и лечен и то у Неурохируршкој клиници, а затим у кућним условима, као и континуираним вишегодишњим амбулантним лечењем од стране лекара неуролога и психијатра. Из тог разлога, а по критеријуму настанка штете и наступања штетних последица, овај суд је своју међународну надлежност засновао на основу чл. 53. цитираног закона. На овакво становиште суда су без утицаја наводи туженог да се на спорни однос има применити чл. 3.

Хашке конвенције о меродавном праву за друмске саобраћајне незгоде и у складу са истим, да се надлежност има засновати пред судом државе не чијој територији се догодила саобраћајна незгода. Ово из разлога што наведена Конвенција не уређује питање надлежности већ питање примене меродавног права, а тим пре што се у конкретном случају, саобраћајна незгода тј штетни догађај, одиграо на територији ничије земље, неутралној зони граничног прелаза-Евзони, па се самим тим, принцип територијалности самог штетног догађаја, не може узети као валидан критеријум по ком би се засновала надлежност суда одређене државе у овој правној ствари.

Из наведених разлога, наводи друготуженог да у овој правној ствари не стоји међународна тј. стварна надлежност суда Републике Србије, нису основани.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж 1306/18 од 03.10.2019. године,

Аутори сентенце: Никола Пржић, судија Апелационог суда у Нишу, Тамара Станојевић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

ПРИМАРНИ И ЕВЕНТУАЛНИ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ

члан 197 став. 2. Закона о парничном поступку

Тужбени захтеви за утврђење ништавости по различитим правним основима не представљају примарни и евентуални тужбени захтев, већ један главни захтев за утврђење ништавости по више различитих правних основа, без обзира на то како их тужилац у тужби означио.

Из образложења:

Према стању у списима предмета тужиље су тужбени захтев поставиле на тај начин што су примарним захтевом тражиле утврђење ништавости уговора о доживотном издржавању из разлога предвиђених у члану 196 Закона о наслеђивању, док су као евентуалне поставиле, најпре, захтев за поништај, и опет утврђење ништавости уговора, али из разлога прописаних чланом 56. став. 1. и 103. став. 1. Закона о облигационим односима.

Првостепени суд је усвојио само примарно постављени тужбени захтев за утврђење ништавости уговора о доживотном издржавању, и из разлога предвиђених у члану 196. Закона о наслеђивању, који захтев су тужиље

поставиле као примарни, али и из разлога прописаних чланом 56. став. 1. и 103. став. 1. Закона о облигационим односима, који су тужиле означиле као један од евентуалних захтева.

Неосновано се жалбеним наводима тужене указује да је изрека пресуде неразумљива јер првостепени суд није одлучио у складу са постављеним тужбеним захтевом тужила. Ово са разлога што су тужиле тужбени захтев поставиле тако што су примарним захтевом тражиле утврђење ништавости уговора из разлога предвиђених у члану 196. Закона о наслеђивању, док су као евентуалне поставиле, најпре, захтев за поништај, и опет утврђење ништавости уговора, али из разлога прописаних чл. 56. став. 1. и 103. став. 1. Закона о облигационим односима. С тим у вези, правилно је првостепени суд, супротно жалбеним наводима, утврдио да је независно од тога како су тужиле ове захтеве назвале, примарни захтев захтев за утврђење ништавости по два правна основа и то и из члана 196. став. 1. Закона о наслеђивању и из чланова 56. став. 1. и 103. став. 1. ЗОО. У том смислу, ради се о једном главном тужбеном захтеву за утврђење ништавости и евентуалном за поништај уговора, о коме првостепени суд правилно није одлучивао јер је усвојио главно постављени захтев.

(Из пресуде Апелациног суда у Нишу 42Гж 1135/20 од 28.05.2020. године)

Аутори сентенце: Милица Златковић, судија Апелациног суда у Нишу са судијским помоћником Мишом Вујичићем.

САДРЖИНА ТУЖБЕ И ИДЕНТИТЕТ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА

Члан 192 Закона о парничном поступку

За одлуку суда о захтеву тужиоца, Центра за социјални рад, за утврђење да је тужени према својој супрузи починио физичко и психичко насиље, није одлучна чињеница, да ли је супруга туженог - жртва насиља у поступку пред належним органима негирала догађај у коме се десило насиље, већ се одлука суда о постојању насиља мора заснивати на оцени свих релевантних доказа.

Из образложења:

Донета одлука противуречна је и супротна жалбом непобијаном ставу трећем изреке, одлука о противтужбеном захтеву туженог, садржана у ставу четвртном изреке.

Наиме, тужила је у овој правној ствари тужбом тражила утврђење да јој је део кп. бр. 1973 од 413 м² у описаним мерама и границама изузет из права својине, исплату накнаде за тако изузет део парцеле и утврђење, да је тужени на том делу парцеле стекао право својине фактичком експропријацијом, а тужени је противтужбом тражио, да му се на истом делу парцеле утврди право својине и да има непрекидну и савесну државину.

Сходно чл. 194 ст. 1-3 ЗПП-а, тужилац може у тужби да тражи да суд само утврди постојање, односно непостојање неког права или правног односа, повреду права личности или истинитост, односно неистинитост неке исправе, а тужба за утврђење може да се поднесе ако тужилац има правни интерес да суд утврди постојање, односно непостојање неког спорног права или правног односа, пре доспелости захтева за чинидбу из истог односа или истинитост односно неистинитост неке исправе, или ако тужилац има неки други правни интерес. Тужба за утврђење може да се поднесе и ради утврђивања постојања, односно непостојања чињенице, ако је то предвиђено законом или другим прописом.

Иако је тужила тужбом тражила утврђење права туженог, а из стања у списима предмета произилази, да тужила није образлагала свој правни интерес за подношење такве тужбе за утврђење и да је изостала оцена првостепеног суда да ли тужила има правни интерес за подношење тужбе у том делу, по тако постављеном тужбеном захтеву суд је поступао и утврдио право својине туженог као у ставу трећем изреке, који жалбом није побијан, па је у том делу првостепена пресуда протеклом рока за жалбу постала правноснажна, тј. правноснажно је утврђено право својине туженог на означеном делу парцеле. Сходно томе, одлука првостепеног суда у делу у коме се одбија противтужбени захтев туженог за утврђење права својине туженог на истом делу парцеле у супротности са правноснажним делом пресуде којим је такво право туженог утврђено. Разлика у правном основу по коме је тужени ово правно стекао, није од утицаја на идентитет захтева, јер се тужбом може тражити само утврђење постојања односно непостојања неког права или правног односа (уколико за то постоји правни интерес) или

утврђење постојања односно непостојања неке чињенице (ако је то законом или другим прописом предвиђено). Стога део тужбеног захтева у коме се наводи да је право својине стечено фактичком експропријацијом, по својој правној природи је правни основ по коме тужени право својине стиче, који је у смислу чл. 192 ст. 4 ЗПП-а необавезни елемент тужбе, али није саставни део самог захтева и исти не чини идентитет захтева. Део петитума противтужбе туженог, да тужени има непрекидну и свесну државину представља утврђење чињенице, а такав захтев нема своје утемљење у ниједном закону, односно другом пропису. Сходно томе, између тужбеног захтева тужиље за утврђење права својине туженог и противтужбеног захтева туженог у делу у коме се тражи утврђење права својине истог, постоји идентитет захтева, па је током поступка у том делу постојала литиспенденција о којој суд није водио рачуна, нити је ценио дозвољеност противтужбе у делу у коме се тражи утврђење чињенице, а сада је побијани став четврти изреке у супротности са правноснажно пресуђеним захтевом тужиље у ставу трећем изреке, па је пресуда и у том делу морала бити укинута.

Из Решења Апелационог суда у Нишу 32 Гж. бр.497/20 од 11.02.2020. год.

Аутор сентенце Зорица Стошић, судија Апелационог суда у Нишу

НЕПОТПУНА ЖАЛБА

**Закон о парничном поступку
(„Службени Гласник РС“ бр. 72/11 18/20)**

чл. 371. ст. 1. ЗПП

Судски пословник (“Сл. гласник РС” бр. 110/09 93/19)

чл. 157а Судског пословника

**Закон о електронском документу, електронској идентификацији и
услугама од поверења у електронском пословању**

(“Сл. гласник РС” бр. 94/17)

чл. 20. ст. 4. и чл. 50. ст. 2. Закона о електронском документу ...

Жалба тужиоца која је изјављена против првостепене пресуде путем његовог пуномоћника адвоката и која је достављена суду путем електронске поште, а није потписана квалификованим електронским потписом подносиоца, односно квалификованим електронским потписом пуномоћника тужиоца из реда адвоката, јесте непотпуна жалба, због чега се иста мора одбацити.

Из образложења:

„Разматрајући списе предмета поводом изјављене жалбе тужиоца, другостепени суд је уочио да пуномоћник тужиоца из реда адвоката, путем кога је тужилац поднео жалбу против првостепене пресуде, исту није потписао у складу са чл. 370. ст. 1. тач. 4 ЗПП и чл. 157а ст. 3. Судског пословника. Предметна жалба не садржи потпис подносиоца жалбе.”

Садржина жалбе прописана је чл. 370. ЗПП тако што жалба мора да садржи: означавање пресуде против које се изјављује жалба, изјаву да се пресуда побија у целини или у одређеном делу, разлог жалбе и потпис подносиоца жалбе. Из наведене законске одредбе несумњиво произилази да се ради о обавезним елементима жалбе, тако да иста у смислу цитираног чл. 370. ст. 1. тач. 4 ЗПП између осталог, мора да садржи потпис подносиоца жалбе.

И Закон о адвокатури (“Сл. гласник РС” бр. 31/11 и 24/12) у чл. 29. ст. 5. прописује да је адвокат дужан да на сваку исправу, допис или поднесак који је саставио стави свој потпис и печат.

Осим тога, из предметне жалбе произилази да је иста поднета суду од стране пуномоћника тужиоца електронским путем у прилогу електронске поште дана 23.03.2020. године и да је на крају жалбе наведено “Пуномоћник тужиоца (М. Г. адвокат из В.) ЈМБГ”. Предметна жалба међутим, не садржи квалификовани електронски потпис подносиоца жалбе.

У савременом друштву, када се ради како о свакодневном комуницирању, тако и комуницирању и општењу странака са судовима и уопште органима јавне власти, законом је дозвољено комуницирање електронским путем.

Сходно наведеном, чл. 98. ст. 2. ЗПП подразумева употребу електронске поште и предају електронских поднесака путем исте, а у складу са посебним законом.

И чл. 157а Судског пословника (“Сл. гласник РС” бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15 - испр., 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19) прописано је да се електронска писмена у облику оригиналног електронског документа снабдевана одговарајућим електронским потписом и интегрисана временским жигом могу у суду примити помоћу програма за пријем електронског документа, у складу са посебним прописима, након што се одговарајућим техничким средствима изврши провера електронског потписа и временског жига. Електронска писмена достављају се суду путем електронске поште на адресу електронске поште која је од суда одређена за пријем електронских поднесака или другим електронским путем, у складу са законом. Ако је законом прописано да акт треба да буде потписан од стране одређеног лица, сматра се да је тај услов испуњен за акт у облику електронског документа ако је на крају електронског документа наведено име и презиме одговарајућег лица и електронски документ потписан квалификованим електронским потписом тог лица.

Из наведене законске регулативе произилази да ако је законом прописано да акт треба да буде потписан од стране одређеног лица, сматра се да је тај услов испуњен за акт у облику електронског документа ако је на крају електронског документа наведено име и презиме одговарајућег лица и електронски документ потписан квалификованим електронским потписом тог лица.

Наиме, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (“Сл. гласник РС” бр. 94/17), као посебан закон, у чл. 15. ст. 1. прописује да поднесак израђен као електронски документ физичка и правна лица (странке) достављају органима

јавне власти путем електронске поште на адресу електронске поште која је од стране органа јавне власти одређена за пријем електронских поднесака. Када се ради о потпису странке на поднеску, исти закон у чл. 20. ст. 4. јасно прописује да у општењу странке са органима јавне власти идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, док у чл. 50. ст. 2. наведени закон прописује да квалификован електронски потпис има исто правно дејство као и својеручни потпис.

Имајући у виду све напред наведено, а како у конкретном случају жалба тужиоца која је изјављена против првостепене пресуде путем његовог пуномоћника адвоката и која је достављена суду путем електронске поште, није потписана квалификованим електронским потписом подносиоца, односно квалификованим електронским потписом пуномоћника тужиоца адвоката М. Г. из В., то је иста непотпуна у смислу чл. 98. и чл. 370. ст. 1. тач. 4 ЗПП, у вези са чл. 157а ст. 3. Судског пословника.

Сходно наведеном, а како је чл. 371. ст. 1. ЗПП прописано да ако жалба није потписана (непотпуна жалба), првостепени суд ће решењем, против кога није дозвољена жалба да одбаци жалбу као непотпуну (чл. 101. ст. 5. ЗПП), док је чл. 389. ст. 1. ЗПП прописано да ће неблаговремену, непотпуну или недозвољену жалбу одбацити другостепени суд решењем, ако то није учинио првостепени суд, без одлагања (чл. 378.), то је другостепени суд, применом цитираних законских одредби одбацио жалбу тужиоца поднету против првостепене пресуде путем његовог пуномоћника из реда адвоката, као непотпуну, јер иста не садржи квалификовани електронски потпис подносиоца жалбе.

***Из решење Апелационог суда у Нишу Гж. 1664/20 од 16.09.2020. године
Сентенцу приредила судија Невена Благојевић***

**НЕДОЗВОЉЕНОСТ ЖАЛБЕ
ИЗЈАВЉЕНЕ ОД СТРАНЕ ПУНОМОЋНИКА
СТРАНКЕ КОЈА ЈЕ ПРЕМИНУЛА**

чл.389. ст. 1. Закона о парничном поступку

Смрћу парничне странке престаје пуномоћје дато адвокату, па је жалба коју је изјавио пуномоћник недозвољена, пошто је исту изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе, према чл. 378. ст. 3. Закона о парничном поступку.

Из образложења:

О тужбеном захтеву тужиоца, одлучено је првостепеном пресудом од 12.10.2017. године, како је то ближе наведено у изреци исте. Тужени О.К. преминуо је дана 23.10.2017. године. Наведена пресуда достављена је пуномоћницима тужиоца и туженог, при чему је Јелена Митић, адвокат из Ниша, која је у овом поступку заступала туженог О.К., пресуду примила 03.11.2017. године, а жалбу против исте је изјавила 17.11.2017. године. Решењем суда од 04.12.2017. године прекинут је поступак због смрти туженог, а исти је решењем суда од 17.05.2019. године настављен, сада против тужених Д.К. и С.К., као правних следбеника сада пок. О.К.

По оцени Апелационог суда, Јелена Митић адв. из Ниша није била овлашћена за изјављивање жалбе у име и за рачун туженог у овом спору, с обзиром да је тужени О.К. преминуо дана 23.10.2017. године, да је смрћу туженог престало пуномоћје дато адвокату Јелени Митић из Ниша, тако да је у овој правној ствари жалбу изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе. Услед наведеног, а према чл. 378. ст. 3. ЗПП, предметна жалба је недозвољена, пошто је исту изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе.

Наиме, према чл. 93. ст. 1. ЗПП пуномоћје престаје смрћу физичког лица, проглашењем за умрло и губитком пословне способности. Сходно наведеној законској одредби, несумњиво произилази да смрћу странке, која је имала пуномоћника у поступку, престаје и однос пуномоћства, са којих разлога се сматра да је жалба истог пуномоћника, након смрти странке, изјављена од стране неовлашћеног лица. Надаље, према чл. 378. ст. 1. ЗПП првостепени суд ће неблаговремену, непотпуну (чл. 371. ст. 1.) или недозвољену жалбу да одбаци решењем, без одлагања. Према ст. 3. жалба је недозвољена ако

је жалбу изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе, ако је жалбу изјавило лице које се одрекло или је повукло жалбу или ако лице које је изјавило жалбу нема правни интерес за изјављивање жалбе. Према чл. 389. ст. 1. ЗПП неблаговремену, непотпуну или недозвољену жалбу одбациће другостепени суд решењем, ако то није учинио првостепени суд, без одлагања (чл. 378). Полазећи од наведених одредби, чињенице да је тужени умро дана 23.10.2017. године, да је смрћу туженог престало пуномоћје дато адвокату Јелени Матић из Ниша, Апелациони суд налази да је жалбу изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе, из ког разлога је жалба одбачена као недозвољена, применом чл. 389. ст. 1. ЗПП.

Иначе, како се у датој ситуацији не ради о отклоњивом процесном недостатку у погледу заступања странке од стране неовлашћеног лица, пошто је пуномоћје дато напред наведеном адвокату од стране туженог престало његовом смрћу, то оваква одлука другостепеног суда, не утиче на учешће наследника сада пок. туженог О.К. у овој парници, а као лица која су ступила на његово место у овом спору, те њихово право да им се изврши уредна достава свих писмена која је првостепени суд донео након смрти туженог сада пок. О.К.

(Решење Апелационог суда у Нишу Гж.4595/19 од 23.10.2019.године),

Аутор сентенце Мирјана Милутиновић, саветник у Апелационом суду у Нишу

ПРЕСТАНАК ПРАВА СВОЈИНЕ ПО ОСНОВУ НАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

У ситуацији када је одлука о национализацији имовине донета на основу тада важећих прописа и постала правноснажна, не може се накнадно у судском поступку, преиспитивати правилност спроведеног поступка национализације и законитост одлуке, јер важећи прописи Републике Србије, не дају таква овлашћења парничном суду.

**Закон о национализацији најамних зграда
и грађевинског земљишта, Сл ФНРЈ бр. 52/59**

Из образложења:

Првостепени суд је правилно утврдио да је зграда бр. .. у ул. ..., национализована Законом о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта (Службени лист ФНРЈ бр. 52/59), у складу са Уредбом о поступку за спровођење национализације најамних зграда и грађевинског земљишта (Службени лист ФНРЈ Бр. 4/1959, 53/60) и доношењем правноснажног решења о национализацији бр. од 17.04.1963. године и да је тада, право својине правних претходника тужилаца на тој непокретности, прешло из приватне у државну (друштвену) својину, па је правилном применом материјалног права, одлучио као у ставу првом изреке, а за своју одлуку је дао довољне и јасне разлоге које у потпуности прихвата и овај суд.

Наиме, Законом о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта, који је био на снази у време доношења решења о национализацији бр. од 17.04.1963. године, прописано је да се национализују и постају друштвена својина најамне стамбене зграде и најамне пословне зграде (чл.1), одређено је шта грађани могу на територији Југославије стицати и имати у својини (чл.2) и одређен је предмет национализације, стамбене зграде и посебни делови стамбених зграда које се даном ступања Закона на снагу национализују (чл.12). Чл. 54. - 62. Закона, уређен је поступак национализације. У складу са чл. 62. Закона, донета је и Уредба о поступку за спровођење национализације најамних зграда и грађевинског земљишта (Службени лист ФНРЈ Бр. 4/1959...1/1965), којом је ближе уређен поступак за утврђење предмета национализације, поступак за одређивање висине накнаде за национализоване непокретности, као и надлежности, састав и рад комисије за национализацију.

У смислу одредаба Закона и Уредбе, даном ступања на снагу Закона (26.12.1958. године), имовина грађана је национализована, а у посебном поступку, та национализација је спровођена тако што је појединачним актом одређен предмет национализације, имовина која је изузета од национализације и која се оставља грађанима у својину и друго. Чином национализације, право својине ранијих власника је престало, а имовина прешла у друштвену својину.

У ситуацији када је одлука о национализацији непокретности донета на основу тада важећег прописа и постала правноснажна, не може се накнадно у судском поступку, преиспитивати правилност спроведеног поступка и

законитост одлуке, јер важећи прописи Републике Србије, не дају таква овлашћења парничном суду. Супротно жалбеним наводима, решење којим је утврђено да је зграда бр. ... у ул. ..., предмет национализације, снадбевено је клаузулом правноснажности, а тужиоци нису доказали да је та клаузула у посебном поступку укинута или да је на било који начин, то решење стављено ван снаге, па су и наводи којима се указује на неправилности у поступку који је претходио доношењу те одлуке, без утицаја на другачије одлучивање. Дакле, како је право својине правног претходника тужилаца престало национализацијом, то тужиоци на истој имовини, нису могли стећи право својине наслеђивањем, како је правилно закључио и првостепени суд.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж 1908/20 од 25.11.2020. године,

Аутори сентенце: Никола Пржић, судија Апелационог суда у Нишу

Тамара Станојевић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

НИШТАВОСТ УГОВОРА О ПОКЛОНУ ЗБОГ НЕДОПУШТЕНИХ ПОБУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Мотиви тј. побуде које наводе поклонодавца на закључење уговора, субјективне су психолошке појаве и нису садржане у изјави воље, али су саставни део уговора, спојен са основом. Стога, је ништав уговор о поклону код кога је побуда за закључење недопуштена, дакле противна принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима.

чл. 52. и чл. 53. ст.3.. Закона о облигационим односима

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила А. и тужени Н.су бивши супружници, мал. В. и мал. Д. су њихова заједничка деца, тужена М. је мајка туженог Н. Након престанка брачне заједнице, тужила је са мал. децом наставила да живи у стану у ул..., који је тада представљао посебну имовину туженог Н. Уговором о поклону Ов бр. ... од 31.03.2014. године, тужени Н. је ктај стан поклонио туженој М. Дана 14.07.2014. године, тужена М. је против

тужилаца и туженог Н. поднела тужбу за исељење. Утврђено је да тужиља А. не поседује имовину на своје име.

Правилно је првостепени суд нашао да је уговор о поклону закључен уз постојање недопуштених побуда на страни туженог Н. као поклонодавца, а која побуда се састојала у томе да се тужиоцима онемогући да даље живе у стану у ул...., па је правилном применом материјалног права из чл. 52. и чл. 53. ст.3.. Закона о облигационим односима, утврдио да је тај уговор ништав и одлучио као у ставу првом изреке пресуде, а за своју одлуку дао је довољне и јасне разлоге које у потпуности прихвата и овај суд.

По налажењу Апелационог суда, нису основани жалбени наводи тужених да је првостепени суд погрешно ценио њихове мотиве за закључење уговора о поклону, да је тужена М. лошег здравственог и финансијског стања и да је са тог разлога, тужени Н. желео да јој стан поклони а уједно и зато што је купљен њеним средствима 2003. године.

Наиме, уговор о поклону је по својој правној природи добротин уговор, без накнаде и битан елемент тог уговора јесте намера даривања на страни поклонодавца. Мотиви тј побуде које наводе поклонодавца на закључење уговора, субјективне су психолошке појаве и нису садржане у изјави воље, али су саставни део уговора, спојен са основом. Стога, уговор о поклону код кога је побуда за закључење недопуштена, дакле противна принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима, ништав је, сходно чл. 53. ст.3. Закона о облигационим односима.

По налажењу овог суда, првостепени суд је правилном оценом доказа у смислу чл. 8. ЗПП, утврдио да побуда туженог Н. за закључење уговора о поклону, није била добротине природе, усмерена на даривање тужене М. и њено благостање, већ се огледала у томе да се тужиљи убудуће онемогући да заједно са мал. тужиоцима живи у стану који је до тог поклона, представљао имовину туженог Н. Овакав закључак првостепеног суда, правилно је заснован на чињеници да су тужиља и мал. тужиоци, у време закључења уговора о поклону, становали у том стану, да тужени Н., као тадашњи власник, сходно чл. 194. ПЗ, није имао законских могућности да им то право ускрати, а да је непосредно након поклона стана, то покушано од стране тужене М., подношењем тужбе за исељење. Таква побуда за закључење уговора о поклону, да се тужиоцима ускрати право становања, произилази и из исказа туженог Н., у делу у ком је навео да је одлучио да свој стан поклони мајци из разлога

што је тужила поседовала друге непокретности које је издавала трећим лицима. Ово тим пре што тужени своје тврдње, да је поклон учињен зато што је туженој био потребан новац за лечење, нису доказали. Наиме, једини доказ који су тужени пружили на ту околност, јесте извештај да је тужена лечена током 2009. године због тумора и да је отпуштена са клинике у добром општем стању, у ком извештају нема података о трошковима лечења, нити се исти због протека времена може сматрати релевантним. Осим тога, утврђено је и да тужена има друге непокретности у свом власништву и да је корисник пензије, па и по налажењу овог суда, њене лоше материјалне прилике, нису доказане, нити су тужени у наводима током поступка ближе објаснили на који начин би учињен поклон стана, помогао туженој у побољшању истих.

Са изнетих разлога и по налажењу овог суда, побуда за закључење уговора о поклону била је да се тужиоцима онемогући право становања у стану који је био предмет поклона, а што је противно добрим обичајима, принудним прописима и јавном поретку и као такво, недопуштено, па је правилно првостепени суд утврдио да је предметни уговор, ништав.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж 1158/20 од 25.11.2020. године,

Аутори сентенце: Оливера Јовановић, судија Апелационог суда у Нишу, Тамара Станојевић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

ПРЕУЗИМАЊЕ ДУГА

(чл. 446. ст.1 и 2 Закона о облигационим односима)

Преузимање дуга доводи до замене дужника у облигационом односу и претпоставља правни посао којим се постижу два циља: ослобођење дотадашњег дужника обавезе и обавезивање преузимаоца за дуг дотадашњег дужника.

Из образложења:

Тужилац М.К. је оснивач и директор друготужиоца “М” Д.О.О. П., док је тужени В.Н., директор и оснивач привредног друштва “Д” Д.О.О. Л. Парничне странке започеле су пословну сарадњу током 2013. године на пројекту у П., где је предузеће тужиоца било инвеститор, а предузеће туженог, тада под називом ВМ “Д.” Д.О.О. било извођач радова. Током 2016. године, друготужилац је као инвеститор, стамбено пословног објекта

у ... ангажовао предузеће туженог “Д” Д.О.О. за извођење занатских радова, у вези којих радова је закључен уговор. Странке су након провере у финансијским књигама и сравњавањем уплата, постигле договор, да због лоше финансијске ситуације туженог и његовог предузећа сачине Уговор о признању, преузимању и измирењу дуга, који уговор су закључиле дана 29.09.2017. године. Предмет тог уговора је признање и преузимање дуга предузећа “Д.” Д.О.О. Л. од стране туженог лично у износу од 9.000.000,00 динара и 27.860 евра. Тужени је лично на себе преузео обавезу да износ од 9.000.000,00 динара исплати друготужиоцу “М.” Д.О.О., а износ од 27.860 евра да исплати тужиоцу М. За испуњење уговорне обавезе гарантовао је непокретношћу уписаном у листу непокретности бр.5800 КО ..., за коју се сагласио да се изврши упис хипотеке у корист тужиоца.

Одредбом чл.446. ст.1. и ст.2.Закона о облигационим односима прописано је да се преузимање дуга врши уговором између дужника и преузимаоца, на који је пристао поверилац. О закљученом уговору може повериоца известити сваки од њих и свакоме од њих поверилац може саопштити свој пристанак на преузимање дуга.

Преузимање дуга доводи до замене дужника у облигационом односу и претпоставља правни посао којим се постижу два циља: ослобођење дотадашњег дужника обавезе и обавезивање преузимаоца за дуг дотадашњег дужника. Преузимање дуга врши се уговором између дужника и преузимаоца, на који је поверилац пристао, јер када поверилац пристане на преузимање дуга, тиме изражава и своју вољу да чинидбу преузимаоца прихвати као испуњење. Пуноважност уговора условљена је сагласношћу повериоца да се закључи уговор о преузимању.

У конкретном случају, предметни Уговор о признању, преузимању и измирењу дуга закључен је у складу са одредбом чл.446. ЗОО, између дужника - привредног друштва “Д” Д.О.О. Л., чији је директор и оснивач овде тужени и преузимаоца дуга – овде туженог В.Н., а уз сагласност поверилаца, привредног друштва “М.” Д.О.О. П. и М.К. (обзиром да је тужени преузео исплату дуга свог предузећа и гарантовао исплату свог личног дуга). Уговор је закључен добровољно и уз сагласност воља свих уговорних страна.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.2637/2019 од 29.01.2020.године,

Аутор сентенце Мирјана Милутиновић, саветник у Апелационом суду у Нишу

ПРАВО ДОЖИВОТНОГ ПЛОДОУЖИВАЊА

чл. 384.-393. Грађанског законика

Невршење права доживотног плодуюживања титулара у одређеном периоду, не може бити законски разлог престанка истог, јер ниједним правним правилом то није прописано као начин престанка личних службености.

На право плодуюживања не могу се применити одредбе чл. 49.-60. Закона о основама својинскоправних односа, јер су тим одредбама регулисане искључиво стварне службености, а које су по својој правној природи и обележјима другачије од личних права службености.

Из образложења:

Тужилац је унук туженог. Из уговора о поклону непокретности Ов бр. 416/98 од 04.08.1998. године, који је закључен између овде туженог као поклонодавца и његових синова, П. и С., као поклонопримца, утврђено је да је предметним уговором тужени Н. поклатио свом сину П., оцу тужиоца, непокретност-стамбени објекат бр.1 који се налази на кп бр. 1585 и 1586, уписане у ЛН бр. 2194 КО ..., док је у чл. 5. уговора уговорено право доживотног плодуюживања у корист поклонодавца, овде туженог на истој непокретности, на тачно одређеним просторијама и то на једној соби у приземљу и једној на спрату са правом коришћења купатила у приземљу и правом пролаза степеницама и кроз ходник спратног дела. Из уговора о поклону непокретности ОПУ 1519-2016 од 07.11.2016. године, који је закључен између П.М., оца тужиоца и сина туженог, као поклонодавца, и тужиоца поклонопримца, утврђено је да је овим уговором, између осталог, П.М., поклатио тужиоцу исту непокретност-породичну стамбену зграду бр.1 која се сада налази на кп бр. 1585/2, са уговореним правом плодуюживања у корист поклонодавца П. и његове супруге С. Из преписа ЛН бр. 2194 КО ..., утврђено је да је тужилац уписан као власник стамбеног објекта бр.1, из ког објекта се у овој парници тражи иселење туженог, те да је у односу на исти објекат уписана забележба заједничког права плодуюживања у корист П.М. и његове супруге С. М

Како право плодуюживања, као лична службеност, није регулисано позитивним прописима, примењују се правна правила Грађанског законика из 1844. године, на основу Закона о неважности правних прописа донесених пре 6. априла 1944. године и за време непријатељске окупације. На право

плодоуживања не могу се применити одредбе чл. 49.-60. Закона о основама својинскоправних односа, јер су тим одредбама регулисане искључиво стварне службености, а које су по својој правној природи и обележјима другачије од личних права службености.

У смислу правила из одредбе чл 340. Грађанског законика, право доживотног плодуживања стиче се на основу уговора, тестаментa или одржаја. Не постоје законски прописи који предвиђају упис у јавне књиге као обавезан начин конституисања овог права, због чега је, у конкретном случају, супротно жалбеним наводима, ово право у корист туженог настало закључењем пуноважног уговора о поклону непокретности Ов бр.416/98 од 04.08.1998.године, којим уговором су се у чл.5. уговорне стране, тужени у својству поклонодавца и П.М. у својству поклонопримца, сагласили да се на делу имовине којом је тужени располагао овим уговором, буде установљено право доживотног плодуживања у корист туженог.

У смислу правила из чл. 384-393 Грађанског законика, право доживотног плодуживања престаје пропашћу ствари, протеком времена за које је плодуживање установљено, ако је било установљено на одређено време или смрћу титулара права. На престанак права плодуживања, не могу се применити чл. 938. Грађанског законика, тј сада чл. 58. Закона о основама својинскоправних односа, јер се ова правна правила тичу односа власника повласног и послужног добра и примењују се на стварне службености. За разлику од стварних службености, код права плодуживања не постоји повласно добро, исто се везује управо за личност титулара, непреносиво је и ненаследиво, са ког разлога право плодуживања и престаје смрћу титулара уколико је уговорено као доживотно. Стога, невршење права доживотног плодуживања титулара у одређеном периоду, не може бити законски разлог престанка истог, превасходно са разлога што ниједним правним правилом то није прописано као начин престанка личних службености. Са наведених разлога, жалбени наводи којима се истиче да тужени није све време користио спорну непокретност и да је самим тим његово право плодуживања исте престало, неосновани су и без утицаја на правилност и законитост првостепене пресуде.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.4423/2018 од 06.06.2019.године),

Аутор сентенце Мирјана Милутиновић, саветник у Апелационом суду у Нишу.

НЕДОПУШТЕНА ПОБУДА КОД ДОБРОЧИНОГ УГОВОРА**Члан 52 и 53 Закона о облигационим односима**

Недопуштена побуда је супротна принудним прописима, јавном поретку и добрим обичајима, те иста утиче на пуноважност уговора о поклону као доброчиног правног посла, из ког разлога није од утицаја савесност друге уговорне стране. Чињеница да је тужена добила одређене непокретности од тужиоца путем уговора о поклону са прећутним условом да му заузврат роди дете утиче на пуноважност таквог уговора као доброчиног правног посла, имајући у виду да циљ истог није доброчино даривање тужене већ остварење циља који је супротан правилима морала и добрим обичајима.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању од стране првостепеног суда тужилац је као поклонодавац са туженом Б.Б. као поклонопримцем закључио уговор о поклону непокретности, који је оверен пред Општинским судом у Нишу под 2Ов бр. .../02 дана07.2002. год. Предмет уговора су следеће непокретности: кућа у Н. у насељу ..., у ул. Т. бр. ..., на кп бр. ... КО Н.-Ц. К., површине 48 м2, уписана у пл бр. ... КО Н.-Ц. К. и кп бр. ... у мзв ..., површине 22,14 ари, уписана у пл бр. ... КО В., као и ловачка пушка ЦЗ-М75 и путнички аутомобил марке Правноснажном и извршном пресудом Основног суда у Нишу 30П бр. 8240/13 од 06.06.2016. год. утврђена је ништавост овог уговора. Између тужене Б.Б. као поклонодавца и њеног сина, туженог В.В. као поклонопримца закључен је уговор о поклону 1Ов бр. .../2010 дана01.2010. год. са анексом 1Ов бр. .../2010 дана09.2010. год., чији је предмет напред наведена кућа, површине 48 м2 са двориштем површине 306 м2 на кп бр. Такође, између тужене Б.Б. као поклонодавца и њене ћерке тужене Г.Г., као поклонопримца, закључен је уговор о поклону 1Ов бр. .../2010 дана01.2010. год. чији је предмет кп бр. ..., површине 2214 м2 са ванкњижним објектом-викендицом по пл. ... КО Н.-В.

Правилно је првостепени суд утврдио да се тужена Б.Б. укњижила као власник куће у Н., у насељу ..., на кп бр. ... КО Н.-Ц. К. и као власник кп бр. ... КО В. на основу ништавог уговора о поклону, који је оверен пред Општинским судом у Нишу под 2Ов. бр. .../02 дана07.2002. год., а који је закључила у својству поклонопримца са тужиоцем као поклонодавцем. Иако је ништавост овог уговора утврђена правноснажном пресудом Основног суда у Нишу

30П бр. 8240/13 од 06.06.2016. год., сматра се да је уговор ништав од самог закључења, те су неосновани жалбени наводи тужених којима указују да су предметни уговори о поклону које је тужена Б.Б. закључила као поклонодавац, закључени пре него што је утврђена ништавост уговора о поклону на основу кога се тужена Б.Б. представила као власник предметне имовине. Наведено с разлога што ништав уговор не егзистира у правном промету, те се сматра да није ни закључен. Правилно првостепени суд закључује да је у тренутку закључења уговора о поклону 20в. бр. .../02 дана07.2002. год. тужена Б.Б. знала да је исти закључен услед недопуштеног мотива, односно да се ради о недопуштеној побуди која је битно утицала на уговорне стране да закључе такав уговор. Ценећи све изведене доказе правилно је првостепени суд утврдио да је тужена Б.Б. као поклонодавац била несавесна и приликом закључења уговора о поклону са својом децом, туженима В.В. и Г.Г., као и да су В.В. и Г.Г. као поклонопримци били несавесни, будући да су знали да је тужена Б.Б. закључењем ових уговора располагала имовином стеченом по основу ништавог правног посла, а имајући у виду да им је био позната недопуштена побуда тужиоца и тужене Б.Б. за закључење уговора о поклону из 2002. год., односно да је тужилац желео да му тужена Б.Б. роди дете као противчинидбу за примљени поклон, а која побуда је супротна императивним законским прописима, јавном поретку и dobrim обичајима. Туженима је такође било познато да се заједница живота између тужиоца и Б.Б. окончава тиме што је тужена Б.Б. засновала нову заједницу са другом особом, обзиром да су живели у породичној заједници са туженом Б.Б. и том особом у кући коју је туженој Б.Б. поклонио тужилац, те им је морало бити познато и то да је тај уговор предмет спора, односно да је тужилац још 2009. год., пре закључења спорних уговора о поклону, покренуо поступак најпре за раскид уговора о поклону из 2002. год. због грубе неблагодарности, а касније и за утврђење ништавости истог.

Чињеница да је тужена добила одређене непокретности од тужиоца путем уговора о поклону са прећутним условом да му заузврат роди дете утиче на пуноважност таквог уговора као доброчиног правног посла, имајући у виду да циљ истог није доброчино даривање тужене већ остварење циља који је супротан правилима морала и dobrim обичајима. Приликом закључења таквог уговора тужена је знала да је исти ништав због недозвољене побуде, из ког разлога тужена не може бити савесна страна ни приликом закључења предметних уговора о поклону са својом децом, којом отуђује имовину стечену

ништавим правним послом, те је првостепени суд, а супротно жалбеним наводима тужених, правилно применио материјално право када је закључио да се ради о недопуштеном мотиву и код ових уговора у смислу одредбе члана 51 и 52 Закона о облигационим односима, јер је циљ закључења истих осујећење тужиоца у покушају да своју имовину поврати након утврђења ништавости уговора о поклону из 2002. год., а не увећање имовине поклонопримаца - тужених В.В. и Г.Г. Како су тужени В.В. и тужена Г.Г. као њена деца и поклонопримци били упознати са недозвољеним мотивима тужиоца и тужене Б.Б., то исти нису трећа савесна лица којима суд може пружити заштиту остављањем предметних непокретности у њиховој имовини. Поред наведеног одредбом члана 53 ставом 3 Закона о облигационим односима прописано је да уговор без накнаде нема правно дејство и када други уговарач није знао да је недопуштена побуда битно утицала на одлуку његовог сауговарача, те су правне последице исте и у ситуацији да тужени В.В. и тужена Г.Г. нису знали за недопуштену побуду тужене Б.Б.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж бр. 5344/2019 од 19.05.2020. год.

Аутори сентенце: Јадранка Митровски, судија Апелационог суда у Нишу, са вишим судијским саветником Оливером Алексић Цветковић

ОДГОВОРНОСТ ЈЕМЦА БЕЗ ОБЗИРА НА ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА ПО ИЗДАТОЈ МЕНИЦИ

Члан 1004 ст. 2 и ст. 3 Закона о облигационим односима

Одредбе Уговора о кредиту, према којима тужени потписивањем уговора и предајом менице преузима личну и безусловну обавезу, да својом имовином одговара за обавезе главног дужника из уговора о кредиту, има елементе уговора о јемству из члана 1004. став 3. Закона о облигационим односима, због чега обавеза туженог да тужиоцу врати тражени износ проистиче, не само на основу менице, већ и из уговора о кредиту.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, између тужиоца и В.В. закључен је Уговор о кредиту бр. ... дана02.2008. године. Наведено описано потраживање обезбеђено је издавањем пет меница од стране овде туженог Б.Б., као „јемца платца“. Одредбом чл. 7 уговора предвиђени су инструменти

обезбеђења и наплате потраживања, а такође у одељку (ф) предвиђено је, да ће 5 соло меница бити издате од стране јемца платца–солидарног јемца, овде туженог, са овлашћењем банци за њихову попуну. Поменути уговор потписао је лично, као јемац платац, овде тужени. Како извршни дужник, овде тужени, није измирио своје доспеле обавезе према банци, овде тужиоцу, иста је поднела предлог за извршење на основу веродостојне исправе Основном суду у Куршумиљи дана 07.09.2017. године, који је решењем ЗИИв.74/17 од 13.11.2017. године усвојио предлог за извршење, али је решењем истог суда од 27.12.2017. године усвојен приговор извршеног дужника, овде туженог.

Супротно жалбеним наводима туженог, правилно је првостепени суд закључио да истицање околности да је наплата потраживања по издатој меници застарела, не утиче на обавезу дужника, овде туженог по уговору о кредиту, која застарева када застари основна обавеза за коју се јемчи сходно чл.1019 Закона о облигационим односима.

Меница је апстрактна хартија од вредности, која је самостална и независна од основног правног посла, поводом кога је и издата. Код сопствене менице, издавалац исте је уједно и менични дужник, односно лице које треба да исплати износ назначен у меничном писмену, меничном повериоцу. У овој правној ствари, меница као веродостојна исправа издата је у складу са одредбама Закона о меници, и при том садржи све елементе које сопствена меница мора да садржи, предвиђене чл. 107 истог закона, при чему је поједине од ових обавезних меничних елемената унео сам менични поверилац, а на основу овлашћења туженог. Чињеница да је меница поднета на наплату по истеку рока из члана 37. Закона о меници, нема утицаја на одговорност туженог, а на шта се неосновано указује жалбом туженог, с обзиром на то да је он на сопственој бланко меници уписао клаузулу „без протеста“, те се тако обавезао да као издавалац сопствене менице и главни менични дужник износ попуњен у меници плати о доспелости, у смислу чл. 52. и 110. Закона о меници. Одредбе Уговора о кредиту, према којима тужени потписивањем уговора и предајом менице преузима личну и безусловну обавезу, да својом имовином одговара за обавезе главног дужника из уговора о кредиту, има елементе уговора о јемству из члана 1004. став 3. Закона о облигационим односима, због чега обавеза туженог да тужиоцу врати тражени износ проистиче, не само на основу менице, већ и из уговора о кредиту.

Сходно наведеном, обавеза туженог на исплату износа ради чије наплате је одређено предложено извршење, постоји и заснива се на сопственим бланко меницама, које је он издао и потписао и при том овластио банку да их попуни, као и на чињеници да се обавезао као јемац платац, а висина његове обавезе је правилно утврђена, на основу налаза и мишљења вештака економско - финансијске струке. За своју одлуку првостепени суд је дао правилне разлоге, које прихвата и овај суд, те се наводи жалбе туженог о погрешној примени материјалног права оцењују неоснованим, јер је меница садржала све битне елементе, постоји законска претпоставка пуноважности потпуне менице па је на меничном дужнику терет доказивања да је меница попуњена противно основном уговору, што тужени у току поступка није доказао, те овај суд налази да је првостепени суд правилно применио материјално право и то чл. 997. и 1002. Закона о облигационим односима.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж бр. 315/2020 од 11.02.2020. год.

Аутори сентенце: Зорица Стошић, судија Апелационог суда у Нишу, са вишим судијским саветником Оливером Алексић Цветковић

НЕЗАКОНИТ И НЕПРАВИЛАН РАД ПРАВНОГ ЛИЦА

Члан 172 став 1 Закона о облигационим односима

Да би се могло говорити о одговорности правног лица за штету у смислу напред цитиране одредбе, потребно је претходно да се испуне услови за одговорност тог лица за штету коју је његов орган проузроковао трећем лицу. Ти услови су постојање штете (члан 155. Закона о облигационим односима), кривице, да је штетник проузроковао штету намерно или крајњом непажњом (члан 158. Закона) и узрочне везе између предузете радње и настале штете. Незаконитим радом органа сматра се поступање супротно закону, другом пропису или општем акту, као и пропуштање да се исти примене. Неправилан рад органа је чињење или не чињење противно уобичајеном или прописаном начину обављања делатности који штети праву или интересима неког лица.

Из образложења:

Првостепени суд налази да постоји пропуст извршитеља у поступку спровођења извршења, обзиром да је исти извршење морао да спроведе

стриктно на основу Уговора о непосредној продаји, који је за предмет имао само цистерну, а у коме се нигде не помиње азотна станица, коју је извршитељ такође предао купцу, иако су били присутни и представници тужиоца и указали извршитељу, да иста представља својину овде тужиоца. Суд налази, да извршитељ није уложио потребну пажњу у обављању своје дужности, да на прецизан начин утврди шта је предмет извршења, а омогућио је, да извршењу присуствују и лица која нису требала да буду присутна (директор Ј.Ј., К.К., директор Л.Л., Љ.Љ. и бивши директор Ђ.Ђ., М.М.), па налази да одговорност за насталу штету сноси и суд, јер цистерна која је била означена у судском решењу није имала ближе ознаке, па је овакво поступање суда и судског извршитеља у узрочно – последичној вези са насталом штетом на страни тужиоца, па усваја тужбени захтев тужиоца у целости.

Чланом 108 ст. 1 Закона о извршењу и обезбеђењу је прописано, право трећег лица, које тврди да на предмету извршења има неко право које спречава извршење, да може јавном извршитељу поднети приговор којим захтева да се извршење утврди недозвољеним на том предмету и да је чл. 111 истог закона прописано, да треће лице може у року од 30 дана од дана пријема решења о одбацивању или одбијању приговора да покрене парнични поступак против извршног повериоца ради утврђења да је извршење на предмету недозвољено, као и да се својинска тужба, за повраћај ствари у сваком случају може поднети против лица код кога се ствар налази и независно од прописаних рокова у овом поступку и независно од подношења тужбе, а покретање парничног поступка не одлаже извршење.

Имајући у виду предње одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу, изостала је оцена првостепеног суда, од каквог је значаја за одговорност тужене околност, да тужилац није покушао да своје право оствари у складу са предњим одредбама, тј. да захтева повраћај ствари, па у том смислу и оцена одговорности тужене.

Наиме, за одговорност тужене у овој правној ствари релевантна је одредба чл. 172 ст. 1 Закона о облигационим односима, којом је прописано да правно лице одговора за штету коју његов орган проузрокује трећем лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција.

Да би се могло говорити о одговорности правног лица за штету у смислу напред цитиране одредбе, потребно је претходно да се испуне услови за одговорност тог лица за штету коју је његов орган проузроковао трећем лицу. Ти услови су постојање штете (члан 155. Закона о облигационим односима), кривице, да је штетник проузроковао штету намерно или крајњом непажњом

(члан 158. Закона) и узрочне везе између предузете радње и настале штете. Незаконитим радом органа сматра се поступање супротно закону, другом пропису или општем акту, као и пропуштање да се исти примене. Неправилан рад органа је чињење или не чињење противно уобичајеном или прописаном начину обављања делатности који штети праву или интересима неког лица.

Стога закључак суда да постоји кривица тужене за насталу штету и узрочно последична веза између настале штете и пропуста у раду органа тужене, за сада нема утемељење у утврђеном чињеничном стању, јер околност да је приликом спровођења поступка извршења дошло до предаје опреме купцу (која је на лицу места била спојена са цистерном, која је била предмет продаје), сама по себи не може водити закључку да на страни тужене постоји незаконит или неправилан рад органа тужене, имајући у виду да је Законом о извршењу и обезбеђењу прописан правни пут којим треће лице може остварити своје право, уколико је у поступку извршења исто повређено.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж бр. 669/2020 од 03.03.2020. год.

Аутори сентенце: Зорица Стошић, судија Апелационог суда у Нишу, са вишим судијским саветником Оливером Алексић Цветковић

ЗА ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ОДГОВАРА САМО ТО ДРУШТВО А НЕ И ЊЕГОВИ ЧЛАНОВИ СВОЈОМ ЛИЧНОМ ИМОВИНОМ

**Члан 15 и члан 104. ст.3. Закона о привредним друштвима
(„Сл.гл. РС“ бр.125/04)**

За преузете обавезе према трећим лицима одговара само друштво и то својом целокупном имовином. Ако је друштво пословало са губицима и има обавезе према трећим лицима, члан друштва може изгубити само оно што је као улог уложио у привредно друштво, а не и своју осталу имовину која је одвојена од имовине друштва са ограниченом одговорношћу.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужилац и привредно друштво В.В. д.о.о. В. били су у пословном односу по основу Уговора бр.... од5.1992.

године и Анекса уговора бр.... од4.1993. године. Тужени – противтужиоци су у д.о.о. „В.В.“ били чланови друштва, а тужена А.А. је била и лице овлашћено за заступање. Пресудом Трговинског суда у Лесковцу П.бр.292/07 од 14.4.2009. године делимично је усвојен тужбени захтев привредног друштва „В.В.“ доо В., као тужиоца и обавезан тужени ХЕ „Ђердап“ доо Кладово на исплату износа од 75.994,99 динара са затезном каматом почев од 24.1.1994. године. Истом пресудом делимично је усвојен и противтужбени захтев туженог ХЕ „Ђердап“ доо Кладово за исплату износа од 270.516,00 динара и утврђено је да је раскинут уговор бр.... од5.1992. године и Анекс истог уговора од4.1993. године. На основу наведене правноснажне и извршне исправе, од стране „В.В.“ доо В., у својству повериоца, инициран је поступак извршења током ког је поверилац наплатио своје потраживање са каматом која је обрачуната за период од 24.1.1994. године до 5.7.2010. године. Такође, и тужени ХЕ „Ђердап“ доо Кладово, наплатио је потраживање по истој пресуди у износу од 270.516,00 динара са каматом која је обрачуната за период од 21.4.2000. године до 15.7.2010. године. Према наводима тужиоца, извршење је спроведено у корист „В.В.“ доо Л. а тужени су, након наплате незаконито обрачунате камате конформном методом, увећали своју имовину на рачун умањења имовине тужиоца, односно да су се неосновано обогатили наплатом камате која је незаконито обрачуната. Према наводима тужених – противтужилца тужилац је у обавези да им, на име разлике више обрачунате камате применом конформне методе на износ од 270.516,00 динара, исплати износ од 2.199.047,47 динара као и да им, на име штете, због нереализованог уговора бр.869 од 25.5.1992. године исплати износ од 33.153.221,89 динара, све са припадајућим каматама.

Неосновани су жалбени наводи тужиоца да су тужени, као члан и директор привредног друштва «В.В.» доо В., пасивно легитимисани у конкретној правној ствари јер су исти, након наплате незаконито обрачунате камате у поступку извршења по решењу о извршењу И.бр.254/10 од 30.6.2010. године, располагали средствима тужиоца и на тај начин увећали своју имовину на рачун тужиоца као и да су обуставили плаћање у непрекидном трајању од 3 године са стањем на дан 31.3.2010. године. Ово из разлога јер је поступак извршења И.бр.254/10 инициран по предлогу привредног друштва »В.В.« доо Л., а на основу извршне исправе Трговинског суда у Лесковцу П.бр.292/07 од 14.4.2009. године. Извршење се спроводило у корист рачуна доо «В.В.», као самосталног привредног субјекта који је, као правно лице,

имало сопствену имовину и обавезе. Такође, и обавеза привредног друштва «В.В.» доо В., која је утврђена наведеном правноснажном пресудом, измирене је у поступку извршења.

У периоду спровођења извршења тужени Б.Б. је био оснивач и члан наведеног привредног друштва а тужена А.А. је била лице овлашћено за заступање. Према одредби чл. 104. ст.3. Закона о привредним друштвима («Сл. гл. РС» бр.125/04) који је био у примени у периоду споровђења извршења по решењу о извршењу од 30.6.2010. године, члан друштва с ограниченом одговорношћу не одговара за обавезе друштва осим до износа неунетог улога у имовину друштва. Наведено значи, да члан друштва не одговара за обавезе друштва, већ само сноси ризик пословања друштва до висине свог улога. За преузете обавезе према трећим лицима одговара само друштво и то својом целокупном имовином. Ако је друштво пословало са губицима и има обавезе према трећим лицима, члан друштва може изгубити само оно што је као улог уложио у привредно друштво, а не и своју осталу имовину која је одвојена од имовине друштва са ограниченом одговорношћу. Одвојеност имовине друштва од личне имовине чланова друштва чини да повериоци друштва нису истовремено и повериоци чланова друштва. У конкретном случају, тужбом се тражи наплата одређеног износа по основу личне одговорности тужених.

У конкретном случају из утврђеног чињеничног стања произилази да пословни однос између тужиоца и привредног друштва «В.В.» доо В., чији су члан и директор друштва тужени, није могао код тужиоца да створи привид привредног и правног индетитета тужених са привредним друштвом јер злоупотреба привредног друштва односно пробијање правне личности подразумева чињење преварне радње која мора бити доказана. Терет доказивања пробоја правне личности је на страни тужиоца који, у конкретном случају, није суду доставио адекватне доказе на ове околности у смислу одредбе чл. 231. ст.2. ЗПП. Наиме, супротно тврдњама тужиоца да су тужени након спровођења извршења располагали новчаним средствима тужиоца и на тај начин умањили имовину тужиоца из правноснажне одлуке Трговинког суда у Лесковцу П.бр. 292/07 од 14.4. 2009. године произилази да је спорни пословни однос тужиоца и «В.В.» доо В., правноснажно решен доношењем наведене пресуде која је у поступку пред судом и спроведена у складу са тада важећим Законом о извршном поступку. Имајући у виду наведено правилно је првостепени суд нашао да је тужбени захтев тужиоца неоснован с обзиром да, у конкретном случају, нема правног основа за одговорност тужених при-

меном одредбе чл. 15. Закона о привредним друштвима којом је регулисан институт пробоја правне личности и одговорности тужених према тужиоцу као привредном друштву. С тим у вези нема правног основа за одступање од правног принципа из чл. 104.ст.3. Закона о привредном друштву да члан друштва са ограниченом одговорношћу не одговара за обавезе друштва осим до износа унетог улога у имовину друштва. Сходно свему напред наведеном и неосновани су жалбени наводи тужиоца којима се тврди да су тужени наплатом камате принудним путем, као члан и директор друштва увећали своју имовину на рачун тужиоца и да суд, у складу са одредбом чл. 15. Закона о привредним друштвима, није потпуно утврдио чињенично стање.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж бр. 1111/2020 од 08.07.2020. год.

Аутори сентенце: Оливера Јовановић, судија Апелационог суда у Нишу, са вишим судијским саветником Оливером Алексић Цветковић

УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

члан 196 став. 1. Закона о наслеђивању

Сагласности надлежног органа старатељства представља конститутивни услов за пуноважност уговора о доживотном издржавању у ситуацији када се као давалац издржавања појављује лице које се као геронто домаћица стара о примаоцу издржавања.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, сада покојна Н. П., бивша из ..., као прималац издржавања, са туженом, као даваоцем издржавања, закључила је уговор о доживотном издржавању, потврђен пред Основним судом у Мајданпеку ОПУ 307/17 од 28.09.2017. године, а предмет уговора је стан у ..., у ул. ... бр. ..., са свим покретним стварима у њему, као и заостале пензије и све друге новчане надокнаде које се у тренутку смрти затекну на име примаоца издржавања. Тужена је била запослена као геронто домаћица, у ком својству је бринула о сада покојној Н. П., а да претходно није добијена сагласност Центра за социјални рад за закључење предметног уговора.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је усвојио главни тужбени захтев за утврђење ништавости уговора о доживотном

издржавању, између осталог и са образложењем да тужена, као лице које се у оквиру свог занимања, односно делатности старала о примаоцу издржавања, није имала потребну сагласност надлежног органа старатељства за закључење овог уговора, у смислу члана 196. Закона о наслеђивању

Неосновани су жалбени наводи тужене којима се указује да је уговор о доживотном издржавању закључен јер је између ње, као даваоца издржавања, и пок. Н. П., као примаоца издржавања, постојао пријатељски однос много пре него што је она добила задужење да се као геронто домаћица стара о сада пок. Н. П.. Ово са разлога што искази саслушаних сведодока, иако су сретали тужену и пок. Н. П., не потврђују чињеницу да је уговор закључен независно од професије тужене, а у ситуацији када је за закључење уговора била потребна сагласност надлежног органа старатељства, као конститутивног услова из члана 196. став. 1. Закона о наслеђивању.

(Из пресуде Апелациног суда у Нишу 42Гж 1135/20 од 28.05.2020. године)

Аутори сентенце: Милица Златковић, судија Апелациног суда у Нишу са судијским помоћником Мишом Вујичићем.

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ДИСКРИМИНАТОРСКОГ ПОСТУПАЊА

члан 21 Устава Републике Србије

и члан 2, члан 4 и члан 23 Закона о забрани дискриминације

За судску заштиту од дискриминације потребно је утврдити неједнако поступање у односу на неко лично својство, а ако се неједнако поступање утврди, потребно је да не постоји објективно и разумно оправдање за неједнако поступање, које се процењује по томе да ли се учињеним разликовањем разумно тежило легитимном циљу, ако такав циљ постоји, да ли постоји однос сразмерности између учињеног разликовања и циља коме се тежило.

Из образложења:

Према чињеничном стању утврђеном првостепеном пресудом, тужени, као осигуравач и Удружење В.В., као уговарач осигурања, дана 09.12.2013. године закључили су уговор о осигурању чланова уговораца у складу

са општим условима осигурања лица од последица несрећног случаја и допунских услова за колективно комбиновано осигурање пензионера и уговореним осигуравајућим покрићем у складу са понудом осигурања. На основу овог уговора, а као члан уговарача осигурања, тужила је била осигураник туженог. Након што је Закон о осигурању (Сл. гласник РС бр.139/14) ступио на снагу 26.12.2014. године и почео да се примењује од 27.06.2015. године, тужени је са Удружењем В.В., дана 07.09.2018. године закључио Анекс 1 наведеног уговора, којим је измењен наведени уговор. У наведеном Анексу, између осталог, наведено је да је разлог измене уговора промена прописа у области осигурања по којој се осигурани ризик због болести, који је предмет наведеног осигурања, сврстава у врсту животног осигурања, а не неживотног осигурања, како је то било у моменту закључења уговора. Наведеним Анексом допуњена је уговорна одредба о моменту престанка осигурања за сваког појединог осигураника и то тако што је, поред већ уговорених разлога престанка осигурања, одређено да исто престаје, без обзира на колико је уговорено трајање осигурања, у року од 24 часа од дана када осигураник наврши 85 година живота. Анексом је уговорено и да својство осигураника престаје свим осигураницима који су у моменту закључења истог навршили 85 година живота. У складу са Анексом, тужени је обавештењем од 11.09.2018. године обавестио Удружење В.В. о наведеним променама услова осигурања и да, услед истих, својство осигураника престаје са навршених 85 година старости, а уколико су осигураници већ навршили 85 година старости, осигурање ће престати 01.10.2018. године. Према допунским условима туженог за колективно осигурање пензионера од последица несрећног случаја (незгоде), који се примењују од 28.12.2015. године, могу се осигурати пензионери до 85. године живота без обзира на њихово здравствено стање и без плаћања повишене премије – способност за осигурање, као и да уговор о осигурању престаје за сваког осигураника у поноћ оног дана када истекне година осигурања у којој осигураник наврши 85 година живота или кад уговор престане по неком другом основу. Тужила сматра, да је на наведеним изменама услова осигурања, дискриминисана на основу своје старосне доби и да су јој истим, по годинама старости, ограничена права, те услед тога душевно пати и трпи штету.

Са изложеног, за судску заштиту од дискриминације потребно је утврдити неједнако поступање у односу на неко лично својство, а ако се неједнако поступање утврди, потребно је да не постоји објективно и разумно оправдање

за неједнако поступање, које се процењује по томе да ли се учињеним разликовањем разумно тежило легитимном циљу, ако такав циљ постоји, да ли постоји однос сразмерности између учињеног разликовања и циља коме се тежило.

Имајући у виду наведене критеријуме, по оцени Апелационог суда, правилан је закључак првостепеног суда да у конкретном случају изменама услова раније уговореног осигурања ризика смрти због болести и то тако што исто престаје када осигураник наврши 85 година старости, тужилца није дискриминисана и да јој овим изменама због њених година живота, односно старости, није повређено ниједно њено људско или мањинско право зајамчено Уставом, а што је неопходна претпоставка за утврђење повреде уставног начела забране дискриминације.

Наиме, основним уговором о осигурању, по коме је тужилца имала својство осигураника, уговорено је, између осталог, осигурање ризика смрти услед болести. Према Закону о осигурању (Сл. гласник РС бр. 55/2004, 70/2004 - испр., 61/2005, 61/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 101/2007, 63/2009 - одлука УС, 107/2009, 99/2011 и 119/2012) који је важио у време закључења овог уговора, наведени осигурани ризик сврставао се у неживотно осигурање, док се овај ризик након измена Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр.139/14), које се ступиле на снагу 23.12.2014. године, а почеле да се примењују 27.06.2015. године, сврстава у животно осигурање.

Тужени је спорне измене услова осигурања извршио након што су ступили на снагу и почели да се примењују измењени прописи у области осигурања, којим је наведени осигурани ризик, за разлику од раније важећих правила, сврстан у животно осигурање. С обзиром да су приликом уговарања различитих врста животног осигурања године старости осигураника околност од значаја за оцену ризика, то је за наведене спорне измене уговора о осигурању, односно ограничење осигурања ризика смрти услед болести на осигуранике до 85 година старости и то под раније уговореним општим условима, постојало објективно и разумно оправдање с легитимним циљем.

Дакле, правилан је закључак првостепеног суда да описаним поступањем туженог није било неоправданог прављења разлике између тужилце у односу на лица млађа од ње, а која је заснована на старосном добу, већ је истим само легитимно, а у складу са изменама прописа о осигурању и одредбама Закона о облигационим односима којима је регулисано осигурање, извршена

процена ризика осигураног случаја, као будућег, неизвесног догађаја, који је независан од искључиве воље уговарача, и, сходно тој процени, сразмерно су измењени раније уговорени услови осигурања ризика смрти услед болести.

Са изложеног, тужени се кретао у оквиру законом прописаних овлашћења када је наведеним Анексом Уговора о осигурању изменио раније уговорене услове осигурања, па је спорна измена услова дозвољена и оправдана јер године живота осигураника, за животно осигурање, представљају чињеницу која је од значаја за процену и мерење ризика осигурања и од утицаја су на услове под којима неком лицу може бити понуђено осигурање, односно на престанак осигурања под ранијим условима, те су неосновани жалбени наводи да ограничења у погледу година живота осигураника нису прописана законом, већ спадају у пословну политику туженог, и да је, стога, прописивањем спорних услова тужени извршио дискриминацију у односу на тужену према њеном личном својству.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж бр. 959/2020 од 19.05.2020. год.

Аутори сентенце: Зорица Стошић, судија Апелационог суда у Нишу, са вишим судијским саветником Оливером Алексић Цветковић

ДОПУСТИВОСТ ПРЕДЛОГА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ У ПОСТУПЦИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

На предлог за одређивање привремене мере која се односи на спречавање дискриминаторског поступања примењује се одредба чл.44. ст.1. Закона о забрани дискриминације, којом је изричито регулисана привремена мера у поступцима за заштиту од дискриминације. Сходно наведеној законској одредби, предлог за одређивање привремене мере у овим поступцима може се поднети само уз тужбу, у току поступка или по окончању поступка док не буде споредено извршење. Ако би овакав предлог био поднет пре подношења тужбе, исти би био недопуштен и као такав би га требало одбацити.

„ Чланом 41 ст.1 и 2 Закона о забрани дискриминације прописано је, да свако ко је повређен дискриминаторским поступањем има право да поднесе тужбу суду и да се у поступку сходно примењују одредбе Закона

о парничном поступку. Чланом 43 истог закона прописано је, да се тужбом може тражити: забрана извршења радње од које прети дискриминација, забрана даљег вршења радње дискриминације, односно забрана понављања радње дискриминације; утврђење да је тужени дискриминаторски поступао према тужиоцу или другоме; извршење радње ради уклањања последица дискриминаторског поступања; накнада материјалне и нематеријалне штете и објављивање пресуде донете поводом неке од тужби из тач. 1-4. овог члана. Чланом 44 наведеног закона прописано је, да тужилац може уз тужбу, у току поступка, као и по окончању поступка, све док извршење не буде спроведено, захтевати да суд привременом мером спречи дискриминаторско поступање ради отклањања опасности од насиља или веће ненакнадиве штете. У предлогу за издавање привремене мере мора се учинити вероватним, да је мера потребна да би се спречила опасност од насиља због дискриминаторског поступања, спречила употреба силе или настанак ненакнадиве штете.

Законом о забрани дискриминације у ниједној одредби није прописана сходна примена Закона о извршењу и обезбеђењу, нити Закон о парничном поступку који се у поступцима за заштиту од дискриминације сходно примењује, то прописује. Стога се у односу на предлог за одређивање привремене мере због дискриминације могу примењивати само одредбе Закона о забрани дискриминације, којим је регулисана судска надлежност и поступак ради заштите од дискриминације, па и издавање привремених мера. Чак и када би било места примени Закона о извршењу и обезбеђењу, као закона који једини на општи начин регулише обезбеђење потраживања у чл.414-426 и поступак одређивања привремених мера у одребама чл. 447-460, свакако одредбе тог закона не би могле да дерогирају примену изрчите одредбе чл. 44 ст. 1 Закона о забрани дискриминације, којим је јасно прописано, да тужилац може само уз тужбу, у току поступка и по окончању поступка, док извршење не буде спроведено, да захтева да суд привременом мером спречи дискриминаторско поступање. Сходно томе, погрешан је став првостепеног суда, да се предлог за одређивање привремене мере која се односи на спречавање дискриминаторског поступања може поднети и пре поднете тужбе, па је у погледу она извршна дужника, предлог за одређивање привремене мере недопуштен. “

Решење Апелационог суда у Нишу, Гж 245/20 од 22.01.2020. године,

Судија Зорица Стошић са судијским помоћником Маријом Фехир

ЗАШТИТА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ**Члан 197 Породичног закона**

За одлуку суда о захтеву тужиоца, Центра за социјални рад, за утврђење да је тужени према својој супрузи починио физичко и психичко насиље, није одлучна чињеница, да ли је супруга туженог - жртва насиља у поступку пред належним органима негирала догађај у коме се десило насиље, већ се одлука суда о постојању насиља мора заснивати на оцени свих релевантних доказа.

Из образложења:

У конкретном случају, правилан је закључак првостепеног суда, да је тужени према својој супрузи сада пок. Мирјани, испољио понашање којим је угрозио њен телесни интегритет, душевно здравље и спокојство, а које се може окарактерисати као психичко и физичко насиље, због чега скуп свих поступака туженог представља недозвољено понашање на начин који се сматра насиљем у породици по чл.197. Породичног закона.

Нису основани жалбени наводи туженог којима се побија правилност утврђеног чињеничног стања и истиче да је исто контрадикторно исказу сада пок. Мирјане датом у кривичном поступку, у ком се иста изјаснила да овде тужени није вршио насиље према њој, као и да не осећа страх и угроженост.

Ово из разлога што је првостепени суд правилном оценом изведених доказа у смислу одредбе чл.8 ЗПП-а, и то извештаја ПУ Врање, ПС Трговиште бр. 6/2017 од 24.07.2017. године и записника Центра за социјални рад у Трговишту од 24.07.2017. године, из којих доказа произилази да се сада пок. Мирјана непосредно након критичног догађаја изјаснила да је тужени вршио насиље према њој и тражила заштиту од надлежних органа, као и потврде Здравственог центра Трговиште од 24.07.2017. године о физичким повредама сада пок. Мирјане, правилно утврдио чињенично стање, да је тужени критичном приликом према својој супрузи испољио физичко и психичко насиље тако што претукао дрветом, наневши јој видљиве повреде, крвне подливе испод десног ока, у пределу лакта леве руке, малог прста на десној нози, дуж целих леђа, изазивајући код исте осећај напетости, немира и страха, а које радње према свим субјективним и објективним околностима представљају понашање којим се угрожава телесни интегритет, душевно здравље и спокојство и квалификују се као насиље у породици у смислу

чл. 197 ст.2. тач.1 и 6. Породичног закона. Околност да је супруга туженог, као жртва насиља, по одређеном протеклу времена променила своје виђење критичног догађаја и на другачији начин се изјаснила у исказу датом у кривичном поступку, не доводи у сумњу правилан закључак првостепеног суда о постојању насилничког понашања туженог.

Жалбени наводи, да суд није узео у обзир психичко стање сада пок. Мирјане и однос туженог према њој, да је једино он бринуо о њеном здрављу и редовно са њом одлазио на лекарске прегледе, неосновани су и без утицаја на другачији исход овог поступка при утврђеном чињеничном стању да је тужени критичном приликом испољио недозвољено понашање према сада пок. Мирјани.

Из Пресуде Апелационог суда у Нишу 32 Гж2. бр.98/20 од 25.02.2020. год.

Аутор сентенце Зорица Стошић, судија Апелационог суда у Нишу

ДЕТЕ МОРА ИМАТИ НАЈМАЊЕ ТАКАВ НИВО ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА КАКАВ УЖИВА И ДУЖНИК ИЗДРЖАВАЊА

Члан 162. ст. 3. Породичног закона

Одлучујуће чињенице приликом оцене могућности једног од родитеља да доприноси издржавању малолетног детета су висана зараде коју остварује и друге материјалне могућности, здравствена и радна способност, односно могућност додатног радног ангажовања, обавеза издржавања других лица, стандард живота и трошкови подмирења основних животних потреба.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, парничне странке су закључиле брак дана ...07.2014. године, пред матичном службом Општине В. Х. Из брака имају једно малолетно дете, кћер В.В., рођену дана ...04.2015.године у Л., Ш. Заједница живота између странака престала је у децембру 2016. године и након тога није успостављена. Мал. В.В. од престанка заједнице живи са мајком у Ш., а са њима у заједници живи и тужиљин син из првог брака који има осам година. Правноснажним делом првостепене пресуде

у овом спору разведен је брак странака, а мал. В.В. поверена је мајци на самостално вршење родитељског права и уређен је начин одржавања личних односа мал. В.В. и туженог, као оца у складу са налазом и мишљењем Центра за социјални рад у В. Х. Мал. В.В. има четири године, а с обзиром на узраст, њене социјалне и образовне потребе су још увек минималне. Утврђено је да тужила није доказала да мал. В.В. похађа вртић. У налазу и мишљењу судског вештака економско-финансијске струке Момчила Аритоновича, наведено је да би висина доприноса туженог за издржавање мал. В.В. износила 13.296,50 динара, ако би се исти одређивао на основу висине месечне накнаде за издржавање деце и омладине коју прописује Центар за социјални рад у В. Х., односно, износила би 20.431,57 динара, ако би се исти одређивао на основу висине нето зараде туженог. Суд је проценио да је за подмирење потреба мал. В.В. потребно издвојити износ од 15.000,00 динара месечно. Тужила је у радном односу, као медицинска сестра – инструментар и остварује редовне месечне приходе у виду зараде, и то: за месец април 2018.године износ од 4.912,15 швајцарских франака, за мај 2018.године износ од 4.744,25 швајцарских франака и за јун 2018.године износ од 4.613,50 швајцарских франака. Тужени има 32 године и живи у В. Х., у породичној кући свог оца, у заједници са оцем, његовом супругом и сестром. По занимању је машински техничар. Током овог поступка, засновао је радни однос код Г.Г., на радном месту инкасанта, где остварује нето зараду у месечном износу од 40.454,50 динара. Не поседује непокретну имовину. Здрав је и радно способан.

Неосновано се жалбом туженог указује да је износ од 15.000,00 динара на име доприноса за издржавање мал. В.В. превисоко одређен, јер је првостепени суд пропустио да цени све чињенице у вези могућности туженог да доприноси издржавању мал. В.В. Наведено из разлога, што су материјалне могућности туженог да доприноси издржавању детета, правилно утврђене, јер је првостепени суд приликом утврђења висине доприноса од чињеница ценио, да је тужени радни однос засновао током овог поступка, да остварује зараду у висини од 40.454,50 динара, да живи у заједници са оцем и његовом супругом и сестром, али и чињеницу да као млада, здрава и радно способна особа мора да нађе законит извор прихода којим ће обезбедити егзистенцијалне потребе мал. В.В. При том, сагледане су и могућности тужиле, као другог родитеља, која је у радном односу и запослена као медицинска сестра у Ш. са приходима од око 4.700 швајцарских франака, уз чињеницу да се стандард живота странака разликује не само по висини

месечних примања на име зараде, већ и због разлике у висини трошкова подмирења основних животних потреба, с обзиром да странке раде и живе у различитим државама.

У контексту наведеног, Апелациони суд налази да одређени износ издржавања од 15.000,00 динара месечно, за мал. В.В., сходно њеном узрасту и потребама, као и нивоу животног стандарда туженог, као дужника издржавања, представља адекватну суму чијим давањем неће бити угрожена његова егзистенција, а уз допринос тужиле, као мајке, у издржавању мал. В.В., биће испоштован и чл. 162. ст. 3. Породичног закона да се деци омогући најмање такав ниво животног стандарда какав ужива и дужник издржавања. Стога је првостепени суд правилно одбио захтев тужиле за већи износ од досуђеног а до траженог износа од 20.000,00 динара за мал. В.В., јер је у тренутној ситуацији неоснован и превисоко постављен, с обзиром на узраст мал. В.В., материјалне могућности туженог и утврђену минималну суму издржавања од стране надлежног министарства за породичну заштиту.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж2 бр. 239/2020 од 01.07.2020. год.

Аутори сентенце: Оливера Јовановић, судија Апелационог суда у Нишу, са вишим судијским саветником Оливером Алексић Цветковић

ДЕЛИМИЧНО ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Несавесно вршење родитељско права, подразумева свако понашање родитеља које није мотивисано бригом и пажњом о детету, односно које није усмерено на најбољи интерес детета.

чл. 82. Породичног закона

Из образложења:

Једно од основних права и дужности родитеља јесте да одлучују о питањима која битно утичу на живот детета. Међутим, то право није апсолутно, већ се родитељ може лишити тог права уколико га врши несавесно и уколико би то било у најбољем интересу детета, обзиром да интерес детета има примарну заштиту у породичним споровима. Несавесно вршење родитељског права, подразумева свако понашање родитеља које

није мотивисано бригом и пажњом о детету, односно које није усмерено на најбољи интерес детета.

По налажењу овог суда, тужени З. Д., није испољио понашање које се може окарактерисати као несавесно вршење родитељског права, нити би његово делимично лишење родитељског права у погледу одлучивања о питању промене пребивалишта мал. детета, било у најбољем интересу мал. А.

Наиме, оценом изведених доказа, овај суд је утврдио да између родитеља мал. А., постоје тешкоће у комуникацији, што је за последицу имало и то да се питање промене пребивалишта мал. А., између њих првобитно није могло расправити на споразуман и заједнички начин у смислу чл. 78. ст.3. Породичног закона, али да је у коначном, то питање решено давањем сагласности туженог тужиљи за промену пребивалишта мал. А. из ...у ... Тачно је да тужени првобитно, није желео ту сагласност да да тужиљи, али по оцени овог суда, такво његово понашање није било несавесно, већ засновано на забринутости о сопственом детету и праву да као родитељ, одлучује о том питању на савестан начин. Тужени је непосредно затим изразио спремност за договор по том питању са тужиљом, у ком смислу се изјасио и пред Центром за социјални рад, а у коначном је сагласност и дао изјавом пред Јавним бележником. По оцени овог суда, таквим поступањем, тужени није угрозио интерес мал. А., нити постоји бојазан да би то учинио убудуће, обзиром да његове родитељске компетенције, нису доведене у сумњу, показује спремност и жељу да врши своја родитељска права и обавезе и свестан је потреба мал. А., између осталог њеног права на развој и образовање. Мишљење је овог суда да је у најбољем интересу мал. детета да о битним питањима које утичу на њен живот и то питању промене њеног пребивалишта, родитељи наставе да одлучују заједнички, па је са тог разлога, овај суд одбио као неоснован тужбени захтев тужиље за делимично лишење родитељског права туженог.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2 267/20 од 01.10.2020. године,

*Аутори сентенеце: Никола Пржић, судија Апелационог суда у Нишу,
Тамара Станојевић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу*

**ДУЖНОСТ СУДА У ПОРОДИЧНИМ СПОРОВИМА
ДА СЕ СТАРА ДА ДЕЦА СТАРИЈА ОД 10 ГОДИНА
ИЗРАСЕ СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ И
ДОБИЈУ СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊА
чл.266. ст.3. тач.1, 2 и 3. Породичног закона**

Када се у парници као тужиоци јављају деца која су навршила више од 10 година суд је дужан да их саслуша, да се стара да добију све потребне информације и обавештења која су им потребна, да им дозволи да непосредно изразе своје мишљење и да мишљењу деце посвети дужну пажњу у складу са њиховим годинама и зрелашћу ради утврђења разлога и мотива због којих деца не желе контакт са оцем.

Из образложења:

Мал. М. и мал. Е. рођене су у ванбрачној заједници туженог-противтужиоца и и мајке Х. Пресудом Општинског суда у Нишу П 3133/2009 од 27.05.2009. године, донетој по престанку ванбрачне заједнице родитеља, мал. деца поверена су мајци на самостално вршење родитељског права уз обавезу оца да доприноси њиховом издржавању са по 1.000,00 динара месечно за свако дете. Након смрти мајке, 05.02.2015. године, деца су по заједничком договору туженог-противтужиоца и бабе и деде по мајци прешла привремено да живе код бабе и деде, а на основу решења Центра за социјални рад баба мал. деце Љ.К. из ... одређена је за њиховог привременог старатеља. На основу налаза и мишљења Центра за социјални рад од 16.11.2018. године утврђено је да тужиле не желе да имају контакте са оцем јер није долазио да их посећује, да је често викао на њих и да није бринуо о њима и изразиле су жељу да и даље живе код бабе и деде и како се тужени није одазивао позивима Центра да користи услуге саветовалишта како би ојачао родитељске капацитете Центар је мишљења да туженог треба делимично лишити родитељског права.

У конкретном случају тужени-противтужилац саслушан као парнична странка указивао је на лоше односе између њега и привременог старатеља деце, односно да су баба и деда по мајци утицала на децу да формирају негативан став и мишљење према оцу, на шта указује и сада у жалби, па је првостепени суд, у циљу заштите најбољих интереса деце, сходно одредби чл. 266. ст. 1. Породичног закона, пре свега био дужан да у смислу одредбе 266. ст. 2. Породичног закона испита да ли су деца заступана на одговарајући начин од стране бабе по мајци

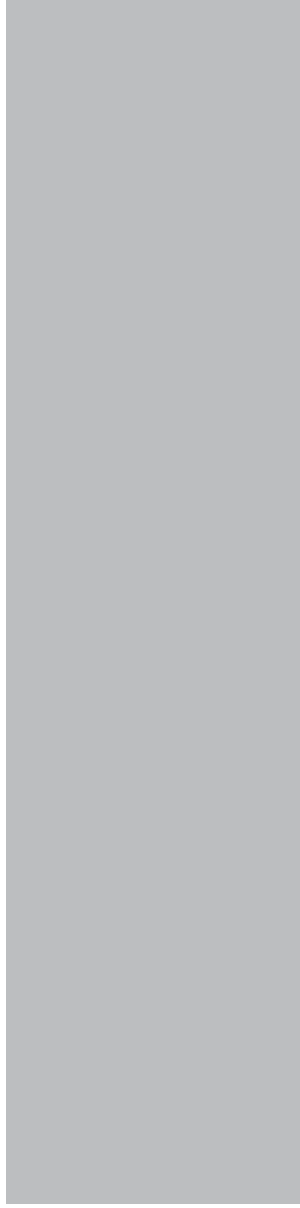
Љутвије Кадријевић, као привременог старатеља, и у вези са тим да ли је било основа да се, због наведених околности, малолетној деци постави привремени заступник, сходно одредби чл. 266. ст.2. Породичног закона.

Како се у конкретном случају ради о деци која су навршила више од 10 година, мал. М.И. рођена је дана 14.03.2004. године, а мал. Е.И. дана 12.10.2007. године, а која се у парници јављају као тужиоци, то је првостепени суд био дужан да децу саслуша у поступку, да се стара да деца добију све потребне информације и обавештења која су им потребна, да дозволи деци да непосредно изразе своје мишљење и да мишљењу деце посвети дужну пажњу у складу са годинама и зрелошћу, чл.266. ст.3. тач.1,2 и 3. Породичног закона., ради утврђења разлога и мотива због којих деца не желе контакт са оцем, а ради процене да ли у конкретном случају има несавесног вршења родитељског права од стране туженог, све у циљу правилне примене одредбе чл.82. Породичног закона и доношења одлуке о тужбеном и противтужбеном захтеву која би била у најбољем интересу малолетне деце.

(Решење Апелационог суда у Нишу Гж2.125/19 од 26.03.2019.године),

Аутор сентенце Мирјана Милутиновић, саветник у Апелационом суду у Нишу

РАДНО ПРАВО



**ОСЛОБАЂАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ ОД ОПТУЖБЕ
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
И ЊЕГОВО ПРАВО ДА У РАДНОМ СПОРУ ПОТРАЖУЈЕ
ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ ДО ПУНОГ ИЗНОСА ЗАРАДЕ
(члан 169. тач. 1 Закона о раду)**

У ситуацији када је у кривичном поступку донета правноснажна пресуда којом је запослени ослобођен од оптужбе за кривично дело примање мита у продуженом трајању, запослени има право да у радном спору потражује исплату разлике од једне половине зараде која му је исплаћивана за време привременог удаљења са рада због дисциплинског поступка који је против запосленог вођен у вези са кривичним поступком, до пуног износа зараде.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је код тужене у радном односу почев од 1998. године, на радном месту полицајца. Решењем тужене 03/9 број од 14.04.2009. године, тужилац је привремено удаљен са рада за време трајања дисциплинског поступка, до окончања истог, а најдуже шест месеци.

У образложењу је наведено да је донет закључак од 14.04.2009. године о покретању дисциплинског поступка против тужиоца због основане сумње да је учинио тешку повреду службене дужности из члана 157 ст. 1 тач. 7 Закона о полицији. За време удаљења, тужилац је по наведеном решењу примао накнаду у висини једне половине зараде. Решењем тужене број од 29.09.2009. године, тужилац је враћен на рад и распоређен на радно место полицајца, почев од 15.10.2009. године. У образложењу је поред осталог наведено да дисциплински поступак против тужиоца није окончан, да привремено удаљење из службе може трајати до окончања дисциплинског поступка, а најдуже шест месеци, те да је у складу са чл. 165 ст. 2 Закона о полицији, на предлог начелника УГП за враћање тужиоца на рад и распоређивање, донето решење као у диспозитиву. Пресудом Вишег суда у К бр. од 24.05.2016. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда у Кж бр. од 17.05.2017. године, тужилац је ослобођен од оптужбе за кривично дело примање мита као саизвршилац, у продуженом трајању.

Тај кривични поступак започет је истрагом која је против тужиоца вођена у предмету тадашњег Окружног суда у Ки бр. Висина спорног потраживања утврђена је на основу резултата економско – финансијског вештачења. Тужбеним захтевом који је прецизирао на рочишту од 22.01.2019. године, тужилац је тражио исплату разлике зараде за време привременог удаљења са рада.

Наиме, одредбама чл. 169. тач. 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005,... 54/2009), који се у конкретном случају примењује на основу чл. 169. Закона о полицији (“Сл. гласник РС” бр. 101/2005 и 63/2009) и чл. 4 Закона о државним службеницима (“Сл. гласник РС” бр. 79/2005,... 104/2009), прописано је да запосленом за време привременог удаљења са рада, у смислу чл. 165. и 166. овог закона, припада разлика између износа накнаде зараде примљене по основу члана 168. овог закона и пуног износа основне зараде и то ако кривични поступак против њега буде обустављен правноснажном одлуком, или ако правноснажном одлуком буде ослобођен оптужбе, или је оптужба против њега одбијена, али не због ненадлежности.

Како је у кривичном поступку вођеном у предмету Вишег суда у К бр. (који је у вези са истражним предметом Окружног суда у Ки бр.) донета правноснажна пресуда од 24.05.2016. године којом је тужилац ослобођен од оптужбе за кривично дело примање мита у продуженом трајању, те како је тужилац у спорном периоду примао једну половину зараде за време привременог удаљења са рада због дисциплинског поступка који је против тужиоца вођен у вези са наведеним кривичним поступком, а што је првостепени суд утврдио на основу исказа тужиоца саслушаног у својству парничне странке, који је правилно ценио као доказ и исти прихватио, а коју везу ни тужена није оспорила одговором на тужбу од 16.03.2018. године, то је првостепени суд применом претходно цитираног прописа из чл. 169 тач. 1 Закона о раду правилно обавезао тужену да тужиоцу на име разлике зараде плати новчано потраживање из прецизираног тужбеног захтева.

Због тога је првостепена пресуда потврђена у ставу првом изреке, како у односу на главно потраживање, тако и у односу на законску затезну камату на износе главног дуга на коју тужилац има право сходно члану 277. и 324. став 1 Закона о облигационим односима у вези правила из члана 4. Закона о

платама државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“ бр. 32/06,... 101/07).

Потврђена је и одлука у погледу тужбеног захтева за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање садржана у ставу другом изреке, јер је донета правилном применом правила из члана 2. и 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 793/20 од 18.09.2020. године)

Сентенцу приредила: Биљана Стаменковић, судија Апелационог суда у Нишу

НЕМОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА О ВРЕМЕНУ ИСПЛАТЕ НЕИСПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА, У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА (члан 186. Закона о раду)

Радни однос је уговорни однос и уговорне стране се могу у складу са начелом аутономије воље споразумети о другачијем начину и динамици исплате неисплаћених потраживања, док је запослени у радном односу код послодавца. Међутим, у случају престанка радног односа по било ком основу из чл. 175. Закона о раду, послодавац је дужан да у року од 30 дана исплати све неисплаћене зараде и друга примања, према чл. 186. истог закона која је императивног карактера, услед чега време исплате тих потраживања не може бити предмет споразумевања између послодавца и запосленог супротно наведеној законској одредби

Из образложења:

Из утврђеног чињеничног стања произилази да је тужилац био у радном односу код туженог до 22.08.2018.године, када му је радни однос престао због смањења обима посла услед технолошких, економских и организационих промена код послодавца „Т.“ а.д. и престанка потребе за његовим радом. Тужилац и тужени су у складу са Одлуком о утврђивању програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације, закључили Споразум о регулисању међусобних права и обавеза по основу рада дана 22.08.2018. године, којим је утврђена обавеза туженог према тужиоцу у укупном

износу од 166.108,41 динара, која је након закључења споразума делимично измирена, тако да је остао неизмирени дуг на име регреса за 2013. годину у износу од 15.563,00 динара и на име дела зараде за месец април 2014.године, износ од 33.042,99 динара. Чланом 2. наведеног Споразума уговорено је да ће се неисплаћена новчана потраживања исплатити када те обавезе буду измириване и другим запосленима који остају да раде у друштву, а најкасније до окончања поступка приватизације.

На основу тако утврђеног чињеничног стања, Апелациони суд налази да је првостепени суд правилно применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца, дајући разлоге које у свему прихвата и овај суд.

Одредбом чл.110 Закона о раду („Службени гласник РС бр.24/05...75/14), предвиђено је да се зарада исплаћује у роковима утврђеним општим актом и уговором о раду, најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец. Према чл. 186. Закона о раду, послодавац је дужан да запосленом у случају престанка радног односа исплати све неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду и то најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа. Ако послодавац због поремећаја у пословању или из других разлога није извршио исплату зараде и других примања, запослени може да оствари заштиту својих права пред надлежним судом и оствари исплату заосталих новчаних потраживања са законском затезном каматом од дана доспелости сваког појединачног потраживања, па до исплате.

Одредбом чл. 60 ст. 4 Устава Републике Србије се јамчи да свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа и да се нико тих права не може одрећи. Стога, како је послодавац дужан да запосленом у случају престанка радног односа исплати све неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа у складу са општим актом и уговором о раду, то запослени има право у случају да му је повређено неко право из радног односа покрене спор пред надлежним судом.

Закљученим споразумом странке нису прецизно и јасно календарским датумом или за тачно одређени период од настанка обавезе уговорили испуњење обавезе, већ на одредив начин, када и осталим запосленима који су остали у радном односу код туженог, а најкасније до окончања поступка приватизације. Одређивање рока испуњења обавезе може бити остављено једном од субјекта облигације, међутим то право не значи да је он потпуно слободан приликом одређивања овог рока и да искључиво зависи од његове воље, јер доспелост обавезе мора бити одређена у складу са циљем и сврхом који треба да се остваре заснивањем уговорног односа, као и природом обавезе.

Радни однос је уговорни однос и уговорне стране се могу у складу са начелом аутономије воље споразумети о другачијем начину и динамици исплате неисплаћених потраживања, док је запослени у радном односу код послодавца. Међутим, у случају престанка радног односа по било ком основу из чл. 175. Закона о раду, послодавац је дужан да у року од 30 дана исплати све неисплаћене зараде и друга примања, према чл. 186. истог закона која је императивног карактера, услед чега време исплате тих потраживања не може бити предмет споразумевања између послодавца и запосленог супротно наведеној законској одредби, како то правилно закључује првостепени суд, из којих разлога је сходно чл. 103. ст. 1 Закона о облигационим односима, ништав напред наведени део споразума, јер је противан принудним прописима.

С тим у вези, одлучујући о делу тужбеног захтева којим је тражена исплата новчаног потраживања, правилно првостепени суд налази да је тужбени захтев и у том делу основан, имајући у виду да основ и висина предметне обавезе туженог, заснована на реализованом праву тужиоца из рада и по основу рада, није била спорна међу странкама, те да тужени неосновано указује да је потраживање преурањено и да исто није доспело и у свему је суд дао јасне разлоге засноване на примени чл. 186 Закона о раду, које прихвата и Апелациони суд.

Наводи жалбе којима се указује на Одлуку Владе Републике Србије о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016 и 2017 годину, не могу утицати на доношење другачије одлуке у овој правној ствари, обзиром да поступак провођења програма решавања вишка запослених, утврђивање вишка запослених и наступање основа за престанак радног односа по том основу, као и исплата

отпремнине не представља релевантан чињенични основ у конкретној парници, с обзиром да се ради о новчаном потраживању које је настало за време трајања радног односа по основу фактичког рада, која нису измирена и која су независна од самог поступка утврђивања вишка запослених и отказа уговора о раду по том основу.

Такође, неосновано се наводима жалбе оспорава правилност и законитост побијане пресуде указујући да је наведеном Одлуком Владе Република Србије предвиђено да је субјект приватизације дужан да закључи споразум о међусобном регулисању права и обавеза по основу рада, уколико према запосленом који је утврђен као вишак имају обавезе по било ком основу из радног односа.

Наиме, споразум који су странке закључиле у целини, није супротан принудним прописима, напротив то је била дужност послодавца, јер је испуњен услов имајући у виду да је послодавац имао неизмирене обавезе из радног односа према тужиоцу, како би се на јасан начин дефинисао и утврдио основ и висина тих обавеза, што споразум и садржи. Међутим, како наведена Одлука, не садржи упућујући норму у погледу начина и времена измирења тих обавеза, то се неосновано наводи жалбе заснивају на том акту, јер је послодавац био у обавези да регулише предметну исплату у оквиру услова и рокова предвиђених императивном нормом.

Стога, правилно је првостепени суд обавезао туженог да тужиоцу исплати предметно новчано потраживање, одлучујући као у ставу другом изреке, налазећи да се у конкретном случају ради о доспелој обавези туженог која није исплаћена у смислу чл. 186. Закона о раду. С тим у вези, неосновано се жалбом туженог указује да се у конкретном случају ради о застарелом потраживању и да је у том правцу првостепени суд погрешно применио материјално право.

Према члану 196. Закона о раду, сва новчана потраживања из радног односа застаревају у року од три године од дана настанка обавезе. Како је радни однос уговорни однос, то се у погледу новчаних потраживања, примењују правила садржана у Закону о облигационим односима, која за одређене правне и чињеничне ситуације нису регулисана и нису у супротности са одредбама Закона о раду.

Наиме, у конкретној парници међу странкама није спорна доспелост неисплаћене зараде за април 2014. годину (01.06.2014.године), односно

регреса за 2013. годину (01.01.2014. године). У време сачињавања споразума између тужиоца и туженог дана 22.08.2018. године, наведена потраживања су застарела, јер је протекло три године од дана настанка обавезе, услед чега је обавеза постала натурална, која се не може намирити принудним путем. Стога, како се радило о већ застарелом потраживању тужиоца, то је управо писаним признањем застареле обавезе, дошло до одрицања туженог од већ наступеле застарелости сходно чл. 365. и члана 366. ст.1. ЗОО, услед чега је настало право тужиоца да покретањем потупка пред надлежним судом подношењем тужбе (10.07.2019. године) тражи испуњење признате обавезе у целости и то како главног дуга, тако и споредних тражења, јер је одрицањем од застарелости за главно потраживање тужени извршио одрицање од застарелости и за сва споредна потраживања која деле судбину главног дуга. С тим у вези констатује се да се послодавац дужник у писаној изјави није децидно изјаснио да се одрицање од застарелости не односи на споредне обавезе, односно потраживања, а чињеница да је тужиоцу престао радни однос, није од утицаја на доспелост већ доспелог потраживања, које је признато сачињеним писаним споразумом закљученим између тужиоца и туженог.

Полазећи од напред наведеног, Апелациони суд налази да нису основани наводи жалбе туженог, с обзиром да је првостепени суд утврдио све релевантне чињенице за правилно одлучивање у овој правној ствари, као у ставу првом и другом изреке, и на тако утврђен чињенични основ, правилно је примењено материјално право у свему дајући разлоге које прихвата и овај суд.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 1107/2020 од 29.05.2020. године)

Сентенцу приредила: Ивана Рађеновић, судија Апелационог суда у Нишу

**ПОСЛЕДИЦЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
КОЈА ИХ ЈЕ УПУТИЛА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ
ПРОВЕДУ У РАДНОМ ОДНОСУ ДВОСТРУКО ДУЖИ
ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД У ОДНОСУ НА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ**

(чл. 184. новелираног Закона о здравственој заштити)

У ситуацији када питање правних последица непоступања запосленог здравственог радника по одредбама чл. 184. ст. 9 и 10 новелираног Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС” бр. 57/2011) није уређено тим посебним законом, нити аутономним актом послодавца или уговором о раду, суду се дају шири овлашћења него иначе, а са циљем да постојећу правну празнину премости применом аналогije (тумачења по сличности), шире интерпретације спорног односа и правних правила садржаних у Закону о облигационим односима као општем закону и да у конкретној парници донесе правилну и закониту одлуку о постављеном тужбеном захтеву.

Из образложења:

Према чињеничном стању садржаном у списима предмета, уговором о раду од 22.05.2007. године тужена ББ засновала је радни однос код тужиоца, на неодређено време, на пословима лекара опште медицине, почев од 22.05.2007. године. Дана 08.06.2009. године директор тужиоца донео је одлуку којом се туженој одобрава специјализација из области интерне медицине, а наредног дана Министарству здравља поднео је захтев да се туженој одобри специјализација из наведене области, поводом ког захтева је министарство дало писано мишљење да је исти оправдан. Решењем од 18.09.2009. године, Министарство здравља дало је сагласност на одлуку директора тужиоца од 08.06.2009. године којом је туженој одобрена специјализација. Дана 30.09.2009. године, директор тужиоца упутио је захтев Медицинском факултету у којим је тражио упис тужене на специјалистичке студије из области интерне медицине, а на основу одлуке од 08.06.2009. године и сагласности садржаног у решењу Министарства здравља од 18.09.2009. године. Поменуте студије тужена је започела 01.10.2009. године, а специјалистички стаж завршила је 09.12.2013. године. Електронском поштом од 21.08.2014. године тужилац је туженој доставио

на потпис уговор о специјализацији са ретроактивним важењем, којим би се тужена према тужиоцу обавезала да заврши специјализацију у законски одређеном року и да проведе у радном односу двоструко дужи период од периода специјализације (члан 7), као и да послодавцу накнади све трошкове на име претходно обављеног специјалистичког стажа, уколико прекине обављање специјалистичког стажа, не положи специјалистички испит или престане са радом у датом периоду специјализације, као и да послодавцу накнади штету коју претрпи таквим поступком (члан 8). Овај уговор тужена је одбила да потпише уз писано образложење које је тужиоцу дала у допису од 01.09.2014. године. Дана 31.10.2014. године тужена је положила специјалистички испит, а дана 10.11.2014. године поднела је тужиоцу захтев да јој се одобри неплаћено одсуство, које јој је одобрено решењем тужиоца од 13.11.2014. године у трајању од 6 месеци, почев од 17.11.2014. године, закључно са 16.05.2015. године. Захтевом који је тужиоцу поднела 15.05.2015. године, тужена је тражила престанак радног односа закључно са 18.05.2015. године, што је констатовано решењем тужиоца од 11.06.2015. године. Захтевом од 11.06.2015. године тужилац је тужену позвао да плати трошкове специјализације. Тужена живи и ради у Немачкој (произилази из садржине поднеска од 10.09.2018. год). Тужба у овој правној ствари поднета је 22.07.2015. године. Поднеском од 20.04.2017. године тужилац је прецизирао тужбени захтев на укупан износ од 170.000,00 динара који чине износи од по 85.000,00 динара, на име трошкова првог семестра плаћених 26.09.2011. године и трошкова другог семестра плаћених 25.01.2012. године. Одговором на тужбу и на главној расправи тужена је оспорила основ тужбеног захтева. Поред наведеног изјавила је компензациони приговор и исти определила на износ од 173.827,00 динара који чини износ од 72.000,0 динара на име трошкова специјалистичког испита које је тужена платила 01.11.2014. године и износ од 101.827,00 динара на име накнаде штете због неомогућавања коришћења плаћеног одсуства за припрему и полагање специјалистичког испита, по молби – захтеву тужене од 06.08.2014. године.

Првостепени суд је на основу изложеног чињеничног стања оценио неоснованим тужбени захтев тужиоца и као такав га је одбио, одлучујући као у изреци ожалбене пресуде под ставом један.

Међутим, овакав закључак за сада се не може прихватити као правилан и законит, јер је првостепена пресуда заснована на чињеничном стању које је остало непотпуно утврђено, услед чега се иста пресуда не може испитати ни са становишта правилне примене материјалног права, па је морала бити укинута.

Одредбама члана 184. Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС” бр. 107/2005,... 99/2010 – на снази од 10.12.2005. до 08.08.2011. године), било је регулисано да се здравствени радник и здравствени сарадник са високом школском спремом може специјализовати ако има завршен приправнички стаж и положен стручни испит и две године обављања здравствене делатности по положеном стручном испиту (став 1). Здравствени радник и здравствени сарадник може обављати здравствену заштиту из области коју специјализира само под надзором овлашћеног здравственог радника, односно здравственог сарадника – ментора (став 2). Здравствени радник са високом стручном спремом може се после завршене специјализације усавршавати у ужој специјалности (став 3). Одобравање специјализација и ужих специјализација врше здравствене установе, односно приватна пракса, у складу са планом стручног усавршавања из члана 183. став 1. овог закона (став 4). Одлуку о одобравању специјализације и уже специјализације, у складу са ставом 4. овог члана, доноси директор здравствене установе, односно оснивач приватне праксе (став 5). Министар решењем даје сагласност на одлуку из става 5. овог члана (став 6). Решење министра из става 6. овог члана коначно је у управном поступку и против њега се може покренути управни спор (став 7).

Изменама и допунама Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС” бр. 57/2011) које су ступиле на снагу 09.08.2011. године, одредба чл. 184. новелирана је на следећи начин: Здравствени радник и здравствени сарадник са високим образовањем може се стручно усавршавати – стицати специјализацију под условом да је завршио приправнички стаж и положио стручни испит, као и да је најмање две године обављао здравствену делатност по положеном стручном испиту, осим ако овим законом није друкчије одређено (став 1). Изузетно од става 1. овог члана, за области дефицитарних грана медицине, стоматологије, односно фармације, здравствени радник може се упутити на специјализацију после завршеног приправничког стажа и положеног стручног испита (став 2). Министар, за сваку календарску годину, најкасније до 31. децембра текуће године, доноси одлуку о областима медицине, стоматологије, односно фармације које су дефицитарне

у Републици Србији, на основу мишљења завода за јавно здравље основаног за територију Републике у складу са законом (став 3). Здравствени радник са високим образовањем може се после завршене специјализације усавршавати и у ужој специјалности под условом да је обављао послове здравствене заштите у складу са овим законом, као специјалиста одређене гране медицине, стоматологије, односно фармације, у трајању од најмање две године (став 4). Одобравање специјализација и ужих специјализација врше здравствене установе, односно приватна пракса, у складу са планом стручног усавршавања из члана 183. став 1. овог закона (став 5). Одлуку о одобравању специјализације и уже специјализације, у складу са ставом 5. овог члана, доноси директор здравствене установе, односно оснивач приватне праксе (став 6). Министар решењем даје сагласност на одлуку из става 6. овог члана (став 7). Решење министра из става 7. овог члана коначно је у управном поступку и против њега се може покренути управни спор (став 8). Здравствени радник, односно здравствени сарадник дужан је да закључи уговор са здравственом установом, односно приватном праксом о правима, обавезама и одговорностима за време стручног усавршавања у току специјализације, односно уже специјализације (став 9). Здравствени радник, односно здравствени сарадник дужан је да у здравственој установи из Плана мреже проведе у радном односу двоструко дужи период од периода трајања специјализације, односно уже специјализације (став 10). Здравствени радник, односно здравствени сарадник може да обавља здравствену заштиту из области коју специјализира само под надзором овлашћеног здравственог радника, односно здравственог сарадника – ментора (став 11). Здравствена установа, односно приватна пракса може да одобри здравственом раднику, односно здравственом сараднику специјализацију, односно ужу специјализацију, под условом да обавља делатност у складу са овим законом најмање две године пре дана подношења захтева за одобравање специјализације, односно уже специјализације (став 12).

Новелирањем цитиране законске одредбе, почев од 09.08.2011. године (када су измене и допуне закона ступиле на снагу), уведена је дужност здравственог радника да са здравственом установом закључи уговор о правима обавезама и одговорностима за време стручног усавршавања у току специјализације, као и дужност да у здравственој установи проведе у радном односу двоструко дужи период од периода трајања специјализације.

Према становишту Апелационог суда, за решавање конкретног спора меродавне су одредбе чл. 184. новелираног Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011), имајући у виду да су специјалистичке студије тужене ББ биле у току на дан ступања на снагу измена и допуна поменутог закона (09.08.2011. године).

Према том пропису, тужена је била дужна да са тужиоцем закључи уговор о правима обавезама и одговорностима за време стручног усавршавања у току специјализације, као и да код тужиоца проведе у радном односу двоструко дужи период у односу на период трајања специјализације, а што тужена неспорно није учинила, имајући у виду да је одбила закључење понуђеног уговора, да је специјализацију завршила 31.10.2014. године полагањем специјалистичког испита, а да јој је радни однос код тужиоца престао 18.05.2015. године, на њен захтев.

Новелираним Законом о здравственој заштити нису регулисане правне последице непоступања запосленог здравственог радника по одредбама цитираног чл. 184 ст. 9 и 10, односно за случај да здравствени радник одбије закључење уговора са здравственом установом као послодавцем и не остане у радном односу код те установе двоструко дужи период у односу на период трајања специјализације. У недостатку такве законске регулативе, а код неспорне чињенице да је тужена одбила закључење уговора који јој је тужилац понудио дана 21.08.2014. године, првостепени суд је пропустио да утврди да ли су закљученим уговором о раду од 22.05.2007. године тужилац и тужена регулисали поменуте правне последице, да ли је тужени и када донео општи акт којим је предвиђена процедура у вези специјализације као и да ли су поменуте правне последице регулисане тим актом послодавца, а који пропуст ће отклонити у поновном поступку, те уколико утврди да такве норме постоје, основаност тужбеног захтева цениће њиховом применом. Такође, утврдиће на који начин је одобрена специјализација и начин финансирања исте, те да ли је у том смислу постојао конкурс по коме је тужила испуњавала прописане услове.

У супротном, уколико нађе да ни уговором о раду од 22.05.2007. године, ни општим актом послодавца, уколико је донет и у примени је, нису регулисане последице непоступања здравственог радника (запосленог) по претходно цитираним одредбама из чл. 184. новелираног Закона о здравственој заштити, првостепени суд ће имати у виду да радни однос тужиоца и тужене

представља својеврсни уговорни (облигациони) однос у коме је тужилац као послодавац имао, поред осталог и обавезу да туженој омогући стручно усваршавање – специјализацију о трошку послодавца у смислу чл. 25 ст. 1 тач. 1 и ст. 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл. гласник РС” бр. 36/2010,... 37/2014), а коју обавезу је тужилац испунио у конкретном случају. Са друге стране, тужена као запослена имала је према тужиоцу обавезу да по окончању специјализације остане у радном односу код њега двоструко дужи временски период у односу на период трајања специјализације, а коју обавезу тужена није испунила. Због тога ће првостепени суд у поновном поступку ценити основаност тужбеног захтева у контексту одредаба чл. 132. у вези са чл. 154 ст. 1 и чл. 155. Закона о облигационим односима, имајући у виду и начела регулисана одредбама чл. 12., 13., 16. и 17 истог закона. Ово из разлога што се у ситуацији када питање правних последица непоступања запосленог здравственог радника по одредбама чл. 184. ст. 9 и 10 новелираног Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС” бр. 57/2011) није уређено тим посебним законом, нити аутономним актом послодавца или уговором о раду, суду дају шири овлашћења него иначе, а са циљем да постојећу правну празнину премости применом аналогije (тумачења по сличности), шире интерпретације спорног односа и правних правила садржаних у Закону о облигационим односима као општем закону и да у конкретној парници донесе правилну и закониту одлуку о постављеном тужбеном захтеву.

Имајући у виду примедбе и пропусте на које му је указао другостепени суд, првостепени суд ће у поновном поступку правилно и потпуно утврдити чињенично стање, након чега ће правилном применом материјалног права поново одлучити о тужбеном захтеву тужиоца, дајући за своју одлуку одговарајуће разлоге.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 1650/20 од 04.09.2020. године)

Сентенцу приредила: Биљана Стаменковић, судија Апелационог суда у Нишу

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА, КАДА УСЛЕД ТЕХНОЛОШКИХ, ЕКОНОМСКИХ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ПРОМЕНА ДОЂЕ ДО СМАЊЕЊА ОБИМА ПОСЛА

(члан 179 ст. 5 тач. 1 Закона о раду)

У ситуацији кад није у обавези да донесе Програм решавања вишка запослених, послодавац нема дискреционо право да без одређених мерила сам одлучи који запослени предствља вишак, већ напротив, одређивање лица које представља вишак од више извршилаца на истом радном месту, без примене критеријума, такву одлуку чини незаконитом.

Из образложења:

Према чињеничном стању садржаном у списима предмета, тужила је код туженог била у радном односу на неодређено време, на пословима диспонента, на основу закљученог уговора о раду од године. Тај уговор је тужилји отказан решењем туженог од године, заснованим на отказном разлогу из чл. 179 ст. 5 тач. 1 Закона о раду, те јој је радни однос престао закључно са године, уз претходну исплату отпремнине. У образложењу решења наведено је поред осталог да је код туженог послодавца смањен обим послова, да су донете измене Правилника о организацији и систематизацији послова којима је смањен број извршилаца на пословима “диспонтент”, те да је тужила одређена као запослена за чијим радом је престала потреба услед економских и организационих промена. Наведено је и то да се тужени приликом избора запосленог водио и чињеницом да тужила као запослена није возач, а да остала тројица запослених управљају возилом што је један од неопходних услова за обављање послова диспонента. Правилником о организацији и систематизацији послова од 10.06.2016. године, у тачки 11, утврђено је радно место диспонтент – референт за издавање возила, за 11 извршилаца, а изменама и допунама овог правилника од 11.05.2017. године исто радно место утврђено је и у оквиру два туженикова огранка у ..., за четири извршиоца. Новим изменама и допунама истог правилника од 02.09.2018. године, на радном месту диспонтент – референт за издавање возила у оквиру туженикових огранака у ..., смањен је број извршилаца са четири на три, о чему је тужилји достављено писано обавештење од 20.09.2018. године. Дана 23.05.2018. године тужени је вршио тестирање четворо запослених у смислу познавања “rent a car” пословања и радних карактеристика прописаних уговором о раду, о чему је сачинио записник.

На основу изложеног чињеничног стања, првостепени суд је закључио да је тужбени захтев тужиље основан, па је исти усвојио као у изреци ожалбене пресуде.

Међутим, овакав закључак првостепеног суда за сада се не може прихватити као правилан и законит, јер је заснован на чињеничном стању које због погрешне примене материјалног права није правилно и потпуно утврђено, па је првостепена пресуда морала бити укинута.

Наиме, спорно решење о отказу уговора о раду донето је применом отказног разлога из члана 179 ст. 5 тач. 1 Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005,... 113/2017) којим је прописано да запосленом може да престане радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе послодавца и то ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла.

Из цитираног прописа произлази да технолошке, економске или организационе промене морају имати објективну структурну вредност да би се отказ због престанка потребе за радом запосленог могао сматрати оправданим. Наведене промене код послодавца представљају његову пословну политику, коју суд није овлашћен да цени у поступку оцене законитости решења о престанку радног односа запосленом по овом основу, али разлози за престанак потребе за радом запосленог морају бити оправдани. Закон о раду не садржи критеријуме којих је послодавац дужан да се придржава при одређивању на које ће се запослене односити престанак потребе за радом, већ прописује поступак који се у том случају примењује и одређује права која је послодавац дужан да обезбеди запосленима за чијим је радом престала потреба. Програм решавања вишка запослених, послодавац је дужан да донесе када се стекне неки од услова из члана 153 Закона о раду, у зависности од броја запослених који представљају вишак у односу на укупан број запослених. Међутим, ситуација када је послодавац у обавези да донесе Програм решавања вишка запослених, као и ситуација када наведену обавезу нема, не даје право послодавцу да без одређених критеријума сам одлучи који запослени представља вишак. Дакле, и у ситуацији кад није у обавези да донесе Програм решавања вишка запослених, послодавац нема дискреционо право да без одређених мерила сам одлучи који запослени представља вишак, већ напротив, одређивање лица које представља вишак

од више извршилаца на истом радном месту, без примене критеријума, такву одлуку чини незаконитом. На послодавцу лежи терет доказивања чињенице да је конкретно решење о отказу уговора о раду засновао на претходно спроведеном поступку бодавања запослених на истом радном месту, према мерилима и критеријумима које је послодавац претходно утврдио.

У конкретном случају, изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова од 11.05.2017. године, радно место “диспонент – референт за издавање возила” утврђено је у оквиру два туженикова огранка у ..., за четири извршиоца, а изменама и допунама истог правилника од 02.09.2018. године, на том радном месту број извршилаца смањен је са четири на три.

Првостепени суд је пропустио да утврди да ли је радно место “диспонент – референт за издавање возила” у оквиру два туженикова огранка у ... било попуњено са сва четири извршиоца (како је било предвиђено изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова од 11.05.2017. године), и о којим конкретним извршиоцима се ради. Ово, имајући у виду да из садржине записника о тестирању од 23.05.2018. године произлази да нису сви запослени обављали послове диспонтента – референта за издавање возила (С. Ц. је обављао послове диспонтента – шефа пословнице ..., тужиља О. Ш. – послове диспонтента, М. Ђ. – послове диспонтента диспечера и Н. К. – послове диспонтента диспечера). Поред наведеног, првостепени суд је пропустио да утврди које конкретне послове (према закљученим уговорима о раду) су наведена лица обављала, да ли су у питању исти послови које је тужиља обављала према закљученом уговору о раду бр. ... од године и ако јесу – да ли записник о обављеном тестирању запослених од 23.05.2018. године стоји у вези са предметним отказом и од каквог је утицаја на исти, а имајући у виду да је тестирање временски претходило изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова од 02.09.2018. године, односно смањењу броја извршилаца на поменутом радном месту са четири на три.

Због наведеног пропуста првостепеног суда, ожалбена пресуда је укинута у ставу првом и другом изреке.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 1973/2020 од 11.09.2020. године

Сентенцу приредила: Ивана Рађеновић, судија Апелационог суда у Нишу

**ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА
ЗА ВРЕМЕ ТРУДНОЋЕ, ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И
ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ И ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
(чл. 187. Закона о раду)**

Када Закон о основама система образовања и васпитања, као посебан закон, не садржи одредбе које се односе на специфичну ситуацију престанка радног односа за време трудничког одсуства, тада ће се супсидијарно применити Закон о раду као матични и општи закон који такву ситуацију регулише когентним нормама садржаним у члану 187.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилца је, на основу решења директора тужене школе бр. .. од 14.11.2012. године, засновала радни однос на неодређено време, са радним временом од 45% од пуног радног времена, на радном месту наставника енглеског језика, почев од 13.11.2012. године. Дана 08.09.2015. године директор тужене је донео решење бр. ... о престанку потребе за радом дела радне норме, којим утврђује престанак потребе за радом тужилце за део који износи 38,89 % од пуне норме, односно 15,55 часова недељно са даном 01.09.2015. године, за које остаје у радном односу на неодређено време, као последицу смањења броја група за енглески језик. На основу наведеног решења, дана 09.09.2015. године, закључен је уговор о раду бр. ... на неодређено време са непуним радним временом у трајању од 15,55 часова недељно. Такође, утврђено је да је код тужилце дана 21.10.2016. године наступила привремена спреченост за рад по прописима о здравственом осигурању, због одржавања трудноће, и да ће трајати до 19.11.2016. године, према потврди Дома здравља ... од 20.10.2016. године. Решењем директора тужене бр. ... од 16.11.2016. године тужилци је престао радни однос у складу са чл. 120 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања, услед чињенице да је у току радног односа утврђено да не испуњава услове из чл. 120 ст. 1 тач. 1 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да нема одговарајуће образовање за обављање послова на којима је распоређена, а који су предвиђени чланом 8 наведеног закона. Против истог решења тужилца је изјавила приговор, који је одбијен Одлуком органа управљања бр. ... од 30.11.2016. године, јер тужилца није поседовала одговарајуће образовање за обављање послова на којима је засновала радни однос, а то је диплома о стеченом образовању у својој струци – мастер, већ

поседује диплому основних академских студија првог степена. Записником просветне инспекције бр. ... од 07.04.2017. године, утврђено је да је тужилци престао радни однос у складу са чланом 120 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку су саслушани тужила у својству странке и сведоци АА1 и АА2.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је нашао да су побијано решење и одлука органа управљања туженог незаконити, обзиром да се тужила у време доношења наведених одлука налазила на трудничком одсуству, што је туженој школи у време доношења одлуке било познато, чиме је тужена школа поступила супротно одредби чл. 187 Закона о раду.

Овакав закључак првостепеног суда, као правилан и на закону заснован, у свему прихвата и овај жалбени суд.

Наиме, одредбом чл. 60. став 5. Устава РС којима је утврђено да се женама, омладини и инвалидима омогућују посебна заштита на раду и посебни услови рада, у складу са законом, да породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом, да се мајци пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја (члан 66. ст. 1. и 2.). Одредбом чл. 66 ст. 1 Устава РС прописано је да породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом.

Одредбама Конвенције Међународне организације рада број 183 о заштити материнства (“Службени гласник РС - Међународни уговори” број 1/10) прописано је, поред осталог, да се ова конвенција примењује на све запослене жене, укључујући и оне у нетипичним облицима зависног рада (члан 2. став 1.), да на основу лекарске потврде или друге одговарајуће потврде, на основу домаћег закона и праксе, у којој се наводи предвиђени датум порођаја, жена на коју се примењује ова конвенција има право на породичко одсуство у трајању не краћем од 14 недеља (члан 4. став 1), да ће се на основу лекарске потврде одобрити одсуство пре или после породичког одсуства у случају болести, компликација или опасности од компликација у вези трудноће или порођаја, те да се врста и максимално трајање таквог одсуства може прописати у складу са домаћим законом и праксом (члан 5).

Одредбама члана 8 исте Конвенције МОР прописано је да се отпуштање жене са посла за време трудноће и одсуства из чл. 4. или 5. ове конвенције

или у периоду након њеног повратка на посао прописаног домаћим законом или прописима сматра незаконитим, осим из разлога који немају везе са трудноћом, порођајем и дојењем као његовом последицом, да терет доказивања да разлози за отпуштање немају везе са трудноћом, порођајем и дојењем сноси послодавац (став 1.), те да по истеку породилског одсуства, жена има право да се врати на исто радно место или на одговарајуће радно место са истом платом (став 2.). Ова Конвенција, коју првостепени суд није имао у виду приликом одлучивања, чини саставни део правног поретка Републике Србије, према чл. 16 став 2 Устава РС.

Одредбом чл. 187 Закона о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) одређено је да за време трудноће, породилског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета послодавац не може запосленом да откаже уговор о раду. Запосленом из става 1. овог члана рок за који је уговором засновао радни однос на одређено време продужава се до истека коришћења права на одсуство. Решење о отказу уговора о раду ништаво је ако је на дан доношења решења о отказу уговора о раду послодавцу било познато постојање околности из става 1. овог члана или ако запослени у року од 30 дана од дана престанка радног односа обавести послодавца о постојању околности из става 1. овог члана и о томе достави одговарајућу потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа.

У првостепеном поступку неспорно је утврђено да је тужилца о привременој спречености за рад у смислу одржавања трудноће обавестила тужену школу дана 21.10.2016. године, те да је туженој ова чињеница била позната у тренутку доношења решења о престанку радног односа, што је констатовано и у самом решењу.

Првостепени суд у образложењу своје одлуке правилно налази да се цитираним одредбама Устава РС и Закона о раду предвиђа посебна заштита жена и мајки, те да послодавац не може да у таквој ситуацији, откаже уговор о раду за време трудноће. Поменутом одредбом чл. 187 ст. 3 Закона о раду одређено је да је решење о отказу уговора о раду ништаво уколико је на дан доношења решења послодавцу било познато постојање околности из става 1, односно стање трудноће. Смисао наведене законске одредбе је забрана отказа одређеним категоријама радника, у конкретном случају трудницама, те имајући у виду чињеницу да је тужени на дан доношења решења знао за

ту чињеницу, решење о престанку радног односа тужиле је незаконито, а одлука првостепеног суда правилна и на закону заснована.

Неосновано се жалбом тужене указује да је тужили радни однос престао по сили закона, обзиром да Закон о раду не предвиђа изузетке у којима се запосленом може отказати уговор о раду за време трудноће. Овакав закључак произилази из одредбе чл. 187 ст. 2 Закона о раду који предвиђа да се запосленом који је засновао радни однос на одређено време исти продужава све до истека права на одсуство, из чега произилази да Закон о раду пружа заштиту и у случају када се стекну услови да запосленом престане радни однос по сили закона, те да оваква заштита траје све до истека права на одсуство. Тачно је да Закон о основама система образовања и васпитања, у одредби чл. 120 ст. 4 предвиђа да запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана, као и да се овај закон примењује као *lex specialis* у односу на Закон о раду, међутим, у ситуацији када посебни закон не садржи одредбе које се односе на специфичну ситуацију престанка радног односа за време трудничког одсуства, супсидијарно се примењују одредбе матичног закона који такву ситуацију регулише когентним нормама.

Такође, неосновани су и жалбени наводи тужене у којима се позива на одредбу чл. 8 Конвенције МОР 183, обзиром да је првостепени суд дао разлоге у образложењу одлуке о разлозима због којих сматра да тужена није доказала да отказ није у вези са одсуством ради одржавања трудноће. Чињеница да је тужена иснсистирала да тужила достави документацију за полагање испита у тренутку када због трудноће није у могућности да такав испит полаже, као и чињеница да је тужена имала увид у досије тужиле током целокупног њеног радног ангажовања, у периоду од четири године, те сам тренутак доношења решења указују да је повод за престанак радног односа управо одсуство са рада ради одржавања трудноће, иако се као правни основ побијаног решења наводи непоседовање одговарајуће мастер дипломе.

Жалбени наводи тужене којима се позива на пресуду Врховног касационог суда Рев2 1111/2015 од 16.06.2016. године, нису од значаја за другачије одлучивање имајући у виду да се чињенично стање у овом предмету у битном разликује, обзиром да се не ради о ситуацији која се може подвести под правила о посебној заштити од отказа уговора о раду у смислу одредбе чл. 187 Закона о раду.

Овај жалбени суд није прихватио ни наводе тужене који се односе на стручну спрему новозапослене, као и да је министарство одбило да тужилци омогући полагање, обзиром да овакве чињенице нису од утицаја за оцену законитости побијаног решења.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 3141/2019 од 24.06.2020. године)

Сентенцу приредила: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу

ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА ЗА ШТЕТУ КОЈУ ЗАПОСЛЕНИ ПРЕТРПИ НА РАДУ (члан 164. Закона о раду)

Чињеница да је несрећни догађај проузроковало друго возило, учесник у саобраћају, може бити од значаја у случају регресирања настале штете туженом, али ни на који начин не може утицати на одговорност тужене да тужиоцу накнади штету коју је претрпео на раду, приликом поступања по налогу тужене.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је у радном односу код тужене, са седиштем његове јединице у ..., али са местом рада у ... Дана године, тужилац се магистралним путем Прешево – Врање са још петорицом колега, у својству путника у возилу, враћао са извршења радног задатка, који се тог дана састојао у помоћи органима МУП-а на пословима обезбеђења државне границе, када је задњи део њиховог службеног теренског моторног возила ударило теретно моторно возило, које није држало потребно растојање. Одмах је пренет у Здравствени центар у Врању, где су констатоване повреде, постављена надлактина гипсана лонгета и одређена физикална терапија. Околности штетног догађаја су утврђене из извештаја о повреди на раду и изјаве тужиоца. Налазом и мишљењем медицинског вештака утврђено је да је тужилац задобио тешку телесну повреду у виду прелома главице жбичне кости у левом лакту; која је узроковала јаке физичке болове око 20 дана, средње око 30 дана, а слабије око 4 месеца; а да је као трајна последица повређивања, његова животна активност умањена за 15%, а изражава се при свакодневним физичким пословима у кући, као и при друштвеним

активностима, управљању моторним возилом итд. Неуропсихијатријским вештачењем је утврђено да је повреда изазвала јак страх у трајању од 3 сата, који је прешао у страх средњег интензитета око 20 дана и слабијег интензитета више од 2 месеца.

Код тако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд правилно налази да је тужена одговорна за штету коју је тужилац претрпео на раду, по начелу објективне одговорности, односно без обзира на кривицу, јер се ради о штети која потиче од опасне делатности, сходно одредби чл. 154 ст. 2 у вези чл. 173 и 174 Закона о облигационим односима, с обзиром да рад који је тужилац обављао и на коме је претрпео штету, односно путовање - враћање службеним моторним возилом тужене са извршења радног задатка у ..., има карактер опасне делатности коју је организовала тужена.

Одговорност тужене произлази и из одредбе чл. 164 Закона о раду ("Сл. гл. РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), којом је прописано да ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му исту накнади у складу са законом и општим актом.

Супротно наводима тужене, које понавља и у жалби, првостепени суд правилно налази да чињеница што се у овој правној ствари ради о саобраћајној несрећи, за коју се зна ко су учесници, као и што је познат евентуални штетник, није од утицаја на оцену основаности тужбеног захтева, зато што је тужилац повређен у радно време, приликом обављања повереног радног задатка, у службеном возилу тужене, које је вршило превоз запослених тужене, односно одвожење и довожење са места рада критичног дана, о чему додатно сведочи и чињеница да је тужена, у оквиру својих надлежности, тужиоцу издала извештај о повреди на раду.

Чињеница на коју указује тужена у жалби, да је несрећни догађај проузроковало друго возило, учесник у саобраћају, може бити од значаја у случају регресирања настале штете туженом, али ни на који начин не може утицати на одговорност тужене да тужиоцу накнади штету коју је претрпео на раду, приликом поступања по налогу тужене, због чега се овај жалбени навод није могао прихватити као основан.

Правилно је и налажење првостепеног суда да у поступању тужиоца нема никаквог доприноса настанку или увећању штете, јер као путник у возилу није никако могао да утиче или допринесе да се штета евентуално избегне или умањи, на основу чега тај суд правилно закључује да у овој правној

ствари нема места примени правила о подељеној одговорности штетника и оштећеника из чл. 205 у вези чл. 192 ЗОО.

*(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 1768/2019 од 28.08.2020. године)
Сентенцу приредио: Ђорђе Гојић, судија Апелационог суда у Нишу*

РАДЊА ЗАПОСЛЕНОГ КАО БИТАН ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОСТОЈАЊЕ ПОВРЕДЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ (Члан 179. став 2. тачка 1. Закона о раду)

За постојање отказног разлога који чини повреда радне обавезе потребни услови су радња запосленог која представља биће повреде радне обавезе и кривица запосленог. Радња запосленог може бити чињење или нечињење, а кривица је основ одговорности у случају повреде радне обавезе, с тим што за отказ уговора о раду није довољан сваки степен кривице, већ је потребно да је запослени извршио повреду радне обавезе намерно или из крајње непажње. За постојање отказног разлога непоштовање радне дисциплине није нужно постојање кривице тј. намере да се прекрши прописана односно уобичајена радна дисциплина, већ је довољна свест о томе.

Из образложења:

За постојање отказног разлога који чини повреда радне обавезе потребни услови су радња запосленог која представља биће повреде радне обавезе и кривица запосленог. Радња запосленог може бити чињење или нечињење, а кривица је основ одговорности у случају повреде радне обавезе, с тим што за отказ уговора о раду није довољан сваки степен кривице, већ је потребно да је запослени извршио повреду радне обавезе намерно или из крајње непажње. За постојање пак отказног разлога непоштовање радне дисциплине није нужно постојање кривице тј. намере да се прекрши прописана односно уобичајена радна дисциплина, већ је довољна свест о томе.

У конкретном случају на страни тужиоца нема радње која би се могла квалификовати као повреда радне обавезе, па самим тим ни његове одговорности. Тужиоцу је отказан уговор о раду зато што је дана 13.05.2017. године, док је радио у трећој смени самоиницијативно прекинуо са радом на возилу К38, напустио своје радно место у 03,30 часова без дозволе свог

руководиоца и ушао у возило K423 за које није имао радни налог у коме је боравио до 03.50 часова где је и затечен од стране радне контроле. Међутим, у првостепеном поступку је утврђено да је код туженог била пракса да запослени и без радног налога прилазе у помоћ и консултацију колегама који имају проблем, као и да је управо тужилац, због свог искуства и знања често био ангажован на тај начин и без радног налога. При томе, критичном приликом непосредни руководиоца није био присутан, а управо је он саслушан као сведок потврдио предњу праксу и посведочио да се у таквим ситуацијама када су у питању консултације није издавао радни налог. Да је тужилац напустио своје радно место ради консултације и помоћи колегама, потврдио је и сведок контролор В.Ђ. који је изјавио да је тужиоца са још двојицом колега затекао у ниском положају и погледа фокусираном ка месту где је требало да се отклони квар.

(Пресуда Основног суда у Нишу 3 П1 1953/17 од 17.05.2019. године и Апелационог суда у Нишу Гжс1 3208/2019 од 11.05.2020. године)

ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА И НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

(Чл.164. Закона о раду и чл. 154. Закона о облигационим односима)

Не постоји одговорност тужене за штету коју је тужилац претрпео у саобраћајном удесу који се догодио на путу од куће до посла, без обзира да ли се та повреда по прописима о здравственом, пензијском и инвалидском осигурању сматра повредом на раду. Наиме, повреда на раду увек је основ за остваривање права по основу здравственог пензијског и инвалидског осигурања, али не мора увек да буде довољна за остваривање права запосленог на накнаду штете према послодавцу. Послодавац одговара за штету коју претрпи запослени услед повреде на раду, само уколико је остварен основ по основу кривице или објективне одговорности.

Из образложења:

Првостепени суд је правилно нашао да повреда, задобијена приликом доласка на рад, представља повреду на раду, али је исто тако правилно закључио да у овој правној ствари нема одговорности послодавца за накнаду

штете. Своју оцену неоснованости тужбеног захтева првостепени суд је правилно засновао на општим правилима одштетног права садржаних у Закону о облигационим односима, према којима одговорност за штету може бити заснована на кривици, на објективној одговорности или на одговорности од опасне ствари или делатности. У том смислу, нашао је да нема кривице тужене у смислу чл. 154 став 1 и чл. 158 ЗОО, јер тужена није ни у каквој вези са конкретном саобраћајном незгодом, односно иста није резултат радње или пропуста у раду тужене; да нема ни одговорности за штету од опасне ствари или делатности тужене у смислу чл. 173. и чл.174. истог закона, зато што незгода није у вези са делатношћу тужене; нити објективне одговорности из чл. 164. до 172.истог закона, због тога што је за конкретни штетни догађај познат штетник, тј., лице које је узроковало штету, а за коју штету је чл. 178 ЗОО прописана одговорност у случају удеса изазваног моторним возилима у покрету.

У конкретном случају између повреде коју је тужилац претрпео спорном приликом и поступања тужене нема узрочности, јер је тужилац повређен на путу од места становања до места рада. Тужена није крива што је колега тужиоца изазвао саобраћајну незгоду у којој је повређен тужилац, нити је повреда настала од опасне ствари или опасне делатности тужене. Због тога не постоји одговорност тужене за штету коју је тужилац претрпео у саобраћајном удесу који се догодио на путу од куће до посла, без обзира да ли се та повреда по прописима о здравственом, пензијском и инвалидском осигурању сматра повредом на раду. Наиме, повреда на раду увек је основ за остваривање права по основу здравственог пензијског и инвалидског осигурања, али не мора увек да буде довољна за остваривање права запосленог на накнаду штете према послодавцу. Послодавац одговара за штету коју претрпи запослени услед повреде на раду, само уколико је остварен основ по основу кривице или објективне одговорности.

(Пресуда Основног суда у Куришумлији 2П.бр. 123/16 од 19.09.2018. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 12Гж1 1021/2019 од 27.02.2020. године)

НАКНАДА МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

(Чл.164. Закона о раду и чл. 154. Закона о облигационим односима)

Право на накнаду штете постоји у случају када одређено поступање, односно непоступање неког лица, проузрокује за друго лице штету која се огледа било у умањењу његове имовине, било у спречавању њеног повећања.

Из образложења:

Одредбом члана 164. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005....32/2013), прописано је да ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету у складу са законом и општим актом. Одредбом члана 154. став Закона о облигационим односима, прописано је да ко другом проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да је штета настала без његове кривице. Одредбом члана 155. истог Закона, прописано је да је штета умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист), као и наношење другоме физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета).

Имајући у виду конкретну правну ствар, да би тужилац могао да оствари своје право на накнаду материјалне штете, било је потребно да исти у првостепеном поступку несумњиво докаже да је до исте дошло потврђеним и утврђеним незаконитим понашањем тужених, односно да докаже да би при правилном и законито спроведеном поступку приликом избора кандидата, управо он био изабран и да би управо са њим дошло до заснивања радног односа са пуним фондом часова. Међутим, правилан је закључак првостепеног суда да тужилац у спроведеном поступку није доказао наведене чињенице. Наиме, током првостепеног поступка је несумњиво утврђено да је тужилац учествовао у изборном поступку поводом расписаног конкурса за пријем у радни однос код тужене, при чему су конкурс, али и одлука о избору кандидата, поништени правноснажном судском одлуком, као незаконити. Такође, правилно је утврђено и то да је до поништаја дошло због чињенице да је током поступка прекршена одредба члана 132. Закона о основама система образовања и васпитања, те је донета одлука о пријему у радни однос кандидаткиње која је исти могла да заснује само у својству приправника. Међутим, утврђено је и то да је поред изабране кандидаткиње, у поступку избора, поред тужиоца учествовао још један кандидат који је

као и тужилац испуњавао све услове за избор, а тужилац током поступка није пружио валидне доказе на основу којих би првостепени суд могао јасно и недвосмислено да утврди да би управо он био изабрани кандидат за заснивање радног односа код тужене а не тај други кандидат, када би и остваривао већу зараду коју тужбеним захтевом и потражује. С тим у вези, и по налажењу Апелационог суда, наводи тужиоца током првостепеног поступка о изгубљеној добити услед незаконитих поступања тужених, остали су на нивоу претпоставки и његовог личног уверења.

(Пресуда Основног суда у Неготину 7П 425/18 од 11.09.2019. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 3461/2019 од 14.05.2020. године)

ПОНИШТАЈ ОДЛУКЕ КОЈИМ ЈЕ ОДБИЈЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ВЕЋЕГ КОЕФИЦИЈЕНТА КАО И ПРАВО НА ВЕЋИ КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТЕ (васпитач мастер)

(Чл.52.Закона о предшколском васпитању и обарзовању, чл.2 бб Уредбе о кеофицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, чл.49. Закона о националном оквиру квалификација РС и чл.195. Закона о раду)

Прописи којима се регулише право на плату и начин обрачуна плате у јавном сектору су императивне природе.

Судска заштита у радном спору може се остварити само поводом повреде права запосленог. Право запосленог може бити повређено појединачним актом - одлуком послодавца или фактичком радњом.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је у радном односу код тужене почев од 1999. године на неодређено време на радном месту васпитача, са VI степеном стручне спреме и завршеном Педагошком академијом. Дана 26.10.2006. године, са туженом је закључила Уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности број 1162-04/71-06, којим је одређено да има право на плату која се утврђује на основу основнице за обрачун плата, коју утврђује Влада РС за јавне службе, по коефицијенту 11,88 којим се

множи основица. Анексом уговора број 1543-04/229-13 од 26.9.2013. године, измењен је основни уговор, поред осталог и у делу којим је одређена висина коефицијента за обрачун плате и одређено да тужила има право на коефицијент у висини од 14,88. Дана 29.12.2014. године, тужила је завршила основне академске студије првог степена, на Учитељском факултету у Врању Универзитета у Нишу, у трајању од 4 године и остварила 240 ЕСПБ, стекла високо образовање и стручни назив дипломирани васпитач. Дана 04.03.2015. године, поднела је захтев туженој да јој се на основу стеченог високог образовања почев од 01.01.2015. године, повећа коефицијент са 14,88 на 17,32. Решењем тужене број 384-05/1-15 од 13.03.2015. године, одбијен је њен захтев за признавање коефицијента 17,32. Против овог решења тужила је изјавила жалбу, коју је Управни одбор тужене, Одлуком број 1482-01/3-15 од 07.10.2015. године, одбио и потврдио првостепено решење. Тужила сматра да је ова одлука незаконита, обзиром да је Уредбом Владе Републике Србије о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, прописано да је коефицијент за плате васпитача са VI степеном стручне спреме 14,8 а за VII степен стручне спреме 17,32 и да је она стекла високо образовање са дужином трајања студија од 4 године, због чега има право на плату применом коефицијента од 17,32. Тужбеним захтевом је тражила да суд наведену одлуку поништи и утврди да јој припада право на коефицијент за обрачун зараде 17,32 почев од 01.01.2015. године. Тужена је оспорила тужбени захтев, истичући да стечено високо образовање за васпитаче не подразумева аутоматски VII степен стручне спреме, јер високо образовање имају и васпитачи који имају 180 ЕСПБ и 240 ЕСПБ и мастер васпитачи, те да тужила није стекла VII-1 степен стручне спреме за који је према Уредби прописан коефицијент 17,32.

Одредбом чл. 52. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гл. РС” бр.18/10, 101/17 и 113/17) прописано је да се висина плате, накнаде и других примања утврђује јединствено за све запослене у предшколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у складу са прописима којма се уређују плате, накнаде и друга примања из радног односа у јавним службама.

Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гл. РС” бр. 44/01, 15/02 ...8/13) чл. 2. 6б, прописано је да се за обрачун и исплату плата запослених из чл. 1. ове уредбе примењују коефицијенти за обрачун основне плате и то: у предшколском васпитању

и образовању за васпитача, стручног сарадника, сарадника, секретара, службеника за безбедност и здравље на раду, шефа рачуноводства, дипломираног правника, дипломираног економисту (VII степен стручне спреме) - 17,32 а за васпитача (VI степен стручне спреме) - 14,88.

Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гл. РС” бр. 27/18, 6/20) у одредби чл. 49. прописује да су степени стручне спреме, односно степени образовања, стручни, академски и научни називи стечени према прописима који су важили до ступања на снагу овог закона еквивалентни са нивоима НОКС утврђеним овим законом. У наставку цитиране законске одредбе у тачкама од 1) до 10) дат је упоредни преглед постојећих квалификација, са степенима и називима стручне спреме, односно називима образовних профила који су важили до доношења Закона о високом образовању („Сл. гл. РС” бр. 76/05 ...88/17).

Према табели разврставања квалификација према нивоима НОКС, завршеним основним академским студијама (ОАС, 240 ЕСПБ) према актуелним квалификацијама одговара више образовање са специјализацијом у трајању до 1 године (до 2005.године 6.2 ССС), према претходним прописима.

Тужилца је 2014. године завршила основне академске студије првог степена, на Учитељском факултету у Врању Универзитета у Нишу, у трајању од 4 године и остварила 240 ЕСПБ и на тај начин, према актуелним прописима, стекла високо образовање и стручни назив дипломирани васпитач. Међутим, уподобљавајући њене стечене квалификације према актуелним прописима са раније важећим квалификацијама, према напред наведеном упоредном разврставању квалификација, произилази да њено садашње образовање одговара ранијем вишем образовању, односно 6.2 ССС.

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама прописује коефицијенте за обрачун и исплату плата за васпитача, у предшколском васпитању и то: 17,32 за васпитача са VII степеном стручне спреме, односно 14,88 за васпитача са VI степеном стручне спреме.

Прописи којима се регулише право на плату и начин обрачуна плате у јавном сектору су императивне природе, па како је тужилца стекла VI степен стручне спреме, то је правилно и законито оспорено решење тужене, којим је потврђено првостепено решење којим је одбијен захтев тужилце за признавање обрачуна и исплате плате по коефицијенту 17,32, обзиром да је

овај коефицијент императивним прописима предвиђен за VII степен стручне спреме који тужила не поседује.

Одредбом чл. 195. Закона о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), прописано је да против решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за повреду права, запослени, односно представник синдиката чији је запослени члан ако га запослени овласти, може да покрене спор пред надлежним судом.

Судска заштита у радном спору може се остварити само поводом повреде права запосленог. Право запосленог може бити повређено појединачним актом - одлуком послодавца или фактичком радњом. Ако је повреда учињена одлуком послодавца предмет спора је захтев да се она поништи. Ако је повреда учињена фактичком радњом, предмет спора је захтев да се запосленом, испуњењем одређене обавезе, предузимањем одређене радње или уздржавањем од одређеног понашања, омогући остваривање одређеног права. Када се тужбом тражи поништај одлуке послодавца заштита се остварује у спору о законитости. У том спору суд не одлучује о самом праву, обавези или одговорности запосленог, већ о томе да ли је решење послодавца у складу са законом и општим актом. Када се тужбом тражи заштита права које је повређено фактичком радњом радни спор је спор пуне јурисдикције. У том спору суд одлучује о самом праву, односно самој обавези или одговорности, односно о ономе о чему је требало да одлучује послодавац да је вршио своју дужност.

У конкретном случају, тужена је одлучујући о жалби тужиле на првостепено решење тужене којим је одбијен њен захтев за признавање већег коефицијента, донела оспорену одлуку. Дакле, о праву тужиле послодавац је донео одлуку која је предмет тужбеног захтева у овој парници. Произилази да тужила заштиту права остварује у спору о законитости одлуке послодавца. У радном спору о законитости појединачног акта суд нема пуну јурисдикцију.

Суд је овлашћен да оцењује да ли су донети акти у складу са законом, али не може да одлучује о самим правима, обавезама и одговорностима запосленог. О њима може да одлучује само послодавац, односно надлежни орган.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу 25 Гж1 1923/19 од 02.06.2020. године,

Аутор сентенце Ружица Јовановић- судија Апелационог суда у Нишу

ЗАПОСЛЕНИ-ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, КАО ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК

Члан 101 и чл.102. Закона о раду

Одредбом чл.101 . Закона о раду, прописано је да запосленом - особи са инвалидитетом и запосленом из чл.81. ст.2. овог закона послодавац је дужан да обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са законом. Чланом 102. истог закона прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом, који одбије да прихвати посао у смислу чл.101. наведеног закона. Ако послодавац не може да запосленом обезбеди одговарајући посао у смислу чл.101 овог закона, запослени се сматра вишком у смислу чл.179. ст.5. тач.1. овог закона.

Једини орган који је надлежан да даје оцену радне способности запосленог је Завод за медицину рада, као непристрасни орган.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је био у радном односу код туженог на неодређено време на пословима ... у ОЦ ЗОП Ниш, ОЈ Пружна деоница ..., све до ...године, када му је решењем туженог бр. ... одгодине отказан уговор о раду, због престанка потребе за његовим радом услед технолошких, економских и организационих промена, на основу одредбе чл.179. ст.5. тач.1. Закона о раду. Истим решењем је утврђено право тужиоца на исплату отпремнине у износу од 916.549,22 динара. У образложењу решења је наведено да је због економских и организационих промена у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром престала потреба за радом запосленог, због чега му се отказује уговор о раду и да је висина отпремнине обрачуната у складу са Уговором о раду и Програмом решавања вишка запослених. Тужени је донео Правилник о организацији и систематизацији послова од 15.09.2016.године, према коме је у ОЈ Пружна деоница ... систематизовано радно место пружни радник са шест извршилаца. Тужени је донео Програм за решавање вишка запослених 18.11.2016.године, којим је одредио критеријуме за утврђивање вишка запослених и то: 1) добровољност; 2) резултати рада (квалитет извршених послова, обим извршених послова, однос према раду, као и 3) стаж осигурања. Истим програмом тужени је утврдио у којим случајевима запослени не могу бити вишак, између осталог ако су самохрани родитељи или старатељи. Тужени је донео прелиминарну листу вишка запослених, на којој се нашао

и тужилац, те је изјавио приговор Тиму туженог за приговоре. Након одлуке по приговорима, тужени је сачинио коначну листу вишка запослених где је уписано и име тужиоца. У конкретном случају тужени није оцењивао рад тужиоца, нити применио предвиђене критеријуме приликом утврђивања вишка запослених, јер према наводима туженог у току поступка, тужилац због трајног губитка здравствене способности није испуњавао услове за послове пружног радника, нити су имали могућност да га распореде на друге послове према његовој преосталој здравственој способности. Тужилац се према достављеној документацији налазио на боловању, које и даље траје, из ког разлога чека решење инвалидске комисије. Према оцени лекарске комисије Републичког Фонда за здравствено осигурање одгодине тужилац није способан за самостални ход и није способан за рад. Решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Филијала Пирот бр.... од ...године захтев тужиоца за признавање права на инвалидску пензију је одбијен, јер не постоји потпуни губитак радне способности и лечење тужиоца није завршено. Ова одлука потврђена је решењем Републичког фонда за пензијско и ивалидско осигурање Београд-Дирекција Фонда одгодине.

Код овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је закључио да је решење туженог о отказу уговора о раду незаконито.

Одредбом чл.179. ст.5. тач.1. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 75/14) прописано је да запосленом може да престане радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе послодавца, ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла. Одредбом чл. 185. ст. 1. истог закона прописано је да се уговор о раду отказује решењем, у писаном облику и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку.

Одредбом чл.101. Закона о раду, прописано је да запосленом - особи са инвалидитетом и запосленом из чл.81. ст.2. овог закона послодавац је дужан да обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са законом. Чланом 102. истог закона прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом, који одбије да прихвати посао у смислу чл.101. наведеног закона. Ако послодавац не може да запосленом обезбеди одговарајући посао у смислу чл.101 овог закона, запослени се сматра вишком у смислу чл.179. ст.5. тач.1. овог закона.

Како у конкретном случају тужени у решењу о отказу уговора о раду није навео чињенице и доказе да су наступили законски разлози за отказ уговора о раду тужиоцу због тога што није способан за рад на пословима пружног радника, нити да га тужени може распоредити на друге послове према његовој преосталој здравственој способности, јер о томе не постоји правноснажна одлука надлежног органа, нити је лечење тужиоца завршено, нити је тужени пружио доказе о испуњености напред наведених услова да тужиоцу престане радни однос по основу тенолошког вишка, то је првостепени суд правилно применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца и поништио као незаконито решење туженог о престанку радног односа, дајући довољне разлоге, које прихвата и овај суд.

Без утицаја су на другачију одлуку жалбени наводи туженог да је тужени на основу уверења Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ одгодине утврдио да тужилац није трајно способан за рад на пословима пружног радника, јер су ти наводи и докази морали бити садржани у отказном акту.

Осим тога, међу странкама је неспорно да се тужилац више година налази на боловању и да је у моменту доношења решења о отказу тужилац био привремено спречен за рад, то тужилац није ни могао бити упућен на ванредни лекарски преглед, сходно одредби чл.31. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници бр.655 од 19.01.2000.године, који прописује да се на редовни или ванредни здравствени преглед не може упутити железнички радник који је привремено неспособан за рад док та неспособност траје, осим у случају изричитог захтева лекарске комисије за привремену спреченост за рад преко 30 дана или на захтев инвалидске комисије.

Тужени се у оспореном решењу позвао на одредбу чл. 179. ст.5. тач.1. Закона о раду, а током поступка је доказивао да тужилац није способан за обављање послова пружног радника, нити да му се може обезбедити обављање послова на другом радном месту према његовој преосталој здравственој способности. Као што је већ речено разлоге на ове околности тужени је требало да наведе у побијаном решењу како би суд могао да испита законитост истог.

Супротно томе, тужени се у току поступка и у жалби позива на уверење Завода за здравствену заштиту радника Железнице Србије од ... године, да тужилац није способан за рад на пословима на којима ради. По оцени овог суда једини орган који је надлежан да даје оцену радне способности је Завод

за медицину рада, као непристрасни орган, а не као у овом случају Завод за здравствену заштиту радника Железнице Србије.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 12Гж1 911/2019 од 13.05.2020.године)

Аутори сентенце: Зорица Цветковић, судија Апелационог суда у Нишу и Слађанка Тасић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу.

ОЦЕНА УКУПНЕ ДУЖИНЕ ТРАЈАЊА ПОСТУПКА (члан 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року)

Трајање жалбеног поступка се приликом оцене да ли је у конкретном случају дошло до повреде права из чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије, може посматрати само у склопу целине поступка, а никако изловано. Наиме, правилна примена правног стандарда суђења у разумном року, подразумева између осталог анализу благовремености суђења у свим фазама поступка, као и оцену укупне дужине трајања суђења. Укупна дужина трајања поступка у конкретном случају није подобна да проузрокује повреду права на суђење у разумном року у ситуацији када суд својим поступањем није допринео одуговлачењу поступка. Евентуална кашњења у појединим фазама поступка не доводе до аутоматске повреде права на суђење у разумном року, ако поступак у целини не траје неразумно дуго.

Из образложења:

Након проучавања извештаја судије известиоца, навода из приговора, увидом у списе предмета и применом мерила за оцену суђења у разумном року прописаних одредбом члана 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, сложеност чињеничних и правних питања, целокупно трајање поступка и поступање суда, природа и врста предмета суђења, значај предмета суђења, понашање странака током поступка, посебно поштовање процесних права и обавеза, поштовање редоследа решавања предмета и законски рокови за заједничавање рочишта и изразу одлука, одлучено је као у изреци овог решења.

Одредбама чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије, прописано је да свако има право да му независтан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и оптужбама против њега.

Сходно одредби чл. 18 ст. 3 Устава Републике Србије, одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција које надзиру њихово спровођење.

Одредбом чл. 309 ЗПП прописано је да суд заказује рочиште за главну расправу најкасније у року од 30 дана од одржавања припремног рочишта, односно од пријема одговора на тужбу или протека рока из овог закона за подношење одговора на тужбу, ако оцени да одржавање припремног рочишта није потребно (члан 302) и по правилу, заказује једно рочиште за главну расправу ради извођења свих доказа чије је извођење дозволио или одредио по службеној дужности. Ако суд оцени да је за извођење доказа потребно одржати више од једног рочишта, заказаће их у најкраћем временском размаку, као у конкретном случају, водећи рачуна о концентрацији главне расправе. Суд је дужан да поштује временски оквир одређен на основу члана 308 овог закона, као и да спречи сваки покушај неоснованог одлагања рочишта и санкционише сваку повреду или злоупотребу процесних права и нарушавање процесне дисциплине. Сходно одредби чл. 354 ЗПП пресуда мора да се писано изрази у року од 8 дана од дана објављивања. У сложенијим предметима суд може да одложи писану изразу пресуде за још 15 дана. Суд је дужан да отпреми оверени препис пресуде наредног дана од дана истека рока за изразу пресуде.

У конкретном случају ради се о предмету из радног односа који спада у хитне предмете по самом закону и који чињенично и правно није сложен. Оценом поступања првостепеног суда утврђује се да је првостепени суд поступао у законом прописаним роковима приликом предузимања радњи, у мери која не представљају одуговлачење поступка.

У смислу одредбе чл. 383 ЗПП другостепени суд одлучује о жалби по правилу без расправе. У случају да другостепени суд не држи расправу,

дужан је да одлучи најкасније у року од девет месеци од дана пријема списка првостепеног суда.

Поменути рок од девет месеци инструктивног је карактера, тако да незнатно прекорачење истог не повлачи за собом и повреду права на суђење у разумном року (по аутоматизму). Ово из разлога што је другостепени суд дужан да приликом решавања предмета поштује њихов редослед имајући у виду датум њиховог пријема, при чему предност у решавању имају хитни предмети и предмети са ранијим датумом пријема. Поред наведеног, трајање жалбеног поступка се приликом оцене да ли је у конкретном случају дошло до повреде права из чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије, може посматрати само у склопу целине поступка, а никако изложено.

Наиме, правилна примена правног стандарда суђења у разумном року, подразумева између осталог анализу благовремености суђења у свим фазама поступка, као и оцену укупне дужине трајања суђења. Укупна дужина трајања поступка у конкретном случају није подобна да проузрокује повреду права на суђење у разумном року у ситуацији када суд својим поступањем није допринео одуговлачењу поступка. Евентуална кашњења у појединим фазама поступка не доводе до аутоматске повреде права на суђење у разумном року, ако поступак у целини не траје неразумно дуго.

Због свега наведеног, на основу чл. 10 Закона о заштити права на суђење у разумном року, одлучено је као у изреци овог решења.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Р4 р 4/2020 од 14.02.2020. године)

Сентенцу приредила: Ивана Рађеновић, судија Апелационог суда у Нишу

ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ

(чл.178. ст.1. тач.1. Закона о раду)

Запослени има право да у смислу одредбе чл.178. ст.1. тач.1. Закона о раду откаже уговор о раду. Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писаном облику. Усмена изјава о отказу уговора о раду не производи правно дејство.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужила је била у радном односу код тужене на неодређено време по основу Уговора о раду, на пословима продавца. Решењем тужене без броја и датума, тужили је отказан уговор о раду својевољно – на основу захтева радника, сходно одредби чл. 178. ст. 1. тач. 1. Закона о раду. Тужила сматра да је наведено решење незаконито те је тужбеним захтевом тражила да суд исто поништи и обавезе тужену да је врати на рад. Тужена је оспорила тужбени захтев, наводећи да је тужили отказ дат на основу њеног захтева да се раскине радни однос и да је отказ уследио након спроведеног пописа и утврђеног мањка код послодавца у продајном објекту у коме је тужила радила. Тужени је тужили отказао уговор о раду применом одредби чл. 178. ст. 1. тач. 1. Закона о раду, својевољно – на основу захтева радника.

Одредбом чл. 178. Закона о раду, прописано је да запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду. Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писаном облику, најмање 15 дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа (отказни рок).

За отказ уговора о раду по наведеном основу у смислу цитиране одредбе закона, неопходно је да запослени отказ послодавцу достави у писаној форми, обзиром на правне последице које овај акт има на радно правни статус запосленог.

С тим у вези изјава воље запосленог којом отказује уговор о раду послодавцу је ваљана, ако је сачињена у писаном облику, ако је изричита, јасна и недвосмислена и не захтева тумачење. Усмена изјава о отказу уговора о раду не производи правно дејство.

Тужена у поступку пред првостепеним судом, није доставила доказе да јој је тужила у писаном облику доставила отказ уговора о раду, те је приликом доношења оспореног решења поступила у супротности са одредбом чл. 178. ст. 1. Закона о раду, што ово решење чини незаконитим, како је то правилно закључио првостепени суд.

Како је тужили радни однос престао незаконито и како је тужила тражила враћање на рад, то је правилно првостепени суд закључио да су испуњени услови прописани одредбом чл. 191. ст. 1. Закона о раду.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу 25 Гж1.840/2018 од 26.02.2019. године.

Аутор сенценце Ружица Јовановић- судија Апелационог суда у Нишу

**ПОВРЕДА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ И РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ
(чл. 179. ст. 2. тач. 1. и 5. и ст.3.тач.8. Закона о раду)**

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе и то: ако несавесно или немарно извршава радне обавезе или ако учини другу повреду радне обавезе утврђену општим актом, односно уговором о раду.

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину и то ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је био у радном односу код туженог на пословима магационера. Решењем туженог бр. 295 од 18.05.2017. године, отказан му је уговор о раду, применом чл. 179. ст. 2. тач. 1. и 5. Закона о раду, због повреде радне обавезе из чл. 82. ст. 1. тач. 3. Правилника о раду – неблаговремено, несавесно и немарно извршавање радне обавезе и повреде радне обавезе из чл. 82. ст. 1. тач. 14. Правилника – неоправдано напуштање радног места, одлазак сарада без јављања и одобрења непосредног руководиоца. Тужиоцу је стављено на терет да је дана 20.03.2017. године, поступајући по усменом налогу руководиоца производње, да му писмено достави извештај о стању одређених боја у магацину (шифру, назив и назив произвођача), конкретно, о стању беле боје произвођача Беовар, Београд, у свом извештају означио назив другог (погрешног) произвођача, који производи другу врсту производа а не ону која је у датом моменту била потребна. Из тог разлога наручен је материјал који није био неопходан, па је након тога извршена нова поруџбина одговарајућег материјала од одговарајућег произвођача. Стављено му је на терет и то да је дана 21.03.2017. године, одмах по доласку на рад, у другој смени у 15,00 сати, напустио радно место без питања и одобрења непосредног руководиоца и то у току примопредаје дужности између њега и магационера прве смене, када му је руководиоца производње указао на неодговорно обављање послова, због чега је тужилац бацио кључеве од магацина на сто и напустио фабрику. Пре доношења оспореног решења, тужени га је дана 31.03.2017. године, писаним путем упозорио да постоје разлози да му се уговор о раду откаже, на које се изјаснио писаним одговором од 10.04.2017. године. Тужилац тврди да је оспорено решење о отказу уговора о

раду незаконито, јер он није учинио повреде радне обавезе које су му стављене на терет, да код туженог ради 17 година и да никада није кажњаван за немаран и несавестан рад. Тужени је оспорио тужбени захтев, истичући да је тужилац извршио повреду радне обавезе и радне дисциплине, који су прописани Законом о раду и општим актом. Тужени је тужиоцу отказао уговор о раду применом одредби чл. 179. ст. 2. тач. 1. и 5. Закона о раду, због повреде радне обавезе из чл. 82. ст. 1. тач. 3. Правилника о раду – неблаговремено, несавесно и немарно извршавање радне обавезе и повреде радне обавезе из чл. 82. ст. 1. тач. 14. Правилника – неоправдано напуштање радног места, одлазак са рада без јављања и одобрења непосредног руководиоца.

Одредбом чл. 179. ст. 2. тач. 1. и 5. Закона о раду (“Сл.гл.РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе и то: ако несавесно или немарно извршава радне обавезе или ако учини другу повреду радне обавезе утврђену општим актом, односно уговором о раду.

Одредбом чл. 179. ст. 3. тач. 8. Закона о раду, прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину и то ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца.

Правилником о раду туженог од 26.01.2015. године, у члану 82. ст. 1. прописано је да запосленом престаје радни однос отказом уговора о раду, ако својом кривицом учини повреду радне обавезе и то: неблаговремено, несавесно и немарно извршавање послова (тач.3.) и неоправдано напуштање радног места или одлазак са рада, напуштање радног места или одлазак са рада без јављања непосредном руководиоцу и његове сагласности (тач.14.).

У конкретном случају, тужилац је добио налог од руководиоца производње да поднесе извештај о стању беле боје произвођача Беовар, Београд, која је била потребна за процес производње, а тужилац је у свом извештају означио другог произвођача, у складу са којим извештајем је наручен материјал који није био потребан. Из наведеног разлога је било потребно да се изврши нова поруџбина, што је довело до застоја у производњи. Понашање тужиоца на наведени начин представља несавесно и немарно извршавање радних обавеза, због чега је правилно првостепени суд закључио да је тужилац учинио повреду радне обавезе која му је стављена на терет и да иста

представља оправдани отказни разлог из чл. 179. ст. 2. тач. 1. Закона о раду и чл. 82. ст. 1. тач. 3. Правилника о раду туженог.

У поступку пред првостепеним судом је такође правилно утврђено да је тужилац починио и повреду радне дисциплине, која му је стављена на терет и то напуштање радног места дана 21.03.2017. године, без питања и одобрења непосредног руководиоца. Околности ове повреде произилазе како из навода сведока Љубодрага Милијића, запосленог код туженог на пословима магационера, на којим пословима се он и тужилац смењују, тако и из навода тужиоца у изјашњењу на упозорење, да је наведеног дана напустио радно место у 15, 00 часова и да се није јавио ником од претпостављених, те је правилно првостепени суд закључио да је тужилац, поступајући на наведени начин, учинио и повреду радне дисциплине из чл. 82. ст. 1. тач. 14. Правилника о раду туженог, што представља оправдани отказни разлог у смислу одредбе чл. 179. ст. 3. тач. 8. Закона о раду.

Како је тужилац учинио и повреду радне обавезе и повреду радне дисциплине, то је правилно првостепени суд закључио да је да је неоснован захтев тужиоца за поништај решења којим је тужиоцу отказан уговор о раду као и захтев за враћање на рад .

Из пресуде Апелационог суда у Нишу 25Гж1 1011/201925 од 19.02.2020. године.

Аутор сентенце Ружица Јовановић- судија Апелационог суда у Нишу

Kancelarko



Program za elektronsko kancelarijsko poslovanje

e-Fakture

Šaljite fakture elektronski,
bez troškova štampe i slanja,
uvek uz izveštaj o prijemu fakture.

e-Delovodnik

Uredite svoju dokumentaciju
i knjige dokumenata
digitalno i efikasno.

e-Poštar

Ubrzajte razmenu dokumenta,
smanjite troškove i kreirajte
procedure odobravanja

Beograd

063/379-761

063/379-948

Novi Sad

063/379-961

063/379-772

Niš

063/379-619

063/379-661



Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

✉ kancelarko@paragraf.rs

🌐 **Kancelarko.rs**

NAŠ TIM

Za uspešno poslovanje potrebna je kvalitetna pravno-ekonomska baza. Za kvalitetnu bazu potreban je profesionalan tim. Naš tim broji preko:

- ◆ 190 zaposlenih koji se svakodnevno brinu o tome da dobijete blagovremenu i tačnu informaciju
- ◆ 200 stalnih autora iz oblasti pravnih, ekonomskih i ostalih nauka
- ◆ 18.000 višegodišnjih korisnika koji svojim sugestijama doprinose kvalitetu baze "Paragraf Lex"

BUDŽETSKI
INSTRUKTOR

SUDSKA
PRAKSA

SLUŽBENA
MIŠLENJA

PRAVNO-
EKONOMSKE
VESTI

OBRASCI

CARINSKA
TARIFA

STRANA
SUDSKA
PRAKSA

PROPISI

MODELI

PRAVO
U PRAVOSUĐU

EVROPSKO
ZAKONODAVSTVO

PORESKO
RAČUNOVODSTVENI
INSTRUKTOR

INSPEKTOR

PRAVO
U JAVNOM
SEKTORU

PRAVO
U PRIVREDI

SPECIJALIS
ZA CARINE

Želite pouzdanu pravno-ekonomsku bazu na koju možete da se oslonite i koja će Vam ponuditi stručne tekstove, pronaći odgovore i biti Vaš virtuelni saradnik?

IMAMO REŠENJE ZA VAS!



www.paragraf.rs